

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

304. 대상적격 (1) : 청소년유해매체물 결정 · 고시

“대법원 2007. 6. 14. 선고 2004두619 판결”

<주제>

- 처분성의 판단기준

<쟁점>

- 구 청소년보호법에 따른 청소년유해매체물 결정 · 고시의 법적 성격 및 그 효력발생의 요건과 시기

<판결요지>

- “구 청소년보호법”에 따른 청소년유해매체물 결정 및 고시처분은 당해 유해매체물의 소유자 등 특정인만을 대상으로 한 행정처분이 아니라 일반 불특정 다수인을 상대방으로 하여 일률적으로 표시의무, 포장의무, 청소년에 대한 판매 · 대여 등의 금지의무 등 각종 의무를 발생시키는 행정처분으로서, 정보통신윤리위원회가 특정 인터넷 웹사이트를 청소년유해매체물로 결정하고 청소년보호위원회가 효력발생시기를 명시하여 고시함으로써 그 명시된 시점에 효력이 발생하였다고 봄이 상당하고, 정보통신윤리위원회와 청소년보호위원회가 위 처분이 있었음을 위 웹사이트 운영자에게 제대로 통지하지 아니하였다고 하여 그 효력 자체가 발생하지 아니한 것으로 볼 수는 없다.

<선정이유>

- 불특정 다수인을 상대방으로 하는 일반처분에 관한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

305. 대상적격 (2) : 공공기관의 행위

“대법원 2008. 1. 31. 선고 2005두8269 판결”

<주제>

- 항고소송의 대상이 되는 행정처분의 의미 - 처분을 행할 수 있는 행정청의 의미

<쟁점>

- 한국마사회의 조교사 및 기수 면허 부여 또는 취소가 행정처분인지 여부

<판결요지>

- [1] 행정소송의 대상이 되는 행정처분이란 행정청 또는 그 소속기관이나 법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 공공단체 등이 국민의 권리 · 의무에 관계되는 사항에 관하여 직접 효력을 미치는 공권력의 발동으로서 하는 공법상의 행위를 말하며, 그것이 상대방의 권리를 제한하는 행위라 하더라도 행정청 또는 그 소속기관이나 권한을 위임받은 공공단체 등의 행위가 아닌 한 이를 행정처분이라고 할 수 없다.  
- [2] 한국마사회가 조교사 또는 기수의 면허를 부여하거나 취소하는 것은 경마를 독점적으로 개최할 수 있는 지위에서 우수한 능력을 갖추었다고 인정되는 사람에게 경마에서의 일정한 기능과 역할을 수행할 수 있는 자격을 부여하거나 이를 박탈하는 것에 지나지 아니하므로, 이는 국가 기타 행정기관으로부터 위탁받은 행정권한의 행사가 아니라 일반 사법상의 법률관계에서 이루어지는 단체 내부에서의 징계 내지 제재처분이다.

<선정이유>

- 한국마사회는 공공기관의 운영에 관한 법률상의 공기업에 해당하는데, 한국마사회가 조교사 또는 기수의 면허를 부여하거나 취소하는 제재처분은 국가 기타 행정기관으로부터 위탁받은 행정권한의 행사가 아니라 일반 사법상의 법률관계에서 이루어지는 단체 내부에서의 징계 내지 제재처분으로 본 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

306. 대상적격 (3) : 불문경고

“대법원 2002. 7. 26. 선고 2001두3532 판결”

<주제>

- 행정규칙에 의한 불문경고조치가 행정처분에 해당하기 위한 요건

<쟁점>

- 어떠한 처분의 근거나 법적인 효과가 행정규칙에 규정되어 있는 경우, 그 처분이 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하기 위한 요건

<판결요지>

- [1] 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 함은 원칙적으로 행정청의 공법상 행위로서 특정 사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 발생하게 하는 등으로 일반 국민의 권리 의무에 직접 영향을 미치는 행위를 가리키는 것이지만, 어떠한 처분의 근거나 법적인 효과가 행정규칙에 규정되어 있다고 하더라도, 그 처분이 행정규칙의 내부적 구속력에 의하여 상대방에게 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법적인 효과를 발생하게 하는 등으로 그 상대방의 권리 의무에 직접 영향을 미치는 행위라면, 이 경우에도 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다.

- [2] 행정규칙에 의한 불문경고조치가 비록 법률상의 징계처분은 아니지만 위 처분을 받지 아니하였다면 차후 다른 징계처분이나 경고를 받게 될 경우 징계감경사유로 사용될 수 있었던 표창공적의 사용가능성을 소멸시키는 효과와 1년 동안 인사기록카드에 등재됨으로써 그 동안은 장관표창이나 도지사 표창 대상자에서 제외시키는 효과 등이 있다는 이유로 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 한 사례

<선정이유>

- 어떠한 처분의 근거나 법적인 효과가 행정규칙에 규정되어 있다고 하더라도, 그 처분이 행정규칙의 내부적 구속력에 의하여 그 상대방의 권리 의무에 직접 영향을 미치는 행위라면 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다는 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

307. 대상적격 (4) : 행정규칙에 근거한 처분

“대법원 2004. 11. 26. 선고 2003두10251, 10268 판결”

<주제>

- 행정규칙에 근거한 조치가 행정처분에 해당하기 위한 요건

<쟁점>

- [1] 어떠한 처분의 근거가 행정규칙에 규정되어 있는 경우, 그 처분이 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하기 위한 요건  
- [2] 정부 간 항공노선의 개설에 관한 잠정협정 및 비밀양해각서와 건설교통부 내부지침에 의한 항공노선에 대한 운수권배분처분이 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라 함은 원칙적으로 행정청의 공법상 행위로서 특정 사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 발생하게 하는 등으로 일반 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치는 행위를 가리키는 것이지만, 어떠한 처분의 근거가 행정규칙에 규정되어 있다고 하더라도, 그 처분이 상대방에게 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법적인 효과를 발생하게 하는 등으로 그 상대방의 권리의무에 직접 영향을 미치는 행위라면, 이 경우에도 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다.  
- [2] 노선을 배분받은 항공사는 중국 항공당국에 통보됨으로써 이 사건 잠정협정 및 비밀양해각서에 의한 지정항공사로서의 지위를 취득하고, 중국의 지정항공사와 상무협정을 체결하는 등 노선면허를 취득하기 위한 후속절차를 밟아 중국 항공당국으로부터 운항허가를 받을 수 있게 되며, 추후 당해 노선상의 합의된 업무를 운영함에 있어 중국의 영역 내에서 무착륙비행, 비 운수목적의 착륙등 제 권리를 가지게 되는 반면, 노선배분을 받지 못한 항공사는 상대국 지정항공사와의 상무협정체결 등 노선면허 취득을 위한 후속절차를 밟을 수 없을 뿐만 아니라 중국 항공당국으로부터 운항허가를 받을 수도 없는 지위에 놓이게 된다.  
- 위에서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 각 노선에 대한 운수권배분처분은 이 사건 잠정협정 등과 행정규칙인 이 사건 지침에 근거하는 것으로서 상대방에게 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법적 효과를 발생하게 하는 등으로 원고의 권리의무에 직접 영향을 미치는 행위로서 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 할 것이다.

<선정이유>

- 정부 간 항공노선의 개설에 관한 잠정협정 및 비밀양해각서와 건설교통부 내부지침에 의한 항공노선에 대한 운수권배분처분이 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

308. 대상적격 (5) : 검찰총장의 검사에 대한 경고조치

“대법원 2021. 2. 10. 선고 2020두47564 판결”

<주제>

- 검찰총장이 검사에 대하여 하는 경고조치가 항고소송의 대상으로서의 처분 여부

<쟁점>

- [1] 처분의 근거나 법적인 효과가 행정규칙에 규정되어 있는 경우, 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하기 위한 요건 / 검찰총장이 검사에 대하여 하는 경고조치가 항고소송의 대상이 되는 처분인지 여부(적극)  
- [2] 검찰총장의 경고처분의 성격 및 검사의 직무상 의무 위반의 정도가 중하지 않아 “검사징계법”에 따른 징계사유에 해당하지 않더라도 징계처분보다 낮은 수준의 감독조치로서 경고처분을 할 수 있는지 여부(적극) / 이때 법원은 이를 존중해야 하는지 여부(원칙적 적극)

<판결요지>

- [1] 항고소송의 대상이 되는 행정처분이란 원칙적으로 행정청의 공법상 행위로서 특정 사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 발생하게 하는 등으로 일반 국민의 권리 의무에 직접 영향을 미치는 행위를 가리키는 것이지만, 어떠한 처분의 근거나 법적인 효과가 행정규칙에 규정되어 있다고 하더라도, 그 처분이 행정규칙의 내부적 구속력에 의하여 상대방에게 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법적인 효과를 발생하게 하는 등으로 그 상대방의 권리 의무에 직접 영향을 미치는 행위라면, 이 경우에도 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 보아야 한다.  
- 검사에 대한 경고조치 관련 규정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 검찰총장이 사무검사 및 사건평정을 기초로 대검찰청 자체감사규정 제23조 제3항, 검찰공무원의 범죄 및 비위 처리지침 제4조 제2항 제2호 등에 근거하여 검사에 대하여 하는 경고조치는 일정한 서식에 따라 검사에게 개별 통지를 하고 이

의신청을 할 수 있으며, 검사가 검찰총장의 경고를 받으면 1년 이상 감찰관리 대상자로 선정되어 특별관리를 받을 수 있고, 경고를 받은 사실이 인사자료로 활용되어 복무평정, 직무성공급 지급, 승진·전보인사에서 불이익을 받게 될 가능성이 높아지며, 향후 다른 징계사유로 징계처분을 받게 될 경우에 징계양정에서 불이익을 받게 될 가능성이 높아지므로, 검사의 권리 의무에 영향을 미치는 행위로서 항고소송의 대상이 되는 처분이라고 보아야 한다.

- [2] "검찰청법 제7조 제1항·제12조 제2항", "검사징계법 제2조·제3조 제1항·제7조 제1항", 대검찰청 자체감사규정 제23조 제2항, 제3항, 사건평정기준 제2조 제1항 제2호, 제5조, 검찰공무원의 범죄 및 비위 처리지침 제4조 제2항 제2호, 제3항 [별표 1] 징계양정기준, 제4항, 제5항 등 관련규정들의 내용과 체계 등을 종합하여 보면, 검찰총장의 경고처분은 검사징계법에 따른 징계처분이 아니라 "검찰청법 제7조 제1항·제12조 제2항"에 근거하여 검사에 대한 직무감독권을 행사하는 작용에 해당하므로, 검사의 직무상 의무 위반의 정도가 중하지 않아 검사징계법에 따른 징계사유에는 해당하지 않더라도 징계처분보다 낮은 수준의 감독조치로서 경고처분을 할 수 있고, 법원은 그것이 직무감독권자에게 주어진 재량권을 일탈·남용한 것이라는 특별한 사정이 없는 한 이를 존중하는 것이 바람직하다.

<선정이유>

- 검찰총장이 검사에 대하여 한 경고조치는 행정규칙에 근거하고 있더라도 검사의 법적지위에 영향을 미치는 경우에는 항고소송의 대상인 행정처분에 해당한다고 본 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

309. 대상적격 (6) : 건축협의 취소

“대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두22980 판결”

<주제>

- 지방자치단체장이 자치사무의 처리로서 행한 결정의 처분성

<쟁점>

- "구 건축법 제29조 제1항"에서 정한 건축협의의 취소가 처분에 해당하는지 여부(적극) 및 지방자치단체 등이 건축물 소재지 관할 허가권자인 지방자치단체의 장을 상대로 건축협의의 취소의 취소를 구할 수 있는지 여부(적극)

<판결요지>

- "구 건축법 제29조 제1항", "제2항", "제11조 제1항" 등의 규정 내용에 의하면, 건축협의의 실질은 지방자치단체 등에 대한 건축허가와 다르지 않으므로, 지방자치단체 등이 건축물을 건축하려는 경우 등에는 미리 건축물의 소재지를 관할하는 허가권자인 지방자치단체의 장과 건축협의의 하지 않으면, 지방자치단체라 하더라도 건축물을 건축할 수 없다. 그리고 "구 지방자치법" 등 관련 법령을 살펴봐도 지방자치단체의 장이 다른 지방자치단체를 상대로 한 건축협의의 취소에 관하여 다툼이 있는 경우에 법적 분쟁을 실효적으로 해결할 구제수단을 찾기도 어렵다.

- 따라서 건축협의의 취소는 상대방이 다른 지방자치단체 등 행정주체라 하더라도 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력 행사("행정소송법 제2조 제1항 제1호")로서 처분에 해당한다고 볼 수 있고, 지방자치단체인 원고가 이를 다툼 실효적 해결 수단이 없는 이상, 원고는 건축물 소재지 관할 허가권자인 지방자치단체의 장을 상대로 항고소송을 통해 건축협의의 취소의 취소를 구할 수 있다.

<선정이유>

- 다른 행정주체를 상대방으로 하는 행위도 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력 행사로서 처분이 될 수 있음을 인정한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

310. 대상적격 (7) : 도시관리계획의 처분성

“대법원 1982. 3. 9. 선고 80누105 판결”

<주제>

- 도시계획결정(현행법상 도시·군관리계획)의 처분성

<쟁점>

- 행정계획인 도시계획결정(현행법상 도시·군관리계획)의 처분성

<판결요지>

- "도시계획법 제12조" 소정의 고시된 도시계획결정(국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 도시·군관리계획)은 특정 개인의 권리 내지 법률상의 이익을 개별적이고 구체적으로 규제하는 효과를 가져오게 하는 행정청의 처분이라 할 것이고, 이는 행정소송의 대상이 된다.

<선정이유>

- 행정계획의 성격을 지니고 있는 도시계획결정(도시·군관리계획)이라 하더라도 그 자체로 국민의 권리의무에 영향을 미치는 이상 처분으로 보아야 한다는 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

311. 대상적격 (8) : 조례

**“대법원 1996. 9. 20. 선고 95누8003 판결”**

**<주제>**

- 조례가 항고소송의 대상이 되기 위한 요건

**<쟁점>**

- [1] 조례가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당되는 경우 및 그 경우 조례무효확인 소송의 피고적격(지방자치단체의 장)
- [2] 교육에 관한 조례 무효확인소송에 있어서 피고적격(교육감)

**<판결요지>**

- [1] 조례가 집행행위의 개입 없이도 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법적 이익에 영향을 미치는 등의 법률상 효과를 발생하는 경우 그 조례는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하고, 이러한 조례에 대한 무효확인소송을 제기함에 있어서 "행정소송법 제38조 제1항", "제13조"에 의하여 피고적격이 있는 처분등을 행한 행정청은, 행정주체인 지방자치단체 또는 지방자치단체의 내부적 의결기관으로서 지방자치단체의 의사를 외부에 표시한 권한이 없는 지방의회가 아니라, "구 지방자치법 제19조 제2항", "제92조"에 의하여 지방자치단체의 집행기관으로서 조례로서의 효력을 발생시키는 공포권이 있는 지방자치단체의 장이다.

- [2] "구 지방교육자치에관한법률 제14조 제5항", "제25조"에 의하면 시·도의 교육·학예에 관한 사무의 집행기관은 시·도 교육감이고 시·도 교육감에게 지방교육에 관한 조례안의 공포권이 있다고 규정되어 있으므로, 교육에 관한 조례의 무효확인소송을 제기함에 있어서는 그 집행기관인 시·도 교육감을 피고로 하여야 한다.

**<선정이유>**

- 조례가 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당하기 위한 요건 및 이를 항고소송으로 다룰 경우의 피고적격에 관한 판결

**<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>**

**312. 대상적격 (9) : 조례로 결정할 사항을 개별 결정에 의한 경우**

**“대법원 2004. 11. 26. 선고 2003두10251, 10268 판결”**

**<주제>**

- 도지사의 지방의료원 폐업결정의 처분성

**<쟁점>**

- 갑 도지사가 도에서 설치·운영하는 을 지방의료원을 폐업하겠다는 결정을 발표하고 그에 따라 폐업을 위한 일련의 조치가 이루어진 후 을 지방의료원을 해산한다는 내용의 조례를 공포하고 을지방의료원의 청산절차가 마쳐진 사안에서, 갑 도지사의 폐업결정을 항고소송의 대상으로 본 사례

**<판결요지>**

- ❶ 지방의료원의 설립·통합·해산은 지방자치단체의 조례로 결정할 사항이므로, 피고 경상남도가 설치·운영하는 지방의료원인 진주의료원의 폐업·해산은 피고 경상남도의 조례로 결정할 사항인 점, ❷ 그럼에도 이 사건 조례가 공포된 2013. 7. 1. 이전에 의료진과의 근무계약 해지, 환자들에 대한 전원조치 및 진주의료원 폐업신고 등 진주의료원의 폐업을 위한 조치가 이루어졌고, 이러한 일련의 조치는 피고 경상남도지사의 이 사건 폐업결정에 따른 것으로 보이는 점, ❸ 피고 경상남도지사의 이 사건 폐업결정으로 인하여 입원환자들은 퇴원하거나 전원하여야 하고, 직원들도 직장을 잃게 되는 등 이들의 권리·의무에 중대한 영향을 미치므로 진주의료원의 폐업이 관계법령상의 기준과 절차를 준수하였는지에 대한 사법심사가 필요한 점 등을 종합하면, 피고 경상남도지사의 이 사건 폐업결정은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사로서 입원환자들과 소속 직원들의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 것이므로 항고소송의 대상에 해당한다고 할 것이다.

**<선정이유>**

- 지방의료원 폐업은 조례로 결정할 사안이나, 조례 공포 전에 이루어진 도지사의 폐업결정으로 폐업을 위한 조치가 이루어진 경우 폐업결정 자체의 처분성이 인정된다고 본 판결

**<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>**

**313. 대상적격 (10) : 고시**

**“대법원 2006. 9. 22. 선고 2005두2506 판결”**

**<주제>**

- 약제급여·비급여목록 및 급여상한금액표의 처분성과 원고적격, 사정판결

**<쟁점>**

- [1] 고시가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하기 위한 요건
- [2] 보건복지부 고시인 약제급여·비급여목록 및 급여상한금액표의 처분성
- [3] 제약회사에게 보건복지부 고시인 약제급여·비급여목록 및 급여상한금액표의 취소를 구할 원고적격이 인정되는지 여부
- [4] 법원이 직권으로 사정판결을 할 수 있는지 여부(적극) 및 사정판결을 하기 위한 요건인 현저히 공공복리에 적합하지 아니한지 여부의 판단 기준

**<판결요지>**

- [1] 어떠한 고시가 일반적·추상적 성격을 가질 때에는 법규명령 또는 행정규칙에 해당할 것이지만, 다른 집행행위의 매개 없이 그 자체로서 직접 국민의 구체적인 권리의무나 법률관계를 규율하는 성격을 가질 때에는 행정처분에 해당한다.

- [2] 원심은 그 채용 증거들을 종합하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, ❶ 약제급여·비급여목록 및 급여상한금액표(이하 '이 사건 고시')는 특정 제약회사의 특정 약제에 대하여 국민건강보험가입자 또는 국민건강보험공단이 지급하여야 하거나 요양기관이 상환받을 수 있는 약제비용의 구체적 한도액을 특정하여 설정하고 있는 점, ❷ 약제의 지급과 비용의 청구행위가 있기만 하면 달리 행정청의 특별한 집행행위의 개입 없이 이 사건 고시가 적용되는 점, ❸ 특정 약제의 상한금액의 변동은 곧바로 국민건강보험가입자 또는 국민건강보험공단이 지급하여야 하거나 요양기관이 상환받을 수 있는 약제비용을 변동시킬 수 있다는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 고시는 다른 집행행위의 매개 없이 그 자체로서 국민건강보험가입자, 국민건강보험공단, 요양기관 등의 법률관계를 직접 규율하는 성격을 가진다고 할 것이므로, 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다는 취지로 판단하였는바, 관계 법령과 위 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하다.

- [3] 제약회사가 자신이 공급하는 약제에 관하여 "국민건강보험법", "같은 법 시행령", "국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙" 등 약제상한금액 고시의 근거 법령에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익을 향유하는데, 보건복지부 고시인 약제급여·비급여목록 및 급여상한금액표로 인하여 자신이 제조·공급하는 약제의 상한금액이 인하됨에 따라 위와 같이 보호되는 법률상 이익이 침해당할 경우, 제약회사는 위 고시의 취소를 구할 원고적격이 있다.

- [4] 행정처분이 위법한 경우에는 이를 취소하는 것이 원칙이나, 예외적으로 그 위법한 처분을 취소·변경하는 것이 도리어 현저히 공공복리에 적합하지 아니하는 경우에는 그 취소를 허용하지 아니하는 사정판결을 할 수 있다. 이러한 사정판결은 당사자의 명백한 주장이 없는 경우에도 기록에 나타난 여러 사정을 기초로 직권으로 할 수 있는 것이나, 그 요건인 현저히 공공복리에 적합하지 아니한지 여부는 위법한 행정처분을 취소·변경하여야 할 필요와 그 취소·변경으로 인하여 발생할 수 있는 공공복리에 반하는 사태 등을 비교·교량하여 판단하여야 한다.

<선정이유>

- 고시가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하기 위한 요건에 관한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

314. 대상적격 (11) : 지목변경신청에 대한 거부

“대법원 2004. 4. 22. 선고 2003두9015 전원합의체 판결”

<주제>

- 지적공부 등재거부의 처분성

<쟁점>

- 지적공부 소관청의 지목변경신청 반려행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는지 여부(적극)

<판결요지>

- "구 지적법 제20조", "제38조 제2항"의 규정은 토지소유자에게 지목변경신청권과 지목정정신청권을 부여한 것이고, 한편 지목은 토지에 대한 공법상의 규제, 개발부담금의 부과대상, 지방세의 과세대상, 공시지가의 산정, 손실보상가액의 산정 등 토지행정의 기초로서 공법상의 법률관계에 영향을 미치고, 토지소유자는 지목을 토대로 토지의 사용·수익·처분에 일정한 제한을 받게 되는 점 등을 고려하면, 지목은 토지소유권을 제대로 행사하기 위한 전제요건으로서 토지소유자의 실체적 권리관계에 밀접하게 관련되어 있으므로 지적공부 소관청의 지목변경신청 반려행위는 국민의 권리관계에 영향을 미치는 것으로서 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다.

<선정이유>

- 지목의 변경 기타 토지대장상에 일정한 사항을 등재하거나 등재사항을 변경하는 행위는 그로 인하여 어떠한 권리가 부여되거나 권리변동 또는 상실의 효력이 생기는 것이 아니므로 소관청의 토지지목변경신청거부(반려) 처분은 행정소송의 대상이 되는 행정처분이 아니라 본 기존의 판례를 변경한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

315. 대상적격 (12) : 거부행위의 처분성

“대법원 2009. 9. 10. 선고 2007두20638 판결”

<주제>

- 신청에 대한 거부가 행정처분에 해당하기 위한 요건, 신청권의 의미

<쟁점>

- [1] 국민의 적극적 신청행위에 대한 행정청의 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하기 위한 요건  
- [2] 국민이 어떤 신청을 한 경우 그에 대한 행정청의 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 처분인지 여부를 판단할 때 신청권의 존재 여부를 넘어서 구체적으로 그 신청의 인용 여부까지 판단하여야 하는지 여부(소극)  
- [3] 금강수계 중 상수원 수질보전을 위하여 필요한 지역의 토지 등의 소유자가 국가에 그 토지 등을 매도하기 위하여 매수신청을 하였으나 유역환경청장이 이를 거절한 사안에서, 그 매수 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 국민의 적극적 신청행위에 대하여 행정청이 그 신청에 따른 행위를 하지 않겠다고 거부한 행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는 것이라고 하려면, ❶ 그 신청한 행위가 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용이어야 하고, ❷ 그 거부행위가 신청인의 법률관계에 어떤 변동을 일으키는 것이어야 하며, ❸ 그 국민에게 그 행위발동을 요구할 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 한다.

- [2] 거부처분의 처분성을 인정하기 위한 전제요건이 되는 신청권의 존부는 구체적 사건에서 신청인이 누구인가를 고려하지 않고 관계 법규의 해석에 의하여 일반 국민에게 그러한 신청권을 인정하고 있는가를 살펴 추상적으로 결정되는 것이고, 신청인이 그 신청에 따른 단순한 응답을 받을 권리를 넘어서 신청의 인용이라는 만족적 결과를 얻을 권리를 의미하는 것은 아니므로, 국민이 어떤 신청을 한 경우에 그 신청의 근거가 된 조항의 해석상 행정발동에 대한 개인의 신청권을 인정하고 있다고 보이면 그 거부행위는 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보아야 하고, 구체적으로 그 신청이 인용될 수 있는가 하는 점은 본안에서 판단하여야 할 사항이다.

- [3] 금강수계 중 상수원 수질보전을 위하여 필요한 지역의 토지 등의 소유자가 국가에 그 토지 등을 매도하기 위하여 매수신청을 하였으나 유역환경청장 등이 매수거절의 결정을 한 사안에서, 토지 등의 매수제도는 환경침해적인 토지이용을 예방하여 상수원의 수질개선을 도모함과 아울러 상수원지역의 토지이용규제로 인한 토지 등의 소유자의 재산권 침해에 대해 보상하려는 것을 목적으로 하는 것으로서 손실보상을 대체하는 성격도 있는 점, 위 규정에 따른 매수신청에 대하여 유역환경청장 등이 매수거절의 결정을 할 경우 토지 등의 소유자로서는 재산권에 대한 제한을 피할 수 없게 되는데, 위 매수거절을 항고소송의 대상이 되는 행정처분으로 보지 않는다면 달리 이에 대하여는 다룰 방법이 없게 되는 점 등에 비추어 그 매수 거부행위가 공권력의 행사 또는 이에 준하는 행정작용으로서 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 한 사례

#### <선정이유>

- 국민의 적극적 신청행위에 대한 행정청의 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하기 위한 요건(법규상 또는 조리상의 신청권)에 관한 판결

#### <제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

#### 316. 대상적격 (13) : 계획변경신청에 대한 거부

“대법원 2015. 3. 26. 선고 2014두42742 판결”

#### <주제>

- 거부처분의 요건 - 행정계획 변경신청권

#### <쟁점>

- 도시계획구역 내 토지소유자와 같이 도시계획시설결정에 이해관계가 있는 주민에게 도시시설계획의 입안 내지 변경을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있는지 여부(적극) 및 이러한 신청에 대한 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는지 여부(적극)

#### <판결요지>

- "국토의 계획 및 이용에 관한 법률"은 국토의 이용·개발과 보전을 위한 계획의 수립 및 집행 등에 필요한 사항을 규정함으로써 공공복리를 증진시키고 국민의 삶의 질을 향상시키는 것을 목적으로 하면서도 도시계획시설결정으로 인한 개인의 재산권행사의 제한을 줄이기 위하여, 도시·군계획시설부지의 매수청구권("제47조"), 도시·군계획시설결정의 실효("제48조")에 관한 규정과 아울러 도시·군관리계획의 입안권자인 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 '입안권자'라 한다)는 5년마다 관할 구역의 도시·군관리계획에 대하여 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비하여야 할 의무를 지우고("제34조"), 주민(이해관계자 포함)에게는 도시·군관리계획의 입안권자에게 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항, 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획도서와 계획설명서를 첨부하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 권리를 부여하고 있고, 입안제안을 받은 입안권자는 그 처리 결과를 제안자에게 통보하도록 규정하고 있다. 이들 규정에 헌법상 개인의 재산권 보장의 취지를 더하여 보면, 도시계획구역 내 토지 등을 소유하고 있는 사람과 같이 당해 도시계획시설결정에 이해관계가 있는 주민으로서 도시시설계획의 입안권자 내지 결정권자에게 도시시설계획의 입안 내지 변경을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있고, 이러한 신청에 대한 거부행위는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다.

#### <선정이유>

- 도시계획구역 내 토지소유자와 같이 도시계획시설결정에 이해관계가 있는 주민에게 도시시설계획의 입안 내지 변경을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있고, 이러한 신청에 대한 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다고 한 판결

#### <제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

#### 317. 대상적격 (14) : 국립대학교원 재임용 거부

“대법원 2004. 4. 22. 선고 2000두7735 전원합의체 판결”

#### <주제>

- 국립대학교원 재임용 거부의 처분성과 신청권

#### <쟁점>

- 대학교원의 임용권자가 임용기간이 만료된 조교수에 대하여 재임용을 거부하는 취지로 한 임용기간만료의 통지가 행정소송의 대상이 되는 처분에 해당하는지 여부(적극)

#### <판결요지>

- 기간제로 임용되어 임용기간이 만료된 국·공립대학의 조교수는 교원으로서의 능력과 자질에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 받아 위 기준에 부합되면 특별한 사정이 없는 한 재임용되리라는 기대를 가지고 재임용 여부에 관하여 합리적인 기준에 의한 공정한 심사를 요구할 법규상 또는 조리상 신청권을 가진다고 할 것이니, 임용권자가 임용기간이 만료된 조교수에 대하여 재임용을 거부하는 취지로 한 임용기간만료의 통지는 위와 같은 대학교원의 법률관계에 영향을 주는 것으로서 행정소송의 대상이 되는 처분에 해당한다.

<선정이유>

- 국·공립대학교원의 재임용신청권을 인정한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

318. 대상적격 (15) : 대학교원 신규임용거부

“대법원 2004. 6. 11. 선고 2001두7053 판결”

<주제>

- 대학교원 신규임용거부의 처분성과 신청권

<쟁점>

- 대학교원의 신규채용에 있어서 유일한 면접심사 대상자로 선정된 임용지원자에 대한 교원신규채용 중단조치가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는지 여부(적극)

<판결요지>

- "구 교육공무원법" 및 "구 교육공무원임용령 등 관계 법령"에 대학교원의 신규임용에 있어서의 심사단계나 심사방법 등에 관하여 아무런 규정을 두지 않았다고 하더라도, 대학 스스로 교원의 임용규정이나 신규채용업무시행지침 등을 제정하여 그에 따라 교원을 신규임용하여 온 경우, 임용지원자가 당해 대학의 교원임용규정 등에 정한 심사단계 중 중요한 대부분의 단계를 통과하여 다수의 임용지원자 중 유일한 면접심사 대상자로 선정되는 등으로 장차 나머지 일부의 심사단계를 거쳐 대학교원으로 임용될 것을 상당한 정도로 기대할 수 있는 지위에 이르렀다면, 그러한 임용지원자는 임용에 관한 법률상 이익을 가진 자로서 임용권자에 대하여 나머지 심사를 공정하게 진행하여 그 심사에서 통과되면 대학교원으로 임용해 줄 것을 신청할 조리상의 권리가 있다고 보아야 할 것이고, 또한 유일한 면접심사 대상자로 선정된 임용지원자에 대한 교원신규채용업무를 중단하는 조치는 교원신규채용절차의 진행을 유보하였다가 다시 속개하기 위한 중간처분 또는 사무처리절차상 하나의 행위에 불과한 것이라고는 볼 수 없고, 유일한 면접심사 대상자로서 임용에 관한 법률상 이익을 가지는 임용지원자에 대한 신규임용을 사실상 거부하는 중국적인 조치에 해당하는 것이며, 임용지원자에게 직접 고지되지 않았다고 하더라도 임용지원자가 이를 알게 됨으로써 효력이 발생한 것으로 보아야 할 것이므로, 이는 임용지원자의 권리 내지 법률상 이익에 직접 관계되는 것으로서 항고소송의 대상이 되는 처분 등에 해당한다.

<선정이유>

- 대학교원 신규임용지원자의 조리상 신청권을 예외적으로 인정한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

319. 대상적격 (16) : 총장임용제청 제외

“대법원 2018. 6. 15. 선고 2016두57564 판결”

<주제>

- 총장임용제청제외 및 총장임용제외의 처분성, 총장임용제청제외처분의 취소를 구할 소의 이익

<쟁점>

- [1] 교육부장관이 대학에서 추천한 복수의 총장 후보자들 전부 또는 일부를 임용제청에서 제외하는 행위가 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당하는지 여부(적극)  
- [2] 교육부장관이 특정 후보자를 임용제청에서 제외하고 다른 후보자를 임용제청함으로써 대통령이 임용제청된 다른 후보자를 총장으로 임용한 경우, 임용제청에서 제외된 후보자가 행정소송으로 다툰 처분(=대통령의 임용 제외처분)

<판결요지>

- [1] 대학의 장 임용에 관하여 교육부장관의 임용제청권을 인정한 취지는 대학의 자율성과 대통령의 실질적인 임용권 행사를 조화시키기 위하여 대통령의 최종적인 임용권 행사에 앞서 대학의 추천을 받은 총장 후보자들의 적격성을 일차적으로 심사하여 대통령의 임용권 행사가 적정하게 이루어질 수 있도록 하기 위한 것이다.  
- [2] 대학의 추천을 받은 총장 후보자는 교육부장관으로부터 정당한 심사를 받을 것이라는 기대를 하게 된다. 만일 교육부장관이 자의적으로 대학에서 추천한 복수의 총장 후보자들 전부 또는 일부를 임용제청하지 않는다면 대통령으로부터 임용을 받을 기회를 박탈하는 효과가 있다. 이를 항고소송의 대상이 되는 처분으로 보지 않는다면, 침해된 권리 또는 법률상 이익을 구제받을 방법이 없다. 따라서 교육부장관이 대학에서 추천한 복수의 총장 후보자들 전부 또는 일부를 임용제청에서 제외하는 행위는 제외된 후보자들에 대한 불이익 처분으로서 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당한다고 보아야 한다.  
- [3] 다만 교육부장관이 특정 후보자를 임용제청에서 제외하고 다른 후보자를 임용제청함으로써 대통령이 임용제청된 다른 후보자를 총장으로 임용한 경우에는, 임용제청에서 제외된 후보자는 대통령이 자신에 대하여 총장 임용 제외처분을 한 것으로 보아 이를 다투어야 한다(대통령의 처분의 경우 소속

장관이 행정소송의 피고가 된다. "국가공무원법 제16조 제2항"). 이러한 경우에는 교육부장관의 임용제청 제외처분을 별도로 다룰 소의 이익이 없어진다.

<선정이유>

- 교육부장관이 대학에서 추천한 복수의 총장 후보자들 전부 또는 일부를 임용제청에서 제외하는 행위가 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당한다는 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

320. 대상적격 (17) : 철거명령신청에 대한 거부

“대법원 1999. 12. 7. 선고 97누17568 판결”

<주제>

- 철거명령 신청에 대한 거부행위가 처분으로 인정되기 위한 요건 - 신청권

<쟁점>

- [1] 행정청이 국민의 신청에 대하여 한 거부행위가 항고소송의 대상인 행정처분이 되기 위한 요건
- [2] 부작위위법확인 소의 요건
- [3] 국민이 행정청에 대하여 제3자에 대한 건축허가와 준공검사의 취소 및 제3자 소유의 건축물에 대한 철거명령을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상 권리가 있는지 여부(소극)

<판결요지>

- [1] 국민의 신청에 대한 행정청의 거부행위가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하기 위하여는 국민이 행정청에 대하여 그 신청에 따른 행정행위를 하여 줄 것을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상의 권리가 있어야 한다.
- [2] 부작위위법확인 소에 있어 당사자가 행정청에 대하여 어떠한 행정행위를 하여 줄 것을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상 권리를 갖고 있지 아니한 경우에는 원고적격이 없거나 항고소송의 대상인 위법한 부작위가 있다고 볼 수 없어 그 부작위위법확인 소는 부적법하다.
- [3] "구 건축법" 및 기타 관계 법령에 국민이 행정청에 대하여 제3자에 대한 건축허가의 취소나 준공검사의 취소 또는 제3자 소유의 건축물에 대한 철거 등의 조치를 요구할 수 있다는 취지의 규정이 없고, "같은 법 제69조 제1항" 및 "제70조 제1항"은 각 조항 소정의 사유가 있는 경우에 시장·군수·구청장에게 건축허가 등을 취소하거나 건축물의 철거 등 필요한 조치를 명할 수 있는 권한 내지 권능을 부여한 것에 불과할 뿐, 시장·군수·구청장에게 그러한 의무가 있음을 규정한 것은 아니므로 위 조항들도 그 근거 규정이 될 수 없으며, 그 밖에 조리상 이러한 권리가 인정된다고 볼 수도 없다.

<선정이유>

- 일반적으로 국민이 행정청에 대하여 제3자에 대한 건축허가와 준공검사의 취소 및 제3자 소유의 건축물에 대한 철거명령을 요구할 수 있는 법규상 또는 조리상 권리가 없고, 따라서 그러한 요구에 대한 거부하는 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당하지 않는다는 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

321. 대상적격 (18) : 공사중지명령 철회신청에 대한 거부

“대법원 2005. 4. 14. 선고 2003두7590 판결”

<주제>

- 공사중지명령의 철회를 요구할 조리상의 신청권

<쟁점>

- 행정청이 행한 공사중지명령의 상대방이 그 명령 이후에 그 원인사유가 소멸하였음을 들어 행정청에 대하여 공사중지명령의 철회를 신청하였으나 행정청이 이에 대하여 아무런 응답을 하지 않고 있는 경우, 그러한 행정청의 부작위의 위법 여부(적극)

<판결요지>

- 행정청이 행한 공사중지명령의 상대방은 그 명령 이후에 그 원인사유가 소멸하였음을 들어 행정청에게 공사중지명령의 철회를 요구할 수 있는 조리상의 신청권이 있다 할 것이고, 상대방으로부터 그 신청을 받은 행정청으로서는 상당한 기간 내에 그 신청을 인용하는 적극적 처분을 하거나 각하 또는 기각하는 등의 소극적 처분을 하여야 할 법률상의 응답의무가 있다고 할 것이며, 행정청이 상대방의 신청에 대하여 아무런 적극적 또는 소극적 처분을 하지 않고 있는 이상 행정청의 부작위는 그 자체로 위법하다고 할 것이고, 구체적으로 그 신청이 인용될 수 있는지 여부는 소극적 처분에 대한 항고소송의 본안에서 판단하여야 할 사항이라고 할 것이다.

<선정이유>

- 행정청이 행한 공사중지명령의 상대방은 그 명령 이후에 그 원인사유가 소멸하였음을 들어 행정청에게 공사중지명령의 철회를 요구할 수 있는 조리상의 신청권이 있다고 한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

### 322. 대상적격 (19) : 폐기물처리업 부정적 통보

“대법원 1998. 4. 28. 선고 97누21086 판결”

#### <주제>

- 폐기물처리업 부정적 통보의 처분성

#### <쟁점>

- 폐기물관리법 관계 법령에 의한 폐기물처리업 허가권자의 부정적 통보가 행정처분에 해당하는지 여부(적극)

#### <판결요지>

- [1] “폐기물관리법 제26조 제1항”, “제2항” 및 “같은 법 시행규칙 제17조 제1항” 내지 “제5항”의 규정에 비추어 보면 폐기물처리업의 허가에 앞서 사업계획서에 대한 적정·부정적 통보 제도를 두고 있는 것은 폐기물처리업을 하고자 하는 자가 스스로 시설 등을 설치하여 허가신청을 하였다가 허가단계에서 그 사업계획이 부적정하다고 판명되어 불허가되면 허가신청인이 막대한 경제적·시간적 손실을 입게 되므로, 이를 방지하는 동시에 허가관청으로 하여금 미리 사업계획서를 심사하여 그 적정·부정적 통보 처분을 하도록 하고, 나중에 허가단계에서는 나머지 허가요건만을 심사하여 신속하게 허가업무를 처리하는데 그 취지가 있다.

- [2] “폐기물관리법” 관계 법령의 규정에 의하면 폐기물처리업의 허가를 받기 위하여는 먼저 사업계획서를 제출하여 허가권자로부터 사업계획에 대한 적정통보를 받아야 하고, 그 적정통보를 받은 자만이 일정기간 내에 시설, 장비, 기술능력, 자본금을 갖추어 허가신청을 할 수 있으므로, 결국 부정적 통보는 허가신청 자체를 제한하는 등 개인의 권리 내지 법률상의 이익을 개별적이고 구체적으로 규제하고 있어 행정처분에 해당한다.

#### <선정이유>

- 폐기물처리업 허가에 앞선 중간단계의 행위(사업계획서에 대한 부정적 통보)를 처분으로 인정한 판결

### <제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

### 323. 대상적격 (20) : 행정처분의 반복 통지

“대법원 2005. 10. 28. 선고 2003두14550 판결”

#### <주제>

- 행정처분을 반복 통지한 경우 처분성

#### <쟁점>

- 지방병무청장이 복무기관을 정하여 공익근무요원 소집통지를 한 후 소집대상자의 원에 의하여 또는 직권으로 그 기일을 연기한 다음 다시 한 공익근무요원 소집통지가 항고소송의 대상이 되는 독립된 행정처분인지 여부(소극)

#### <판결요지>

- 지방병무청장이 보충역 편입처분을 받은 자에 대하여 복무기관을 정하여 공익근무요원 소집통지를 한 이상 그것으로써 공익근무요원으로서의 복무를 명하는 병역법상의 공익근무요원 소집처분이 있었다고 할 것이고, 그 후 지방병무청장이 공익근무요원 소집대상자의 원에 의하여 또는 직권으로 그 기일을 연기한 다음 다시 공익근무요원 소집통지를 하였다 하더라도 이는 최초의 공익근무요원 소집통지에 관하여 다시 의무이행기일을 정하여 알려주는 연기통지에 불과한 것이므로, 이는 항고소송의 대상이 되는 독립한 행정처분으로 볼 수 없다.

#### <선정이유>

- 공익근무요원 소집처분 이후 다시 한 소집통지가 의무이행기일을 정하여 알려주는 연기통지에 불과하여 독립한 행정처분으로 볼 수 없다는 판결

### <제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

### 324. 대상적격 (21) : 감액처분이 있는 경우 항고소송의 대상

“대법원 2008. 2. 15. 선고 2006두3957 판결”

#### <주제>

- 감액처분이 있는 경우 항고소송의 대상

#### <쟁점>

- 행정청이 과징금 부과처분을 하였다가 감액처분을 한 것에 대하여 그 감액처분으로도 아직 취소되지 않고 남아 있는 부분이 위법하다고 하여 다투는 경우 항고소송의 대상

#### <판결요지>

- 과징금 부과처분에서 행정청이 납부의무자에 대하여 부과처분을 한 후 그 부과처분의 하자를 이유로 과징금의 액수를 감액하는 경우에 그 감액처분은 감액된 과징금 부분에 관하여만 법적 효과가 미치는 것으로서 처음의 부과처분과 별개 독립의 과징금 부과처분이 아니라 그 실질은 당초 부과처분의 변경이고, 그에 의하여 과징금의 일부취소라는 납부의무자에게 유리한 결과를 가져오는 처분이므로 처음의 부과처분이 전부 실효되는 것은 아니며, 그 감액처분으로도 아직 취소되지 않고 남아 있는 부분이 위법하다고 하여 다투는 경우 항고소송의 대상은 처음의 부과처분 중 감액처분에 의하여 취소되지 않고 남은 부분이고 감액처분이 항고소송의 대상이 되는 것은 아니다.

<선행이유>

- 원처분과 감액처분의 관계 및 항고소송의 대상에 관한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

325. 대상적격 (22) : 증액처분이 있는 경우 항고소송의 대상

“대법원 2009. 5. 14. 선고 2006두17390 판결”

<주제>

- 증액처분이 있는 경우 항고소송의 대상

<쟁점>

- “국세기본법 제22조의2”의 시행 이후 당초 과세처분에 대한 증액경정처분이 있는 경우 항고소송의 심판대상(=증액경정처분) 및 그 항고소송에서 당초 신고나 결정에 대한 위법사유를 함께 주장할 수 있는지 여부(적극)

<판결요지>

- “국세기본법 제22조의2”의 시행 이후에도 증액경정처분이 있는 경우, 당초 신고나 결정은 증액경정처분에 흡수됨으로써 독립한 존재가치를 잃게 된다고 보아야 하므로, 원칙적으로는 당초 신고나 결정에 대한 불복기간의 경과 여부 등에 관계없이 증액경정처분만이 항고소송의 심판대상이 되고, 납세의무자는 그 항고소송에서 당초 신고나 결정에 대한 위법사유도 함께 주장할 수 있다고 해석함이 타당하다.

<선행이유>

- 과세처분과 증액경정처분의 관계 및 항고소송의 대상에 관한 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

326. 대상적격 (23) : 변경처분이 있는 경우 항고소송의 대상

“대법원 2015. 11. 19. 선고 2015두295 전원합의체 판결”

<주제>

- 선행처분을 변경하는 후속처분이 있는 경우 항고소송의 대상

<쟁점>

- 기존의 행정처분을 변경하는 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 그 부분이 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우, 종전처분이 항고소송의 대상이 되는지 여부(적극) 및 종전처분을 변경하는 내용의 후속처분이 있는 경우 법원이 항고소송의 대상이 되는 행정처분을 확정하는 방법

<판결요지>

- [1] 기존의 행정처분을 변경하는 내용의 행정처분이 뒤따르는 경우, 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되지만, 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 추가·철회·변경된 부분이 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우(가분적인 경우)에는, 후속처분에도 불구하고 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다. 따라서 종전처분을 변경하는 내용의 후속처분이 있는 경우 법원으로서, 후속처분의 내용이 종전처분 전체를 대체하거나 주요 부분을 실질적으로 변경하는 것인지, 후속처분에서 추가·철회·변경된 부분의 내용과 성질상 나머지 부분과 가분적인지 등을 살펴 항고소송의 대상이 되는 행정처분을 확정하여야 한다.

- [2] 피고가 대형마트 및 준대규모점포의 영업제한 시간을 오전 0시부터 오전 8시까지로 정하고 매월 둘째 주와 넷째 주 일요일을 의무휴업일로 지정하는 처분의 취소를 구하는 소송의 계속 중에 영업시간 제한 부분의 시간을 오전 0시부터 오전 10시까지로 변경하되, 의무휴업일은 종전과 동일하게 유지하는 내용의 후속처분을 한 경우, 후속처분은 종전처분 전체를 대체하거나 그 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용이 아니라, 의무휴업일 지정 부분을 그대로 유지한 채 영업시간 제한 부분만을 일부 변경하는 것으로서, 후속처분에 따라 추가된 영업시간 제한 부분은 그 성질상 종전처분과 가분적인 것으로 여겨진다. 따라서 후속처분으로 종전처분이 소멸하였다고 볼 수는 없고, 종전처분과 그 유효를 전제로 한 후속처분이 병존하면서 위 원고들에 대한 규제 내용을 형성한다고 할 것이다.

<선행이유>

- 기존의 행정처분을 변경하는 내용의 행정처분이 뒤따르는 경우, 후속처분이 종전처분을 완전히 대체하는 것이거나 주요 부분을 실질적으로 변경하는 내용인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 종전처분은 효력을 상실하고 후속처분만이 항고소송의 대상이 되지만, 후속처분의 내용이 종전처분의 유효를 전제로 내용 중 일부만을 추가·철회·변경하는 것이고 추가·철회·변경된 부분이 내용과 성질상 나머지 부분과 불가분적인 것이 아닌 경우에는, 종전처분이 여전히 항고소송의 대상이 된다는 법리를 제시하고 있는 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

327. 대상적격 (24) : 선행처분이 후행처분에 흡수되는 경우

**“대법원 2015. 2. 12. 선고 2013두987 판결”**

**<주제>**

- 과징금 부과처분과 과징금 감면처분이 있는 경우 항고소송의 대상

**<쟁점>**

- 공정거래위원회가 부당한 공동행위를 한 사업자에게 과징금 부과처분(선행처분)을 한 뒤, 다시 자진신고 등을 이유로 과징금 감면처분(후행처분)을 한 경우, 선행처분의 취소를 구하는 소가 적법한지 여부(소극)

**<판결요지>**

- 공정거래위원회가 부당한 공동행위를 행한 사업자로서 "구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제22조의2"에서 정한 자진신고자나 조사협조자에 대하여 과징금 부과처분(이하 '선행처분'이라 한다)을 한 뒤, "독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제35조 제3항"에 따라 다시 자진신고자 등에 대한 사건을 분리하여 자진신고 등을 이유로 한 과징금 감면처분(이하 '후행처분'이라 한다)을 하였다면, 후행처분은 자진신고 감면까지 포함하여 처분 상대방이 실제로 납부하여야 할 최종적인 과징금액을 결정하는 종국적 처분이고, 선행처분은 이러한 종국적 처분을 예정하고 있는 일종의 잠정적 처분으로서 후행처분이 있을 경우 선행처분은 후행처분에 흡수되어 소멸한다. 따라서 위와 같은 경우에 선행처분의 취소를 구하는 소는 이미 효력을 잃은 처분의 취소를 구하는 것으로 부적법하다.

**<선정이유>**

- 공정거래위원회가 과징금 부과처분(선행처분)과 과징금 감면처분(후행처분)을 연달아 하는 경우, 후행처분이 종국적 처분이고 선행처분은 후행처분을 예정한 잠정적 처분으로서 후행처분에 흡수되어 소멸한다는 법리를 제시한 판결

**<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>**

**328. 대상적격 (25) : 입찰참가자격 제한**

**“대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두18964 판결”**

**<주제>**

- 공기업 · 준정부기관이 행하는 입찰참가자격 제한의 처분성

**<쟁점>**

- 공기업 · 준정부기관이 행하는 입찰참가자격 제한의 처분성을 인정하는 전제에서 처분의 위법성을 판단한 사례

**<판결요지>**

- "공공기관의 운영에 관한 법률 제39조 제2항", "제3항"에 따라 입찰참가자격 제한기준을 정하고 있는 "구 공기업 · 준정부기관 계약사무규칙 제15조 제2항", "국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제76조 제1항 [별표 2], 제3항" 등은 비록 부령의 형식으로 되어 있으나 규정의 성질과 내용이 공기업 · 준정부기관(이하 '행정청'이라 한다)이 행하는 입찰참가자격 제한처분에 관한 행정청 내부의 재량준칙을 정한 것에 지나지 아니하여 대외적으로 국민이나 법원을 기속하는 효력이 없으므로, 입찰참가자격 제한처분이 적법한지 여부는 이러한 규칙에서 정한 기준에 적합한지 여부만에 따라 판단할 것이 아니라 공공기관의 운영에 관한 법률상 입찰참가자격 제한처분에 관한 규정과 그 취지에 적합한지 여부에 따라 판단하여야 한다. 다만 그 재량준칙이 정한 바에 따라 되풀이 시행되어 행정관행이 이루어지게 되면 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙에 따라 행정청은 상대방에 대한 관계에서 그 규칙에 따라야 할 자기기속을 받게 되므로, 이러한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그에 반하는 처분은 평등의 원칙이나 신뢰보호의 원칙에 어긋나 재량권을 일탈 · 남용한 위법한 처분이 된다.

**<선정이유>**

- 공기업 · 준정부기관이 행하는 입찰참가자격 제한의 처분성을 인정하는 전제에서 처분의 위법성을 판단한 판결

**<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>**

**329. 대상적격 (26) : 거래정지조치**

**“대법원 2018. 11. 29. 선고 2015두52395 판결”**

**<주제>**

- 조달청이 계약상대방에 대하여 하는 나라장터 종합쇼핑몰 거래정지조치의 처분성

**<쟁점>**

- 갑 주식회사가 조달청과 물품구매계약을 체결하고 국가종합전자조달시스템인 나라장터 종합쇼핑몰 인터넷 홈페이지를 통해 요구받은 제품을 수요기관에 납품하였는데, 조달청이 계약이행내역 점검 결과 일부 제품이 계약 규격과 다르다는 이유로 물품구매계약 추가특수조건 규정에 따라 갑 회사에 대하여 6개월의 나라장터 종합쇼핑몰 거래정지 조치를 한 사안에서, 위 거래정지 조치는 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는데도 이와 달리 보아 소를 각하한 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다고 한 사례

**<판결요지>**

- 갑 주식회사가 조달청과 물품구매계약을 체결하고 국가종합전자조달시스템인 나라장터 종합쇼핑몰 인터넷 홈페이지를 통해 요구받은 제품을 수요기관에 납품하였는데, 조달청이 계약이행내역 점검 결과 일부 제품이 계약 규격과 다르다는 이유로 물품구매계약 추가특수조건 규정에 따라 갑 회사에

대하여 6개월의 나라장터 종합쇼핑몰 거래정지 조치를 한 사안에서, 조달청이 계약상대자에 대하여 나라장터 종합쇼핑몰에서의 거래를 일정기간 정지하는 조치는 "전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률", "조달사업에 관한 법률" 등에 의하여 보호되는 계약상대자의 직접적이고 구체적인 법률상 이익인 나라장터를 통하여 수요기관의 전자입찰에 참가하거나 나라장터 종합쇼핑몰에서 등록된 물품을 수요기관에 직접 판매할 수 있는 지위를 직접 제한하거나 침해하는 행위에 해당하는 점 등을 종합하면, 위 거래정지 조치는 비록 추가특수조건이라는 사법상 계약에 근거한 것이지만 행정청인 조달청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사로서 그 상대방인 갑 회사의 권리·의무에 직접 영향을 미치므로 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하고, 다만 추가특수조건에서 정한 제재조치의 발동요건조차 갖추지 못한 경우에는 위 거래정지 조치가 위법하므로 갑 회사의 행위가 추가특수조건에서 정한 거래정지 조치의 사유에 해당하는지, 추가특수조건의 내용이나 그에 기한 거래정지 조치가 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 등을 위반하였거나 평등원칙, 비례원칙, 신뢰보호 원칙 등을 위반하였는지 등에 관하여 나아가 살펴봐야 하는데도, 위 거래정지 조치가 사법상 계약에 근거한 의사표시에 불과하고 항고소송의 대상이 되는 행정처분으로 볼 수 없다고 판단하여 소를 각하한 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다고 한 사례

<선정이유>

- 조달계약은 사법상 계약이고 이 사안에서 추가특수조건은 사법상 계약에 근거한 것이지만, 추가특수조건에 따라 행정청이 상대방에 대해 거래정지를 한 것은 계약체결을 거절하는 사법상 의사표시가 아니라 행정처분이라는 것을 밝힌 것으로서, 사법상 계약관계에서 상대방에 대한 행정청의 일정한 의사표시가 행정처분이 될 수 있음을 보여주는 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

330. 대상적격 (27) : 산업단지관리공단의 입주계약 취소

“대법원 2017. 6. 15. 선고 2014두46843 판결”

<주제>

- 산업단지관리공단이 하는 입주계약 취소의 처분성

<쟁점>

- 산업단지관리공단이 하는 “구 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제38조 제2항”에 따른 입주변경계약의 취소가 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하는지 여부(적극)

<판결요지>

- “구 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제13조 제1항” 등의 규정들에서 알 수 있는 산업단지관리공단의 지위, 입주계약 및 변경계약의 효과, 입주계약 및 변경계약 체결 의무와 그 의무를 불이행한 경우의 형사적 내지 행정적 제재, 입주계약해지의 절차, 해지통보에 수반되는 법적 의무 및 그 의무를 불이행한 경우의 형사적 내지 행정적 제재 등을 종합적으로 고려하면, 입주변경계약취소는 행정청인 관리권자로부터 관리업무를 위탁받은 산업단지관리공단이 우월적 지위에서 입주기업체들에게 일정한 법률상 효과를 발생하게 하는 것으로서 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당한다.

<선정이유>

- 산업단지입주계약은 관련 법상 계약이지만, 계약취소의 절차와 이후의 계약상대방에게 주어지는 의무 및 불이행시 제재 등을 종합해 보면 입주계약의 취소는 행정처분이라는 것으로서, 행정작용이 행정처분인지 여부는 관련법의 규정에 따라 상대방에 미치는 법적 효과 등을 종합적으로 고찰하여 판단하여야 함을 밝힌 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

331. 대상적격 (28) : 보조금 지급신청에 대한 경기도지사의 통보

“대법원 2023. 2. 23. 선고 2021두44548 판결”

<주제>

- 보조금 지급신청에 대한 행정청의 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지 여부(소극)

<쟁점>

- 여객자동차 운송사업자 갑 주식회사가 시내버스 노선을 운행하면서 환승요금할인, 청소년요금할인을 시행한 데에 따른 손실을 보전해 달라며 경기도지사와 광명시장에게 보조금 지급신청을 하였으나, 경기도지사가 갑 회사와 광명시장에게 갑 회사의 보조금 지급신청을 받아들일 수 없음은 기존에 회신한 바와 같고, 광명시에서는 적의 조치하여 주기 바란다.는 취지로 통보한 사안에서, 경기도지사의 위 통보는 갑 회사의 권리·의무에 직접적인 영향을 주는 것이라고 할 수 없어 항고소송의 대상이 되는 처분으로 볼 수 없다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 항고소송의 대상인 처분이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용(“행정소송법 제2조 제1항 제1호”)을 말한다. 행정청의 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지는 추상적·일반적으로 결정할 수 없고, 구체적인 경우에 관련 법령의 내용과 취지, 그 행위의 주체·내용·형식·절차, 그 행위와 상대방 등 이해관계인이 입는 불이익 사이의 실질적 견련성, 법치행정의 원리와 그 행위에 관련된 행정청이나 이해관계인의 태도 등을 고려하여 개별적으로 결정하여야 한다.

- [2] 여객자동차 운송사업자 갑 주식회사가 시내버스 노선을 운행하면서 환승요금할인 및 청소년요금할인을 시행한 데에 따른 손실을 보전해 달라며 경기도지사와 광명시장에게 보조금 지급신청을 하였으나, 경기도지사가 갑 회사와 광명시장에게 갑 회사의 보조금 지급신청을 받아들일 수 없음은 기존에 회신한 바와 같고, 광명시에서는 적의 조치하여 주기 바란다.는 취지로 통보한 사안에서, 경기도 여객자동차 운수사업 관리 조례 제15조에 따른 보조금 지급사무는 광명시장에게 위임되었으므로 위 신청에 대한 응답은 광명시장의 해야 하고, 경기도지사는 갑 회사의 보조금 지급신청에 대한 처분권한

자가 아니며, 위 통보는 경기도지사가 갑 회사의 보조금 신청에 대한 최종적인 결정을 통보하는 것이라기보다는 광명시장의 사무에 대한 지도·감독권자로서 갑 회사에 대하여는 보조금 지급신청에 대한 의견을 표명함과 아울러 광명시장에 대하여는 경기도지사의 의견에 따라 갑 회사의 보조금 신청을 받아들일지를 심사하여 갑 회사에 통지할 것을 촉구하는 내용으로 보는 것이 타당하므로, 경기도지사의 위 통보는 갑 회사의 권리·의무에 직접적인 영향을 주는 것이라고 할 수 없어 항고소송의 대상이 되는 처분으로 볼 수 없다고 한 사례

<선정이유>

- 여객자동차 운송사업자 갑 주식회사가 손실을 보전해 달라며 경기도지사와 광명시장에게 보조금지급신청을 한 사안에서 경기도지사가 갑 회사와 광명시장에게 갑 회사의 보조금 지급신청을 받아들일 수 없음은 기존에 회신한 바와 같고, 광명시에서는 적의 조치하여 주기 바란다.는 취지로 한 경기도지사의 통보는 갑 회사의 권리·의무에 직접적인 영향을 주는 것이라고 아니어서 행정처분에 해당하지 않는다고 밝힌 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제02절 처분>

332. 대상적격 (29) : 감사원의 징계요구

“대법원 2016. 12. 27. 선고 2014두5637 판결”

<주제>

- 감사원의 징계요구 및 재심의결정이 항고소송의 대상이 되는지 여부(소극)

<쟁점>

- 갑 시장이 감사원으로부터 “감사원법 제32조”에 따라 을에 대하여 징계의 종류를 정식으로 정한 징계 요구를 받게 되자 감사원에 징계 요구에 대한 재심을 청구하였고, 감사원이 재심의청구를 기각하자 을이 감사원의 징계 요구와 그에 대한 재심의결정의 취소를 구하고 갑 시장이 감사원의 재심의 결정 취소를 구하는 소를 제기한 사안에서, 감사원의 징계 요구와 재심의결정이 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 할 수 없고, 갑 시장이 제기한 소송이 기관소송으로서 “감사원법 제40조 제2항”에 따라 허용된다고 볼 수 없다고 한 사례

<판결요지>

- 갑 시장이 감사원으로부터 “감사원법 제32조”에 따라 을에 대하여 징계의 종류를 정식으로 정한 징계 요구를 받게 되자 “감사원법 제36조 제2항”에 따라 감사원에 징계 요구에 대한 재심을 청구하였고, 감사원이 재심의청구를 기각하자 을이 감사원의 징계 요구와 그에 대한 재심의결정의 취소를 구하고 갑 시장이 감사원의 재심의결정 취소를 구하는 소를 제기한 사안에서, 징계 요구는 징계 요구를 받은 기관의 장이 요구받은 내용대로 처분하지 않더라도 불이익을 받는 규정도 없고, 징계 요구 내용대로 효과가 발생하는 것도 아니며, 징계 요구에 의하여 행정청이 일정한 행정처분을 하였을 때 비로소 이해관계인의 권리관계에 영향을 미칠 뿐, 징계 요구 자체만으로는 징계 요구 대상 공무원의 권리·의무에 직접적인 변동을 초래하지도 아니하므로, 행정청 사이의 내부적인 의사결정의 경로로서 징계 요구, 징계 절차 회부, 징계로 이어지는 과정에서의 중간처분에 불과하여, 감사원의 징계 요구와 재심의결정이 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 할 수 없고, “감사원법 제40조 제2항”을 갑 시장에게 감사원을 상대로 한 기관소송을 허용하는 규정으로 볼 수는 없고 그 밖에 행정소송법을 비롯한 어떠한 법률에도 갑 시장에게 감사원의 재심의 판결에 대하여 기관소송을 허용하는 규정을 두고 있지 않으므로, 갑 시장이 제기한 소송이 기관소송으로서 “감사원법 제40조 제2항”에 따라 허용된다고 볼 수 없다고 한 사례

<선정이유>

- 감사원의 징계요구는 소속 공무원의 측면에서는 아직 시장의 징계가 이루어지지 않은 상태의 행정청간의 중간적·내부적 행위고, 시장의 측면에서는 감사원의 징계요구가 구속력이 없으므로 처분성이 없으며, 나아가 “감사원법 제40조 제2항”의 재심의 판결에 대한 행정소송에 관한 규정이 기관소송에 관한 규정도 아니므로 시장의 소는 부적법하다는 판결로서 처분성의 개념요소 중 대외적으로 권리·의무에 영향을 미쳐야 한다는 것의 의미와 기관소송의 대상에 대해 밝힌 판결

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

333. 대상적격 (30) : 행정심판의 재결

“대법원 1997. 12. 23. 선고 96누10911 판결”

<주제>

- 재결에 고유한 하자, 인용재결의 취소를 구하는 소송에서 심리·판단의 범위

<쟁점>

- [1] 제3자료를 수반하는 행정행위에 대하여 제3자가 행정심판을 제기하여 그 처분이 취소되는 재결이 있자 그 원처분의 상대방이 위 재결에 대한 취소소송을 제기한 경우, 위 소송이 재결에 고유한 하자를 주장하는 것이 되는지 여부(적극)
- [2] 인용재결청 스스로가 직접 당해 사업계획승인처분을 취소하는 형성적 재결을 한 경우, 그 재결 외에 그에 따른 별도의 처분이 없기 때문에 재결 자체를 쟁송의 대상으로 할 수 있다고 본 사례
- [3] 인용재결의 취소를 구하는 소송의 심리·판단의 범위

<판결요지>

- [1] 이른바 복효적 행정행위, 특히 제3자료를 수반하는 행정행위에 대한 행정심판청구에 있어서 그 청구를 인용하는 내용의 재결로 인하여 비로소 권리이익을 침해받게 되는 자는 그 인용재결에 대하여 다툴 필요가 있고, 그 인용재결은 원처분과 내용을 달리하는 것이므로 그 인용재결의 취소를 구하는 것은 원처분에는 없는 재결에 고유한 하자를 주장하는 셈이어서 당연히 항고소송의 대상이 된다.

- [2] 재결청인 문화체육부장관 스스로가 직접 사업계획승인처분을 취소하는 형성적 재결을 한 경우에는 그 재결 외에 그에 따른 행정청의 별도의 처분이 있지 않기 때문에 재결 자체를 쟁송의 대상으로 할 수밖에 없다고 본 사례

- [3] 인용재결의 취소를 구하는 당해 소송은 그 인용재결의 당부를 그 심판대상으로 하고 있고, 그 점을 가리기 위하여는 행정심판청구인들의 심판청구원인 사유에 대한 재결청의 판단에 관하여도 그 당부를 심리·판단하여야 할 것이므로, 원심으로서의 재결청이 원처분의 취소 근거로 내세운 판단사유의 당부뿐만 아니라 재결청이 심판청구인의 심판청구원인 사유를 배척한 판단 부분이 정당한가도 심리·판단하여야 한다.

#### <선정이유>

- 원처분주의의 예외로서 재결이 대상처분이 되기 위해서는 재결 자체에 고유한 위법이 있어야 하는데, 제3자가 제기한 행정심판에서 청구가 인용된 경우 원처분의 상대방은 재결로 인해 비로소 권익이 침해되었으므로 재결자체에 고유한 위법이 있는 경우에 해당함을 밝힌 판결

### <제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

#### 335. 원고적격 (1) : 법률상 이익의 의미

“대법원 1999. 12. 7. 선고 97누12556 판결”

##### <주제>

- 원고적격의 인정요건인 법률상 이익의 의미

##### <쟁점>

- [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자가 행정처분의 취소 등을 구할 수 있는 요건으로서 법률상 이익의 의미  
- [2] 갑이 을 소유의 도로를 공로에 이르는 유일한 통로로 이용하였으나 갑 소유의 대지에 연결하여 새로운 공로가 개설되어 그 쪽으로 출입문을 내어 바로 새로운 공로에 이를 수 있게 된 경우, 갑이 을 소유의 도로에 대한 도로폐지허가처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는지 여부(소극)

##### <판결요지>

- [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자라도 당해 행정처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있는 경우에는 원고적격이 인정된다고 할 것이나, 여기서 말하는 법률상의 이익은 당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우를 말하고 다만 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 추상적, 평균적, 일반적 이익과 같이 간접적이거나 사실적, 경제적 이해관계를 가지는 데 불과한 경우는 여기에 포함되지 않는다.  
- [2] 갑이 을 소유의 도로를 공로에 이르는 유일한 통로로 이용하였으나 갑 소유의 대지에 연결하여 새로운 공로가 개설되어 그 쪽으로 출입문을 내어 바로 새로운 공로에 이를 수 있게 된 경우, 을의 신청에 따라 관할 행정청이 을 소유의 도로에 대하여 한 도로폐지허가처분으로 인하여 을 소유의 도로가 “구 건축법 제2조 제11호 (나)목” 소정의 도로에 해당하지 않게 되었다고 하더라도 주위토지소유자인 갑의 대지 및 그 지상의 주택은 “같은 법 제2조 제11호” 소정의 새로 개설된 도로에 접하고 있으므로 여전히 “같은 법 제33조” 소정의 접도의무가 충족된다고 할 것이고, 도로폐지허가처분 이전에 을 소유의 도로에 대하여 “같은 법 제34조, 제36조, 제37조”가 적용됨으로써 갑이 갖고 있던 통행의 이익이 도로폐지허가처분에 의하여 상실되었다고 하더라도 이러한 갑의 폐지된 도로에 대한 통행의 이익은 같은 법에 의한 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 추상적, 평균적, 일반적 이익과 같이 간접적이거나 사실적, 경제적 이익에 불과하고 이를 같은 법에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익에 해당한다고 보기도 어렵고, 또한 갑이 종전에 갖고 있던 폐지된 도로에 대한 주위토지통행권은 새로운 도로가 개설됨으로써 도로폐지허가처분 당시에는 이미 소멸하였을 뿐만 아니라, 도로폐지허가처분 당시에는 폐지된 도로의 소유자인 을에게 폐지된 도로에 대한 독점적·배타적 사용수익권이 있다고 할 것이어서 그 제한을 전제로 한 갑의 폐지된 도로에 대한 무상통행권도 인정되지 않는다고 할 것이므로, 도로폐지허가처분으로 인하여 갑이 폐지된 도로에 대한 사법상의 통행권을 침해받았다고 볼 수도 없다 할 것이어서 갑에게는 도로폐지허가처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없다.

#### <선정이유>

- 기존 도로를 폐지하고 새로운 도로를 개설하여 통로가 새로이 확보된 경우에, 기존 도로를 이용함으로써 얻은 이익은 반사적 이익에 불과하므로 기존 도로폐지허가처분의 취소를 구하는 소는 법률상 이익이 없다는 점을 밝힌 판결

### <제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

#### 336. 원고적격 (2) : 영업자소송의 원고적격

“대법원 2002. 10. 25. 선고 2001두4450 판결”

##### <주제>

- 영업자소송에서 원고적격

##### <쟁점>

- [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자가 행정처분의 취소 등을 구할 수 있는 요건으로서 법률상 보호되는 이익의 의미  
- [2] 기존의 업자가 경쟁자에 대한 면허나 인·허가 등 수익적 행정처분의 취소를 구할 당사자적격이 있는 경우  
- [3] 시외버스운송사업계획변경인가처분으로 시외버스 운행노선 중 일부가 기존의 시내버스 운행노선과 중복하게 되어 기존 시내버스사업자의 수익 감소가 예상되는 경우, 기존의 시내버스운송사업자에게 위 처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있는지 여부(적극)

##### <판결요지>

- [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자라도 하더라도 당해 행정처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당한 경우에는 취소소송을 제기하여 그 당부의 판단을 받을 자격이 있다 할 것이나, 여기에서 말하는 법률상 보호되는 이익이란 당해 행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고

구체적인 이익을 말하고 제3자가 당해 행정처분과 관련하여 간접적이거나 사실적·경제적인 이해관계를 가지는 데 불과한 경우는 여기에 포함되지 아니한다.

- [2] 일반적으로 면허나 인·허가 등의 수익적 행정처분의 근거가 되는 법률이 해당 업자들 사이의 과당경쟁으로 인한 경영의 불합리를 방지하는 것도 그 목적으로 하고 있는 경우, 다른 업자에 대한 면허나 인·허가 등의 수익적 행정처분에 대하여 미리 같은 종류의 면허나 인·허가 등의 수익적 행정처분을 받아 영업을 하고 있는 기존의 업자는 경업자에 대하여 이루어진 면허나 인·허가 등 행정처분의 상대방이 아니라 하더라도 당해 행정처분의 취소를 구할 당사자적격이 있다.

- [3] "구 여객자동차운수사업법 제6조 제1항 제1호"에서 사업계획이 당해 노선 또는 사업구역의 수송수요와 수송력공급에 적합할 것을 여객자동차운송사업의 면허기준으로 정한 것은 여객자동차운송사업에 관한 질서를 확립하고 여객자동차운송사업의 종합적인 발달을 도모하여 공공의 복리를 증진함과 동시에 업자 간의 경쟁으로 인한 경영의 불합리를 미리 방지하자는 데 그 목적이 있다할 것이고, 한편 "같은 법 제3조 제1항 제1호"와 "같은 법 시행령 제3조 제1호", "같은 법 시행규칙 제7조 제3항", "제4항" 등의 각 규정을 종합하여 보면, 시내버스운송사업과 시외버스운송사업은 다 같이 운행계통을 정하고 여객을 운송하는 노선여객자동차운송사업에 속하므로, 위 두 운송사업이 면허기준, 준수하여야 할 사항, 중간경유지, 기점과 종점, 운행방법, 이용요금 등에서 달리 규율된다는 사정만으로 본질적인 차이가 있다고 할 수는 없으며, 시외버스운송사업계획변경인가처분으로 인하여 기존의 시내버스운송사업자의 노선 및 운행계통과 시외버스운송사업자들의 그것들이 일부 중복되게 되고 기존업자의 수익감소가 예상된다면, 기존의 시내버스운송사업자와 시외버스운송사업자들은 경업관계에 있는 것으로 봄이 상당하다 할 것이어서 기존의 시내버스운송사업자에게 시외버스운송사업계획변경인가처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있다.

#### <선정이유>

- 근거법령의 해석과 경업관계의 확인을 통해 경업자소송의 원고적격을 인정한 판결

### <제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

#### 337. 원고적격 (3) : 경원자소송의 원고적격

“대법원 2009. 12. 10. 선고 2009두8359 판결”

##### <주제>

- 경원자소송에서 원고적격, 사정판결

##### <쟁점>

- [1] 제3자에게 경원자(競願者)에 대한 수익적 행정처분의 취소를 구할 당사자적격이 있는 경우
- [2] 사정판결을 하기 위한 요건인 현저히 공공복리에 적합하지 아니한가 여부의 판단 방법 및 사정판결제도의 위헌 여부(소극)

##### <판결요지>

- [1] 인·허가 등의 수익적 행정처분을 신청한 수인이 서로 경쟁관계에 있어서 일방에 대한 허가등의 처분이 타방에 대한 불허가 등으로 귀결될 수밖에 없는 때 허가 등의 처분을 받지 못한 자는 비록 경원자에 대하여 이루어진 허가 등 처분의 상대방이 아니라 하더라도 당해 처분의 취소를 구할 원고적격이 있다. 다만, 명백한 법적 장애로 인하여 원고 자신의 신청이 인용될 가능성이 처음부터 배제되어 있는 경우에는 당해 처분의 취소를 구할 정당한 이익이 없다.

- [2] 원고를 포함하여 법학전문대학원 설치인가 신청을 한 41개 대학들은 2,000명이라는 총 입학정원을 두고 그 설치인가 여부 및 개별 입학정원의 배정에 관하여 서로 경쟁관계에 있고 이 사건 각 처분이 취소될 경우 원고의 신청이 인용될 가능성도 배제할 수 없으므로, 원고에게 법학전문대학원 설치인가처분의 취소 등을 원고적격이 있다고 판단한 사례

##### <선정이유>

- 수인이 서로 경쟁관계에 있고 일방에 대한 허가 등 처분이 타방에 대한 불허가로 귀결될 수 밖에 없는 경우, 타방은 일방에 대한 허가처분의 취소를 구할 원고적격이 있다는 점을 밝힌 판결

### <제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

#### 338. 원고적격 (4) : 이웃 주민(隣人)의 원고적격

“대법원 1995. 9. 26. 선고 94누14544 판결”

##### <주제>

- 법률상 이익의 존부를 판단하기 위한 처분의 근거 법규의 의미

##### <쟁점>

- [1] 제3자가 행정처분의 취소를 구할 원고적격이 있는 경우
- [2] 제3자에게 상수원보호구역변경처분의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 한 사례
- [3] 제3자에게 도시계획결정처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 한 사례

##### <판결요지>

- [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자라도 당해 행정처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있는 경우에는 원고적격이 인정되는데, 여기서 말하는 법률상의 이익은 당해 처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우를 말하고, 다만 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 추상적, 평균적, 일반적인 이익과 같이 간접적이거나 사실적, 경제적 이해관계를 가지는 데 불과한 경우는 여기에 포함되지 않는다.

- [2] 상수원보호구역 설정의 근거가 되는 "수도법 제5조 제1항" 및 "동 시행령 제7조 제1항"이 보호하고자 하는 것은 상수원의 확보와 수질보전일 뿐이고, 그 상수원에서 급수를 받고 있는 지역주민들이 가지는 상수원의 오염을 막아 양질의 급수를 받을 이익은 직접적이고 구체적으로는 보호하고 있지 않음에 명백하여 위 지역주민들이 가지는 이익은 상수원의 확보와 수질보호라는 공공의 이익이 달성됨에 따라 반사적으로 얻게 되는 이익에 불과하므로 지역주민들에 불과한 원고들에게는 위 상수원보호구역변경처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 없다.

- [3] "도시계획법 제12조 제3항"의 위임에 따라 제정된 도시계획시설기준에관한규칙 제125조 제1항이 화장장의 구조 및 설치에 관하여는 "매장및묘지등에관한법률"이 정하는 바에 의한다고 규정하고 있어, 도시계획의 내용이 화장장의 설치에 관한 것일 때에는 "도시계획법 제12조" 뿐만 아니라 "매장및묘지등에관한법률" 및 "같은법 시행령" 역시 그 근거 법률이 된다고 보아야 할 것이므로, "같은법 시행령 제4조 제2호"가 공설화장장은 20호 이상의 인가가 밀집한 지역, 학교 또는 공중이 수시 집합하는 시설 또는 장소로부터 1,000m 이상 떨어진 곳에 설치하도록 제한을 가하고, "같은법 시행령 제9조"가 국민보건상 위해를 끼칠 우려가 있는 지역, "도시계획법 제17조"의 규정에 의한 주거지역, 상업지역, 공업지역 및 녹지지역 안의 풍치지구 등의 공설화장장 설치를 금지함에 의하여 보호되는 부근 주민들의 이익은 위 도시계획결정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 법률상 이익이다.

<선정이유>

- 화장장 설치의 직접 근거법령인 도시계획법령에서 법률상 이익을 찾을 수 없더라도 도시계획법령이 원용하고 있는 매장 및 묘지 등에 관한 법령에 근거하여 법률상 이익을 찾을 수 있다면 원고적격이 인정된다는 판결로서, 원고적격에서 처분의 근거법령의 범위를 확대한 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

339. 원고적격 (5) : 이웃 주민(隣人)의 원고적격

"대법원 2011. 9. 8. 선고 2009두6766 판결"

<주제>

- 납골당설치 신고 수리거부의 처분성, 인근주민의 원고적격

<쟁점>

- [1] 납골당설치 신고가 수리를 요하는 신고인지 여부(적극) 및 수리행위에 신고필증 교부 등 행위가 필요한지 여부(소극)
- [2] 파주시장이 종교단체 납골당설치 신고를 한 갑 교회에, "구 장사 등에 관한 법률"에 따라 필요한 시설을 설치하고 유골을 안전하게 보관할 수 있는 설비를 갖추어야 하며 관계 법령에 따른 허가 및 준수 사항을 이행하여야 한다는 취지의 납골당설치 신고사항 이행통지를 한 사안에서, 파주시장이 갑 교회에 이행통지를 함으로써 납골당설치 신고수리를 하였다고 보는 것이 타당하고, 이를 수리처분과 별도로 항고소송 대상이 되는 다른 처분으로 볼 수 없다고 한 사례
- [3] 납골당 설치장소에서 500m 내에 20호 이상의 인가가 밀집한 지역에 거주하는 주민들의 경우, 납골당이 누구에 의하여 설치되는지와 관계없이 납골당 설치에 대하여 환경 이익 침해 또는 침해 우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 원고적격이 인정되는지 여부(적극)

<판결요지>

- [1] "구 장사 등에 관한 법률(이하 '구 장사법') 제14조 제1항", "구 장사 등에 관한 법률 시행규칙 제7조 제1항 [별지 제7호 서식]"을 종합하면, 납골당설치 신고는 이른바 수리를 요하는 신고라 할 것이므로, 납골당설치 신고가 구 장사법 관련 규정의 모든 요건에 맞는 신고라 하더라도 신고인은 곧바로 납골당을 설치할 수는 없고, 이에 대한 행정청의 수리처분이 있어야만 신고한 대로 납골당을 설치할 수 있다. 한편 수리란 신고를 유효한 것으로 판단하고 법령에 의하여 처리할 의사로 이를 수령하는 수동적 행위이므로 수리행위에 신고필증 교부 등 행위가 꼭 필요한 것은 아니다.
- [2] 파주시장이 종교단체 납골당설치 신고를 한 갑 교회에, 구 장사법 등에 따라 필요한 시설을 설치하고 유골을 안전하게 보관할 수 있는 설비를 갖추어야 하며 관계 법령에 따른 허가 및 준수사항을 이행하여야 한다는 내용의 납골당설치 신고사항 이행통지를 한 사안에서, 이행통지는 납골당설치 신고에 대하여 파주시장이 납골당설치 요건을 구비하였음을 확인하고 구 장사법령상 납골당설치 기준, 관계 법령상 허가 또는 신고 내용을 고지하면서 신고한 대로 납골당 시설을 설치하도록 한 것이므로, 파주시장이 갑 교회에 이행통지를 함으로써 납골당설치 신고수리를 하였다고 보는 것이 타당하고, 이행통지가 새로이 갑 교회 또는 관계자들의 법률상 지위에 변동을 일으키지는 않으므로 이를 수리처분과 별도로 항고소송 대상이 되는 다른 처분으로 볼 수 없다고 한 사례
- [3] "구 장사법 제14조 제3항", "구 장사법 시행령 제13조 제1항 [별표 3]"에서 납골묘, 납골담, 가족 또는 종중·문중 납골당 등 사설납골시설의 설치장소를 '20호 이상의 인가가 밀집한 지역으로부터 500m 이상 떨어진 곳'으로 제한을 둔 것은, 이러한 사설납골시설을 인가가 밀집한 지역 인근에 설치하지 못하게 함으로써 주민들의 쾌적한 주거, 경관, 보건위생 등 생활환경상의 개별적 이익을 직접적·구체적으로 보호하려는 데 취지가 있으므로, 이러한 납골시설 설치장소에서 500m 내에 20호 이상의 인가가 밀집한 지역에 거주하는 주민들은 납골당 설치에 대하여 환경상 이익 침해를 받거나 받을 우려가 있는 것으로 사실상 추정된다. 다만 사설납골시설 중 종교단체 및 재단법인이 설치하는 납골당에 대하여는 그와 같은 설치 장소를 제한하는 규정을 명시적으로 두고 있지 않지만, 종교단체나 재단법인이 설치한 납골당이라 하여 납골당으로서 성질이 가족 또는 종중, 문중 납골당과 다르다고 할 수 없고, 인근 주민들이 납골당에 대하여 가지는 쾌적한 주거, 경관, 보건위생 등 생활환경상의 이익에 차이가 난다고 볼 수 없다. 따라서 납골당 설치장소에서 500m 내에 20호 이상의 인가가 밀집한 지역에 거주하는 주민들에게는 납골당이 누구에 의하여 설치되는지를 따질 필요 없이 납골당 설치에 대하여 환경 이익 침해 또는 침해 우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 원고적격이 인정된다고 보는 것이 타당하다.

<선정이유>

- 원고적격과 관련하여 법률상 이익이 있는 자의 범위를 정함에 있어서 법령에서 영향권의 범위가 정해진 경우 영향권 내에 거주하는 주민의 원고적격을 인정한 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

340. 원고적격 (6) : 환경영향평가 대상지역 안의 주민

**“대법원 2006. 3. 16. 선고 2006두330 전원합의체 판결”**

**<주제>**

- 환경영향평가법에 따른 환경영향평가 대상 지역과 원고적격

**<쟁점>**

- [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자가 행정처분의 무효확인을 구할 수 있는 요건으로서 법률상 보호되는 이익의 의미
- [2] 환경영향평가 대상지역 안의 주민에게 공유수면매립면허처분과 농지개량사업 시행인가처분의 무효확인을 구할 원고적격이 인정되는지 여부(적극) 및 환경영향평가 대상지역 밖의 주민에게 그원고적격이 인정되기 위한 요건
- [3] 환경영향평가 대상지역 밖에 거주하는 주민에게 헌법상의 환경권 또는 환경정책기본법에 근거하여 공유수면매립면허처분과 농지개량사업 시행인가처분의 무효확인을 구할 원고적격이 없다고 한 사례

**<판결요지>**

- [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자라 하더라도 당해 행정처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당한 경우에는 그 처분의 무효확인을 구하는 행정소송을 제기하여 그 당부의 판단을 받을 자격이 있다 할 것이며, 여기에서 말하는 법률상 보호되는 이익이라 함은 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익이 있는 경우를 말하고, 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 일반적·간접적·추상적 이익이 생기는 경우에는 법률상 보호되는 이익이 있다고 할 수 없다.
- [2] 공유수면매립면허처분과 농지개량사업 시행인가처분의 근거 법규 또는 관련 법규가 되는 구 공유수면매립법, 구 농촌근대화촉진법, 구 환경보전법, 구 환경보전법 시행령, 구 환경정책기본법, 구 환경정책기본법 시행령의 각 관련 규정의 취지는, 공유수면매립과 농지개량사업시행으로 인하여 직접적이고 중대한 환경피해를 입으리라고 예상되는 환경영향평가 대상지역 안의 주민들이 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경침해를 받지 아니하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 개별적 이익까지도 이를 보호하려는 데에 있다고 할 것이므로, 위 주민들이 공유수면매립면허처분 등과 관련하여 갖고 있는 위와 같은 환경상의 이익은 주민 개개인에 대하여 개별적으로 보호되는 직접적·구체적 이익으로서 그들에 대하여는 특단의 사정이 없는 한 환경상의 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 공유수면매립면허처분 등의 무효확인을 구할 원고적격이 인정된다. 한편, 환경영향평가 대상지역 밖의 주민이라 할지라도 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 그 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경피해를 받거나 받을 우려가 있는 경우에는, 공유수면매립면허처분 등으로 인하여 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해우려가 있다는 것을 입증함으로써 그 처분 등의 무효확인을 구할 원고적격을 인정받을 수 있다.
- [3] “헌법 제35조 제1항”에서 정하고 있는 환경권에 관한 규정만으로는 그 권리의 주체·대상·내용·행사방법 등이 구체적으로 정립되어 있다고 볼 수 없고, “환경정책기본법 제6조”도 그 규정 내용 등에 비추어 국민에게 구체적인 권리를 부여한 것으로 볼 수 없다는 이유로, 환경영향평가 대상지역 밖에 거주하는 주민에게 헌법상의 환경권 또는 환경정책기본법에 근거하여 공유수면매립면허처분과 농지개량사업 시행인가처분의 무효확인을 구할 원고적격이 없다고 한 사례

**<선정이유>**

- 환경관련 소송에서 원고적격을 인정함에 있어서 환경영향평가대상지역을 기준으로 대상지역 안에 있는 자는 원고적격이 추정되고 대상지역 밖에 있는 자는 환경상 이익의 침해(우려)를 입증함으로써 원고적격을 인정받을 수 있음을 밝힌 판결

**<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>**

**341. 원고적격 (7) : 법률상 이익 침해(우려)가 추정되는 주민의 의미**

**“대법원 2009. 9. 24. 선고 2009두2825 판결”**

**<주제>**

- 법률상 이익 침해(우려)가 추정되어 환경소송의 원고적격이 인정되는 영향권 내의 주민의 범위

**<쟁점>**

- 행정처분의 근거 법규 등에 의하여 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해 우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 원고적격이 인정되는 사람의 범위

**<판결요지>**

- 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해 우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 원고적격이 인정되는 사람에는 환경상 침해를 받으리라고 예상되는 영향권 내의 주민들을 비롯하여 그 영향권 내에서 농작물을 경작하는 등 현실적으로 환경상 이익을 향유하는 사람도 포함된다. 그러나 단지 그 영향권 내의 건물·토지를 소유하거나 환경상 이익을 일시적으로 향유하는 데 그치는 사람은 포함되지 않는다.

**<선정이유>**

- 영향권 내에 거주하는 주민뿐만 아니라, 영향권 내에서 농작물을 경작하는 등 현실적으로 환경상 이익을 향유하는 사람도 환경상 이익의 침해 또는 침해 우려가 있는 것으로 추정을 받는다는 것을 밝힌 판결

**<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>**

**342. 원고적격 (8) : 법령이 규정한 영향권 안의 주민**

**“대법원 2010. 4. 15. 선고 2007두16127 판결”**

**<주제>**

- 환경상 침해를 받으리라고 예상되는 영향권의 범위가 근거 법규 등에 구체적으로 규정되어 있는 경우 원고적격

#### <쟁점>

- [1] 행정처분으로써 이루어지는 사업으로 환경상 침해를 받으리라고 예상되는 영향권의 범위가 그 처분의 근거 법규 등에 구체적으로 규정되어 있는 경우, 영향권 내의 주민에게 행정처분의 취소 등을 구할 원고적격이 인정되는지 여부(원칙적 적극) 및 영향권 밖의 주민에게 원고적격이 인정되기 위한 요건

- [2] "구 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제8조 제4호", "구 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제56조 제1항 [별표 1] 제1호 (라)목 (2)" 등의 규정 취지 및 수도물을 공급받아 마시거나 이용하는 주민들이 환경상 이익의 침해를 이유로 공장설립승인처분의 취소 등을 구할 원고적격을 인정 받기 위한 요건

- [3] 김해시장이 낙동강에 합류하는 하천수 주변의 토지에 "구 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제13조"에 따라 공장설립을 승인하는 처분을 한 사안에서, 공장설립으로 수질오염 등이 발생할 우려가 있는 취수장에서 물을 공급받는 부산광역시 또는 양산시에 거주하는 주민들도 위 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 법률상 보호되는 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 주민으로서 원고적격이 인정된다고 한 사례

#### <판결요지>

- [1] 행정처분의 근거 법규 또는 관련 법규에 그 처분으로써 이루어지는 행위 등 사업으로 인하여 환경상 침해를 받으리라고 예상되는 영향권의 범위가 구체적으로 규정되어 있는 경우에는, 그 영향권 내의 주민들에 대하여는 당해 처분으로 인하여 직접적이고 중대한 환경피해를 입으리라고 예상할 수 있고, 이와 같은 환경상의 이익은 주민 개개인에 대하여 개별적으로 보호되는 직접적·구체적 이익으로서 그들에 대하여는 특단의 사정이 없는 한 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해 우려가 있는 것으로 사실상 추정되어 법률상 보호되는 이익으로 인정됨으로써 원고적격이 인정되며, 그 영향권 밖의 주민들은 당해 처분으로 인하여 그 처분 전과 비교하여 수인한도를 넘는 환경피해를 받거나 받을 우려가 있다는 자신의 환경상 이익에 대한 침해 또는 침해 우려가 있음을 증명하여야만 법률상 보호되는 이익으로 인정되어 원고적격이 인정된다.

- [2] 공장설립승인처분의 근거 법규 및 관련 법규인 "구 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제8조 제4호"가 산업자원부장관으로 하여금 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 환경오염을 일으킬 수 있는 공장의 입지제한에 관한 사항을 정하여 고시하도록 규정하고 있고, 이에 따른 산업자원부 장관의 공장입지기준고시(제2004-98호) 제5조 제1호가 상수원 등 용수이용에 현저한 영향을 미치는 지역의 상류를 환경오염을 일으킬 수 있는 공장의 입지 제한지역으로 정할 수 있다고 규정하고, "국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제58조 제3항"의 위임에 따른 "구 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제56조 제1항 [별표 1] 제1호 (라)목 (2)"가 개발행위로 인하여 당해 지역 및 그 주변 지역에 수질오염에 의한 환경오염이 발생할 우려가 없을 것을 개발사업의 허가기준으로 규정하고 있는 취지는, 공장설립승인처분과 그 후속절차에 따라 공장이 설립되어 가동됨으로써 그 배출수 등으로 인한 수질오염 등으로 직접적이고도 중대한 환경상 피해를 입을 것으로 예상되는 주민들이 환경상 침해를 받지 아니한 채 물을 마시거나 용수를 이용하며 쾌적하고 안전하게 생활할 수 있는 개별적 이익까지도 구체적·직접적으로 보호하려는 데 있다. 따라서 수도물을 공급받아 이를 마시거나 이용하는 주민들로서는 위 근거 법규 및 관련 법규가 환경상 이익의 침해를 받지 않은 채 깨끗한 수도물을 마시거나 이용할 수 있는 자신들의 생활환경상의 개별적 이익을 직접적·구체적으로 보호하고 있음을 증명하여 원고적격을 인정받을 수 있다.

- [3] 김해시장이 소감천을 통해 낙동강에 합류하는 하천수 주변의 토지에 "구 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제13조"에 따라 공장설립을 승인하는 처분을 한 사안에서, 상수원인 물금취수장이 소감천이 흘러 내려 낙동강 본류와 합류하는 지점 근처에 위치하고 있는 점, 수도물은 수도관 등 급수시설에 의해 공급되는 것이어서 거주지역이 물금취수장으로부터 다소 떨어진 곳이라고 하더라도 수도물의 수질악화 등으로 주민들이 갖게 되는 환경상 이익의 침해나 그 우려는 그 수도물을 공급하는 취수시설이 입게 되는 수질오염 등의 피해나 그 우려와 동일하게 평가될 수 있는 점 등에 비추어, 공장설립으로 수질오염 등이 발생할 우려가 있는 물금취수장에서 취수된 물을 공급받는 부산광역시 또는 양산시에 거주하는 주민들도 위 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 개별적·구체적·직접적으로 보호되는 환경상 이익, 즉 법률상 보호되는 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 주민으로서 원고적격이 인정된다고 한 사례

#### <선정이유>

- 환경관련 소송에서 원고적격을 인정함에 있어서 영향권의 범위 내에 거주하는 자는 원고적격이 추정되는데, 이 사안은 취수장으로부터 상당한 거리가 떨어진 곳에 거주하는 자라도 수도관을 통해 수도물을 공급받는 경우 영향권 내에 있는 것으로 본 판결

### <제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

#### 343. 원고적격 (9) : 법인의 법률상 이익

"대법원 2012. 6. 28. 선고 2010두2005 판결"

#### <주제>

- 자연인이 아닌 수녀원이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 이익의 향수주체가 될 수 있는지 여부

#### <쟁점>

- 재단법인 갑 수녀원이, 매립목적을 택지조성에서 조선시설용지로 변경하는 내용의 공유수면매립목적 변경 승인처분으로 인하여 법률상 보호되는 환경상 이익을 침해받았다면서 행정청을 상대로 처분의 무효 확인을 구하는 소송을 제기한 사안에서, 갑 수녀원에는 처분의 무효확인을 구할 원고적격이 없다고 한 사례

#### <판결요지>

- 재단법인 갑 수녀원이, 매립목적을 택지조성에서 조선시설용지로 변경하는 내용의 공유수면매립목적 변경 승인처분으로 인하여 법률상 보호되는 환경상 이익을 침해받았다면서 행정청을 상대로 처분의 무효 확인을 구하는 소송을 제기한 사안에서, 공유수면매립목적 변경 승인처분으로 갑 수녀원에 소속된 수녀 등이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 환경상 이익을 침해받았다고 하더라도 이를 가리켜 곧바로 갑 수녀원의 법률상 이익이 침해된다고 볼 수 없고, 자연인이 아닌 갑 수녀원은 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 이익을 향수할 수 있는 주체가 아니므로 위 처분으로 위와 같은 생활상의 이익이 직접적으로 침해되는 관계에 있다고 볼 수도 없으며, 위 처분으로 환경에 영향을 주어 갑 수녀원이 운영하는 썸 공장에 직접적이고 구체적인 재산적 피

해가 발생한다거나 갑 수녀원이 폐쇄되고 이전해야 하는 등의 피해를 받거나 받을 우려가 있다는 점 등에 관한 증명도 부족하다는 이유로, 갑 수녀원에 처분의 무효 확인을 구할 원고적격이 없다고 한 사례

<선정이유>

- 쾌적한 환경에서 생활할 수 있는 이익의 향수 주체를 자연인이 아닌 법인에게도 인정할 수 있는지 여부에 관한 판결로서 이 사안에서는 자연인이 아닌 수녀원에게는 그와 같은 이익이 인정되지 않는다고 판시함

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

344. 원고적격 (10) : 주주의 법률상 이익

“대법원 2005. 1. 27. 선고 2002두5313 판결”

<주제>

- 법인의 주주에게 법인에 대한 행정처분의 취소를 구할 원고적격이 인정되기 위한 요건

<쟁점>

- [1] 법인의 주주가 당해 법인에 대한 행정처분의 취소를 구할 원고적격이 있는 경우
- [2] 은행의 주주에게 은행의 업무정지처분 등을 다룰 원고적격이 인정된다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 법인의 주주는 법인에 대한 행정처분에 관하여 사실상이나 간접적인 이해관계를 가질 뿐이어서 스스로 그 처분의 취소를 구할 원고적격이 없는 것이 원칙이라고 할 것이지만, 그 처분으로 인하여 법인이 더 이상 영업 전부를 행할 수 없게 되고, 영업에 대한 인·허가의 취소 등을 거쳐 해산·청산 되는 절차 또한 처분 당시 이미 예정되어 있으며, 그 후속절차가 취소되더라도 그 처분의 효력이 유지되는 한 당해 법인이 종전에 행하던营业을 다시 행할 수 없는 예외적인 경우에는 주주도 그 처분에 관하여 직접적이고 구체적인 법률상 이해관계를 가진다고 보아 그 효력을 다룰 원고적격이 있다.

- [2] 부실금융기관의 정비를 목적으로 은행의 영업 관련 자산 중 재산적 가치가 있는 자산 대부분과 부채 등이 타에 이전됨으로써 더 이상 그 영업 전부를 행할 수 없게 되고, 은행업무정지처분 등의 효력이 유지되는 한 은행이 종전에 행하던营业을 다시 행할 수는 없는 경우, 은행의 주주에게 당해 은행의 업무정지처분 등을 다룰 원고적격이 인정된다고 한 사례

<선정이유>

- 법인 등 단체의 구성원은 단체에 대한 처분으로 인하여 단체의 존립에 영향을 미쳐서 구성원 자신의 직접적이고 구체적인 법률상 이해관계를 가져오는 경우에 예외적으로 원고적격이 인정된다는 것을 밝힌 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

345. 원고적격 (11) : 학교법인의 임원

“대법원 2007. 12. 27. 선고 2005두9651 판결”

<주제>

- 학교법인의 임원으로 선임된 사람이 법인에 대한 임원취임승인신청 반려처분을 다룰 원고적격

<쟁점>

- [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자가 행정처분의 취소나 무효확인을 구할 수 있는 요건인 법률상 보호되는 이익의 의미
- [2] 관할청의 임원취임승인행위의 법적 성격 및 학교법인의 임원취임승인신청 반려처분에 대하여, 임원으로 선임된 사람이 이를 다룰 수 있는 원고적격이 있는지 여부(적극)

<판결요지>

- [1] 행정처분의 직접 상대방이 아닌 제3자라 하더라도 당해 행정처분으로 인하여 법률상 보호되는 이익을 침해당한 경우에는 그 처분의 취소나 무효 확인을 구하는 행정소송을 제기하여 그 당부의 판단을 받을 자격이 있으며, 여기에서 말하는 법률상 보호되는 이익이란 당해 처분의 근거 법규 및 관련 법규에 의하여 보호되는 개별적·직접적·구체적 이익이 있는 경우를 말하고, 공익보호의 결과로 국민 일반이 공통적으로 가지는 일반적·간접적·추상적 이익이 생기는 경우에는 법률상 보호되는 이익이 있다고 할 수 없다.

- [2] "구 사립학교법 제20조 제1항", "제2항"은 학교법인의 이사장·이사·감사 등의 임원은 이사회의 선임을 거쳐 관할청의 승인을 받아 취임하도록 규정하고 있는바, 관할청의 임원취임승인행위는 학교법인의 임원선임행위의 법률상 효력을 완성케 하는 보충적 법률행위이다. 따라서 관할청이 학교법인의 임원취임승인신청에 대하여 이를 반려하거나 거부하는 경우 학교법인에 의하여 임원으로 선임된 사람은 학교법인의 임원으로 취임할 수 없게 되는 불이익을 입게 되는데, 이와 같은 불이익은 간접적이거나 사실상의 불이익이 아니라 직접적이고 구체적인 법률상의 불이익이라 할 것이므로 학교법인에 의하여 임원으로 선임된 사람에게는 관할청의 임원취임승인신청 반려처분을 다룰 수 있는 원고적격이 있다.

<선정이유>

- 법인 등 단체의 구성원이 단체에 대한 처분을 다투기 위한 요건에 관한 판결로서 학교법인에 대해 임원취임승인신청을 반려하는 경우에 임원이 될 자는 임원으로 취임할 수 없는 불이익을 입게 되는데, 이 경우 불이익은 법률상 불이익이라고 인정한 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제01절 원고적격>

346. 원고적격 (12) : 국가기관

“대법원 2013. 7. 25. 선고 2011두1214 판결”

<주제>

- 행정기관의 당사자적격, 원고적격, 소의 이익

<쟁점>

- 갑이 국민권익위원회에 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률에 따른 신고와 신분보장조치를 요구하였고, 국민권익위원회가 을 시·도선거관리위원회 위원장에게 갑에 대한 중징계요구를 취소하고 향후 신고로 인한 신분상 불이익처분 및 근무조건상의 차별을 하지 말 것을 요구하는 내용의 조치요구를 한 사안에서, 국가기관인 을에게 위 조치요구의 취소를 구하는 소를 제기할 당사자능력, 원고적격 및 법률상 이익을 인정한 원심판단을 정당하다고 한 사례

<판결요지>

- 갑이 국민권익위원회에 “부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률(이하 ‘국민권익위원회법’이라 한다)”에 따른 신고와 신분보장조치를 요구하였고, 국민권익위원회가 갑의 소속기관장인 을 시·도선거관리위원회 위원장에게 갑에 대한 중징계요구를 취소하고 향후 신고로 인한 신분상 불이익처분 및 근무조건상의 차별을 하지 말 것을 요구하는 내용의 조치요구를 한 사안에서, 국가기관 일방의 조치요구에 불응한 상대방 국가기관에 국민권익위원회법상의 제재규정과 같은 중대한 불이익을 직접적으로 규정한 다른 법령의 사례를 찾아보기 어려운 점, 그럼에도 을이 국민권익위원회의 조치요구를 다들 별다른 방법이 없는 점 등에 비추어 보면, 처분성이 인정되는 위 조치요구에 불복하고자 하는 을로서는 조치요구의 취소를 구하는 항고소송을 제기하는 것이 유효·적절한 수단이므로 비록 을이 국가기관이더라도 당사자능력 및 원고적격을 가진다고 보는 것이 타당하고, 을이 위 조치요구 후 갑을 파면하였다고 하더라도 조치요구가 곧바로 실효된다고 할 수 없고 을은 여전히 조치요구를 따라야 할 의무를 부담하므로 을에게는 위 조치요구의 취소를 구할 법률상 이익도 있다고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례

<선정이유>

- 국가기관은 당사자능력이 없고, 국가내의 행정기관 상호간의 분쟁은 항고소송의 대상이 되지 않는 것이 원칙이나, 근거법상 제재규정과 같은 중대한 불이익이 발생하고 항고소송 외에 달리 다들 방법이 없음을 이유로 국가기관의 당사자능력과 원고적격을 인정한 예외적인 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

362. 피고적격 (1)

“대법원 1994. 8. 12. 선고 94누2763 판결”

<주제>

- 내부위임을 받은 하급행정청이 그 명의로 한 행정처분에 대한 항고소송에서 피고적격

<쟁점>

- 내부위임을 받은 데 불과한 하급행정청이 권한 없이 한 행정처분에 대한 행정소송의 피고적격

<판결요지>

- 행정처분의 취소 또는 무효확인을 구하는 행정소송은 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 그 처분을 행한 행정청을 피고로 하여야 하며, 행정처분을 행할 적법한 권한 있는 상급행정청으로부터 내부위임을 받은 데 불과한 하급행정청이 권한 없이 행정처분을 한 경우에도 실제로 그 처분을 행한 하급행정청을 피고로 하여야 할 것이지 그 처분을 행할 적법한 권한 있는 상급행정청을 피고로 할 것은 아니다.

<선정이유>

- 권한의 내부위임의 경우 원칙적으로 수임기관은 위임기관의 명의로 처분을 하고 그 처분에 대한 취소소송의 경우 피고도 위임기관이 되는 것이나, 수임기관이 자기명의로 처분을 한 경우 대외적으로 표시된 자는 수임기관이므로 그를 피고적격자로 하여 국민의 피고적격 혼동을 피하고자 하는 경향을 보여주는 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

363. 피고적격 (2)

“대법원 2007. 8. 23. 선고 2005두3776 판결”

<주제>

- 권한의 위임·위탁의 경우 피고적격

<쟁점>

- 에스에이치공사가 택지개발사업 시행자인 서울특별시시장으로부터 이주대책 수립권한을 포함한 택지개발사업에 따른 권한을 위임 또는 위탁받은 경우, 위 공사 명의로 이루어진 이주대책에 관한 처분에 대한 취소소송의 정당한 피고는 위 공사라고 한 사례

<판결요지>

- 에스에이치공사가 택지개발사업 시행자인 서울특별시시장으로부터 이주대책 수립권한을 포함한 택지개발사업에 따른 권한을 위임 또는 위탁받은 경우, 이주대책 대상자들이 에스에이치공사 명의로 이루어진 이주대책에 관한 처분에 대한 취소소송을 제기함에 있어 정당한 피고는 에스에이치공사가 된다고 한 사례

<선정이유>

- 지방자치법("헌 제104조 제2항")과 조례, 대행계약서 등의 내용에 따라 행정권한이 위 SH공사에 위임된 경우 현실적으로 처분을 한 수임기관인 SH공사가 피고적격자라고 하여 "행정소송법 제2조 제2항"의 취지를 잘 보여준 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제02절 피고적격>

364. 피고적격 (3)

“대법원 2014. 9. 26. 선고 2013두2518 판결”

<주제>

- 처분청과 처분을 통지한 기관이 다른 경우 피고적격

<쟁점>

- [1] 망인에게 수여된 서훈을 취소하는 경우, 유족이 서훈취소 처분의 상대방이 되는지 여부(소극)및 망인에 대한 서훈취소 결정의 효력이 발생하기 위한 요건  
- [2] 국무회의에서 건국훈장 독립장이 수여된 망인에 대한 서훈취소를 의결하고 대통령이 결재함으로써 서훈취소가 결정된 후 국가보훈처장이 망인의 유족 갑에게 독립유공자 서훈취소결정 통보를 하자 갑이 국가보훈처장을 상대로 서훈취소결정의 무효 확인 등의 소를 제기한 사안에서, 위소는 피고를 잘못 지정하였다고 한 사례

<판결요지>

- [1] "헌법 제11조 제3항"과 "구 상훈법 제2조", "제33조", "제34조", "제39조"의 규정 취지에 의하면, 서훈은 서훈대상자의 특별한 공적에 의하여 수여되는 고도의 일신전속적 성격을 가지는 것이다. 나아가 서훈은 단순히 서훈대상자 본인에 대한 수혜적 행위로서의 성격만을 가지는 것이 아니라, 국가에 뚜렷한 공적을 세운 사람에게 영예를 부여함으로써 국민 일반에 대하여 국가와 민족에 대한 자긍심을 높이고 국가적 가치를 통합·제시하는 행위의 성격도 있다. 서훈의 이러한 특수성으로 말미암아 상훈법은 일반적인 행정행위와 달리 사망한 사람에 대하여도 그의 공적을 영예의 대상으로 삼아 서훈을 수여할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 그러한 경우에도 서훈은 어디까지나 서훈대상자 본인의 공적과 영예를 기리기 위한 것이므로 비록 유족이라고 하더라도 제3자는 서훈수여 처분의 상대방이 될 수 없고, "구 상훈법 제33조", "제34조" 등에 따라 망인을 대신하여 단지 사실행위로서 훈장 등을 교부받거나 보관할 수 있는 지위에 있을 뿐이다. 이러한 서훈의 일신전속적 성격은 서훈취소의 경우에도 마찬가지이므로, 망인에게 수여된 서훈의 취소에서도 유족은 그 처분의 상대방이 되는 것이 아니다.  
- 이와 같이 망인에 대한 서훈취소는 유족에 대한 것이 아니므로 유족에 대한 통지에 의해서만 성립하여 효력이 발생한다고 볼 수 없고, 그 결정이 처분권자의 의사에 따라 상당한 방법으로 대외적으로 표시됨으로써 행정행위로서 성립하여 효력이 발생한다고 봄이 타당하다.  
- [2] 국무회의에서 건국훈장 독립장이 수여된 망인에 대한 서훈취소를 의결하고 대통령이 결재함으로써 서훈취소가 결정된 후 국가보훈처장이 망인의 유족 갑에게 독립유공자 서훈취소결정 통보를 하자 갑이 국가보훈처장을 상대로 서훈취소결정의 무효 확인 등의 소를 제기한 사안에서, 갑이 서훈취소 처분을 행한 행정청(대통령)이 아니라 국가보훈처장을 상대로 제기한 위 소는 피고를 잘못 지정한 경우에 해당하므로, 법원에서는 석명권을 행사하여 정당한 피고로 경정하게 하여 소송을 진행해야 함에도 국가보훈처장이 서훈취소 처분을 한 것을 전제로 처분의 적법 여부를 판단한 원심판결에 법리오해 등의 잘못이 있다고 한 사례

<선정이유>

- 국무회의에서 건국훈장 독립장이 수여된 망인에 대한 서훈취소를 의결하고 대통령이 결재함으로써 서훈취소가 결정된 후 국가보훈처장이 망인의 유족 갑에게 독립유공자 서훈취소결정 통보를 한 경우, 통보기관일 뿐인 국가보훈처장이 아니라 서훈취소 처분을 행한 대통령에게 피고적격이 있다는 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

347. 소의 이익 (1) : 처분에서 정한 제재기간의 경과

“대법원 2006. 6. 22. 선고 2003두1684 전원합의체 판결”

<주제>

- 제재기간이 경과한 제재처분에 대한 소의 이익

<쟁점>

- [1] 제재적 행정처분이 그 처분에서 정한 제재기간의 경과로 인하여 그 효과가 소멸되었으나, 부령인 시행규칙 또는 지방자치단체의 규칙의 형식으로 정한 처분기준에서 제재적 행정처분을 받은 것을 가중사유나 전제요건으로 삼아 장래의 제재적 행정처분을 하도록 정하고 있는 경우, 선행처분인 제재적 행정처분을 받은 상대방이 그 처분에서 정한 제재기간이 경과하였다 하더라도 그 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있는지 여부(한정 적극)  
- [2] 환경영향평가대행업무 중지처분을 받은 환경영향평가대행업자가 업무정지처분기간 중 환경영향평가대행계약을 신규로 체결하고 그 대행업무를 한 사안에서, 업무정지처분기간 경과 후에도 "환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법 시행규칙"의 규정에 따른 후행처분을 받지 않기 위하여 위 업무정지처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 한 사례

<판결요지>

- [1] [다수의견] 제재적 행정처분이 그 처분에서 정한 제재기간의 경과로 인하여 그 효과가 소멸되었으나, 부령인 시행규칙 또는 지방자치단체의 규칙(이하 이들을 '규칙'이라고 한다)의 형식으로 정한 처분기준에서 제재적 행정처분(이하 '선행처분'이라고 한다)을 받은 것을 가중사유나 전제요건으로 삼아 장래의 제재적 행정처분(이하 '후행처분'이라고 한다)을 하도록 정하고 있는 경우, 제재적 행정처분의 가중사유나 전제요건에 관한 규정이 법령이 아니라 규칙의 형식으로 되어 있다고 하더라도, 그러한 규칙이 법령에 근거를 두고 있는 이상 그 법적 성질이 대외적·일반적 구속력을 갖는 법규명령인지 여부와는 상관없이, 관할 행정청이나 담당공무원은 이를 준수할 의무가 있으므로 이들이 그 규칙에 정해진 바에 따라 행정작용을 할 것이 당연히 예견되고, 그 결과 행정작용의 상대방인 국민으로서의 그 규칙의 영향을 받을 수밖에 없다. 따라서 그러한 규칙이 정한 바에 따라 선행처분을 받은 상대방이 그 처분의 존재로 인하여 장래에 받을 불이익, 즉 후행처분의 위험은 구체적이고 현실적인 것이므로, 상대방에게는 선행처분의 취소소송을 통하여 그 불이익을 제거할 필요가 있다. 또한, 나중에 후행처분에 대한 취소소송에서 선행처분의 사실관계나 위법 등을 다룰 수 있는 여지가 남아 있다고 하더라도, 이러한 사정은 후행처분이 이루어지기 전에 이를 방지하기 위하여 직접 선행처분의 위법을 다투는 취소소송을 제기할 필요성을 부정할 이유가 되지 못한다. 그러한 쟁송방법을 막는 것은 여러 가지 불합리한 결과를 초래하여 권리구제의 실효성을 저해할 수 있기 때문이다. 오히려 앞서 본 바와 같이 행정청으로서의 선행처분이 적법함을 전제로 후행처분을 할 것이 당연히 예견되므로, 이러한 선행처분으로 인한 불이익을 선행처분 자체에 대한 소송에서 사전에 제거할 수 있도록 해 주는 것이 상대방의 법률상 지위에 대한 불안을 해소하는 데 가장 유효적절한 수단이 된다고 할 것이고, 또한 그 소송을 통하여 선행처분의 사실관계 및 위법 여부가 조속히 확정됨으로써 이와 관련된 장래의 행정작용의 적법성을 보장함과 동시에 국민생활의 안정을 도모할 수 있다. 이상의 여러 사정과 아울러, 국민의 재판청구권을 보장한 "헌법 제27조 제1항"의 취지와 행정처분으로 인한 권익침해를 효과적으로 구제하려는 행정소송법의 목적 등에 비추어 행정처분의 존재로 인하여 국민의 권익이 실제로 침해되고 있는 경우는 물론이고 권익침해의 구체적·현실적 위험이 있는 경우에도 이를 구제하는 소송이 허용되어야 한다는 요청을 고려하면, 규칙이 정한 바에 따라 선행처분을 가중사유 또는 전제요건으로 하는 후행처분을 받을 우려가 현실적으로 존재하는 경우에는, 선행처분을 받은 상대방은 비록 그 처분에서 정한 제재기간이 경과하였다하더라도 그 처분의 취소소송을 통하여 그러한 불이익을 제거할 권리보호의 필요성이 충분히 인정된다고 할 것이므로, 선행처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 보아야 한다.

- [2] 환경영향평가대행업무 정지처분을 받은 환경영향평가대행업자가 업무정지처분기간 중 환경영향평가대행계약을 신규로 체결하고 그 대행업무를 한 사안에서, "환경·교통·재해 등에 관한 영향평가법 시행규칙 제10조 [별표 2] 2. 개별기준 (11)"에서 환경영향평가대행업자가 업무정지처분기간 중 신규계약에 의하여 환경영향평가대행업무를 한 경우 1차 위반시 업무정지 6월을, 2차 위반시 등록취소를 각 명하는 것으로 규정하고 있으므로, 업무정지처분기간 경과 후에도 위 시행규칙의 규정에 따른 후행처분을 받지 않기 위하여 위 업무정지처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다고 한 사례

#### <선정이유>

- 제재기간이 경과한 경우 제재처분을 항고소송으로 다툴 소익이 없음이 원칙이나, 법령에서 제재처분을 받은 전력을 이후의 가중사유나 전제요건으로 규정한 경우에는 예외적으로 소익이 인정되고, 해당 법령이 부령이나 지방자치단체의 규칙으로서 법규성이 인정되지 않는 경우도 마찬가지로 소익이 인정됨을 밝힌 판결

### <제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

#### 348. 소의 이익 (2) : 처분의 직권취소

"대법원 2002. 9. 6. 선고 2001두5200 판결"

##### <주제>

- 직권으로 취소된 처분의 취소를 구할 소의 이익

##### <쟁점>

- 납품업자에 대한 입찰참가자격 제한처분을 직권으로 취소하고 제1심판결의 취지에 따라 그 제재기간만을 감경하여 입찰참가자격을 제한하는 내용의 새로운 처분을 다시 한 경우, 당초의 입찰참가자격 제한처분은 적법하게 취소되었다고 할 것이어서 그 처분의 취소를 구할 소의 이익이 없다고 한 사례

##### <판결요지>

- 납품업자에 대한 입찰참가자격 제한처분을 직권으로 취소하고 제1심판결의 취지에 따라 그 제재기간만을 감경하여 입찰참가자격을 제한하는 내용의 새로운 처분을 다시 한 경우, 당초의 입찰참가자격 제한처분은 적법하게 취소되었다고 할 것이어서 그 처분의 취소를 구할 소의 이익이 없다고 한 사례

##### <선정이유>

- 직권으로 당초의 처분을 취소하고 새로운 처분을 하였다면 당초의 처분은 존재하지 않게 되므로, 존재하지 아니한 처분의 취소를 구하는 소는 원칙적으로 소의 이익이 없다고 한 판결

### <제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

#### 349. 소의 이익 (3) : 처분의 직권취소

"대법원 2019. 6. 27. 선고 2018두49130 판결"

##### <주제>

- 소송 계속 중 처분이 직권취소된 경우 예외적으로 소의 이익이 인정되기 위한 요건

##### <쟁점>

- 행정처분의 무효확인 또는 취소를 구하는 소송 계속 중 처분청이 다툼의 대상이 되는 행정처분을 직권으로 취소한 경우, 그 처분을 대상으로 한 항고소송이 적법한지 여부(원칙적 소극) 및 예외적으로 그 처분의 취소를 구할 소의 이익을 인정할 수 있는 경우

##### <판결요지>

- 행정처분의 무효확인 또는 취소를 구하는 소가 제소 당시에는 소의 이익이 있어 적법하였더라도, 소송 계속 중 처분청이 다툼의 대상이 되는 행정처분을 직권으로 취소하면 그 처분은 효력을 상실하여 더 이상 존재하지 않는 것이므로, 존재하지 않는 그 처분을 대상으로 한 항고소송은 원칙적으로 소의 이익이 소멸하여 부적법하다.
- 다만 처분청의 직권취소에도 불구하고 완전한 원상회복이 이루어지지 않아 무효확인 또는 취소로써 회복할 수 있는 다른 권리나 이익이 남아 있거나 또는 동일한 소송 당사자 사이에서 그 행정처분과 동일한 사유로 위법한 처분이 반복될 위험성이 있어 행정처분의 위법성 확인 내지 불분명한 법률문제에 대한 해명이 필요한 경우 행정의 적법성 확보와 그에 대한 사법통제, 국민의 권리구제의 확대 등의 측면에서 예외적으로 그 처분의 취소를 구할 소의 이익을 인정할 수 있을 뿐이다.

<선정이유>

- 직권으로 처분이 취소되면 처분이 존재하지 않게 되어 이에 대한 취소를 구하는 소는 소의 이익이 없지만, 예외적으로 취소를 통해 회복되는 권리나 이익이 남아 있거나 처분의 위법성 확인이나 불분명한 법률관계를 명확히 해명할 필요가 있는 경우 소의 이익이 인정된다는 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

350. 소의 이익 (4) : 조합설립변경인가가 있는 경우

“대법원 2012. 10. 25. 선고 2010두25107 판결”

<주제>

- 도시정비사업조합설립 변경인가가 있는 경우 종전의 조합설립인가처분을 다툼 소의 이익

<쟁점>

- [1] 행정청이 주택재건축사업조합 설립인가처분을 한 후 “구 도시 및 주거환경정비법 시행령 제27조 각 호”에서 정하는 경미한 사항의 변경에 대하여 조합설립 변경인가 형식으로 처분을 한 경우, 당초 조합설립인가처분을 다툼 소의 이익이 소멸하는지 여부(소극)
- [2] 주택재건축사업조합이 새로 조합설립인가처분을 받는 것과 동일한 요건과 절차를 거쳐 조합설립변경인가처분을 받는 경우, 당초 조합설립인가처분의 무효확인을 구할 소의 이익이 소멸하는지 여부(원칙적 소극)

<판결요지>

- [1] 재건축조합설립인가신청에 대한 행정청의 조합설립인가처분은 법령상 일정한 요건을 갖추 경우 주택재건축사업의 추진위원회에게 행정주체로서의 지위를 부여하는 일종의 설권적 처분의 성격을 가지고 있고, “구 도시 및 주거환경정비법 제16조 제2항”은 조합설립인가처분의 내용을 변경하는 변경인가처분을 할 때에는 조합설립인가처분과 동일한 요건과 절차를 거칠 것을 요구하고 있다. 그런데 조합설립인가처분과 동일한 요건과 절차가 요구되지 않는 “구 도시 및 주거환경정비법 시행령 제27조 각 호”에서 정하는 경미한 사항의 변경에 대하여 행정청이 조합설립의 변경인가라는 형식으로 처분을 하였다고 하더라도, 그 성질은 당초의 조합설립인가처분과는 별개로 위 조항에서 정한 경미한 사항의 변경에 대한 신고를 수리하는 의미에 불과한 것으로 보아야 하므로, 경미한 사항의 변경에 대한 신고를 수리하는 의미에 불과한 변경인가처분이 있다고 하더라도 설권적 처분인 조합설립인가처분을 다툼 소의 이익이 소멸된다고 볼 수는 없다.
- [2] 주택재건축사업조합이 새로 조합설립인가처분을 받는 것과 동일한 요건과 절차를 거쳐 조합설립변경인가처분을 받는 경우 당초 조합설립인가처분의 유효를 전제로 당해 주택재건축사업조합이 매도청구권 행사, 시공자 선정에 관한 총회 결의, 사업시행계획의 수립, 관리처분계획의 수립 등과 같은 후속 행위를 하였다면 당초 조합설립인가처분이 무효로 확인되거나 취소될 경우 그것이 유효하게 존재하는 것을 전제로 이루어진 위와 같은 후속 행위 역시 소급하여 효력을 상실하게 되므로, 특별한 사정이 없으면 위와 같은 형태의 조합설립변경인가가 있다고 하여 당초 조합설립인가처분의 무효확인을 구할 소의 이익이 소멸된다고 볼 수는 없다.

<선정이유>

- 당초처분과 변경처분의 관계는 대상처분이 무엇인지, 변경처분 후 당초처분의 취소나 무효를 구하는 소의 이익이 있는지 등이 관건임. 주택재건축사업조합 설립인가처분 후, 경미한 사항을 변경한 경우 변경인가는 변경사항에 대한 신고를 수리하는 의미에 불과하므로 설립인가처분의 취소를 구할 소의 이익이 있고, 설립인가처분과 동일한 요건과 절차에 따라 변경인가처분을 한 경우라도 설립인가의 유효를 전제로 후속행위가 이어지므로 설립인가처분의 취소를 구할 소의 이익이 있다고 본 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

351. 소의 이익 (5) : 임기가 만료된 학교법인의 임원

“대법원 2007. 7. 19. 선고 2006두19297 전원합의체 판결”

<주제>

- 학교법인 임원취임승인취소 처분에 대한 소의 이익

<쟁점>

- [1] 임기가 만료된 학교법인의 이사나 감사가 후임이사나 감사의 선임시까지 종전 직무를 계속 수행할 긴급처리권이 인정되는지 여부(원칙적 적극) 및 위 긴급처리권에 후임 정식이사를 선임할 권한이 포함되는지 여부(적극)
- [2] 학교법인 임원취임승인의 취소처분 후 그 임원의 임기가 만료되고 “구 사립학교법 제22조 제2호” 소정의 임원결격사유기간마저 경과한 경우 또는 위 취소처분에 대한 취소소송 제기 후 임시이사가 교체되어 새로운 임시이사가 선임된 경우, 위 취임승인취소처분 및 당초의 임시이사선임처분의 취소를 구할 소의 이익이 있는지 여부(적극)

<판결요지>

- [1] 학교법인의 이사나 감사 전원 또는 그 일부의 임기가 만료되었다고 하더라도, 그 후임이사나 후임감사를 선임하지 않았거나 또는 그 후임이사나 후임감사를 선임하였다고 하더라도 그 선임결의가 무효이고 임기가 만료되지 아니한 다른 이사나 감사만으로는 정상적인 학교법인의 활동을 할 수 없는 경우, 임기가 만료된 구 이사나 감사로 하여금 학교법인의 업무를 수행케 함이 부적당하다고 인정할 만한 특별한 사정이 없는 한, "민법 제691조"를 유추하여 구 이사나 감사에게는 후임이사나 후임감사가 선임될 때까지 종전의 직무를 계속하여 수행할 긴급처리권이 인정된다고 할 것이며, 학교법인의 경우 민법상 재단법인과 마찬가지로 이사를 선임할 수 있는 권한은 이사회에 있으므로, 임기가 만료된 이사들의 참여 없이 후임 정식이사들을 선임할 수 없는 경우 임기가 만료된 이사로서는 위 긴급처리권에 의하여 후임 정식이사들을 선임할 권한도 보유하게 된다.

- [2] (가) 비록 취임승인이 취소된 학교법인의 정식이사들에 대하여 원래 정해져 있던 임기가 만료되고 "구 사립학교법 제22조 제2호" 소정의 임원결격사유기간만저 경과하였다 하더라도, 그 임원취임승인취소처분이 위법하다고 판명되고 나아가 임시이사들의 지위가 부정되어 직무권한이 상실되면, 그 정식이사들은 후임이사 선임시까지 "민법 제691조"의 유추적용에 의하여 직무수행에 관한 긴급처리권을 가지게 되고 이에 터잡아 후임 정식이사들을 선임할 수 있게 되는바, 이는 감사의 경우에도 마찬가지이다.

- (나) 제소 당시에는 권리보호의 이익을 갖추었는데 제소 후 취소 대상 행정처분이 기간의 경과 등으로 그 효과가 소멸한 때, 동일한 소송 당사자 사이에서 동일한 사유로 위법한 처분이 반복될 위험성이 있어 행정처분의 위법성 확인 내지 불분명한 법률문제에 대한 해명이 필요하다고 판단되는 경우, 그리고 선행처분과 후행처분이 단계적인 일련의 절차로 연속하여 행하여져 후행처분이 선행처분의 적법함을 전제로 이루어짐에 따라 선행처분의 하자가 후행처분에 승계된다고 볼 수 있어 이미 소를 제기하여 다투고 있는 선행처분의 위법성을 확인하여 줄 필요가 있는 경우 등에는 행정의 적법성 확보와 그에 대한 사법통제, 국민의 권리구제의 확대 등의 측면에서 여전히 그 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

- (다) 임시이사 선임처분에 대하여 취소를 구하는 소송의 계속 중 임기만료 등의 사유로 새로운 임시이사들로 교체된 경우, 선행 임시이사 선임처분의 효과가 소멸하였다는 이유로 그 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 보게 되면, 원래의 정식이사들로서는 계속 중인 소를 취하하고 후행 임시이사선임처분을 별개의 소로 다투 수밖에 없게 되며, 그 별소 진행 도중 다시 임시이사가 교체되면 또 새로운 별소를 제기하여야 하는 등 무익한 처분과 소송이 반복될 가능성이 있으므로, 이러한 경우 법원이 선행 임시이사 선임처분의 취소를 구할 법률상 이익을 긍정하여 그 위법성 내지 하자의 존재를 판결로 명확히 해명하고 확인하여 준다면 위와 같은 구체적인 침해의 반복 위험을 방지할 수 있을 뿐 아니라, 후행 임시이사 선임처분의 효력을 다투는 소송에서 기판력에 의하여 최초 내지 선행 임시이사 선임처분의 위법성을 다투지 못하게 함으로써 그 선임처분을 전제로 이루어진 후행 임시이사 선임처분의 효력을 쉽게 배제할 수 있어 국민의 권리구제에 도움이 된다.

- (라) 그러므로 취임승인이 취소된 학교법인의 정식이사들로서는 그 취임승인취소처분 및 임시이사 선임처분에 대한 각 취소를 구할 법률상 이익이 있고, 나아가 선행 임시이사 선임처분의 취소를 구하는 소송 도중에 선행 임시이사가 후행 임시이사로 교체되었다고 하더라도 여전히 선행 임시이사 선임처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

<선정이유>

- 학교법인 이사 등 임원에 대한 취임승인취소처분의 취소를 구하는 소송 도중 임원의 임기가 만료된 경우 원칙적으로 소의 이익이 없지만, 임시 이사나 후임 이사가 선임된 경우, 정식이사에 대한 승인취소처분과 임시 이사선임 간의 하자의 승계나 승인취소처분취소소송의 기판력의 역할 및 무익한 소송의 반복방지 등에 비추어 임원취임승인취소처분의 취소를 구할 소의 이익이 인정된다는 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

352. 소의 이익 (6) : 퇴학처분 이후 검정고시에 합격한 경우

“대법원 1992. 7. 14. 선고 91누4737 판결”

<주제>

- 고등학교 퇴학처분의 취소를 구할 소의 이익

<쟁점>

- 고등학교에서 퇴학처분을 당한 후 고등학교졸업학력검정고시에 합격한 경우, 퇴학처분의 취소를 구할 소의 이익 유무(적극)

<판결요지>

- 고등학교졸업이 대학입학자격이나 학력인정으로서의 의미밖에 없다고 할 수 없으므로 고등학교졸업학력검정고시에 합격하였다 하여 고등학교 학생으로서의 신분과 명예가 회복될 수 없는 것이니 퇴학처분을 받은 자로서는 퇴학처분의 위법을 주장하여 그 취소를 구할 소송상의 이익이 있다.

<선정이유>

- 처분 후 사정변경으로 이익침해가 해소된 경우 소의 이익이 인정되지 않지만, 고등학교 졸업검정고시합격으로 인해 고등학교 학생으로 신분과 명예가 회복될 수 없으므로 검정고시에 합격했다 하더라도 고등학교 퇴학처분의 취소를 구할 소의 이익이 있다는 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

353. 소의 이익 (7) : 원상회복이 불가능한 경우

“대법원 1992. 4. 24. 선고 91누11131 판결”

<주제>

- 건축공사가 완료된 이후 건축허가의 취소를 구할 소의 이익

<쟁점>

- [1] 위법한 행정처분을 취소한다 하더라도 그 원상회복이 불가능한 경우 그 취소를 구할 소의 이익 유무(소극)

- [2] 건축허가가 건축법 소정의 이격거리를 두지 아니하고 건축물을 건축하도록 되어 있어 위법하다 하더라도 이미 건축공사가 완료되었다면 인접한 대지의 소유자로서는 위 건축허가처분의 취소를 구할 소의 이익이 없다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 위법한 행정처분의 취소를 구하는 소는 위법한 처분에 의하여 발생한 위법상태를 배제하여 원상으로 회복시키고 그 처분으로 침해되거나 방해받은 권리와 이익을 보호 구제하고자 하는 소송이므로 비록 그 위법한 처분을 취소한다 하더라도 원상회복이 불가능한 경우에는 그 취소를 구할 이익이 없다.

- [2] 건축허가가 건축법 소정의 이격거리를 두지 아니하고 건축물을 건축하도록 되어 있어 위법하다 하더라도 그 건축허가에 기하여 건축공사가 완료되었다면 그 건축허가를 받은 대지와 접한 대지의 소유자인 원고가 위 건축허가처분의 취소를 받아 이격거리를 확보할 단계는 지났으며 민사소송으로 위 건축물 등의 철거를 구하는 데 있어서도 위 처분의 취소가 필요한 것이 아니므로 원고로서는 위 처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 없다고 한 사례

<선정이유>

- 건축물간 이격거리 위반 등을 이유로 위법한 건축허가가 취소된 경우, 허가가 없는 것이 되므로 수허가자는 건축을 할 수 없으나, 이미 공사가 완공된 경우에는 허가가 취소된다고 하더라도 이격거리 확보에 관한 원고의 이익은 회복될 수 없고, 나아가 원고는 행정청에게 존재하는 건축물의 철거를 구할 수 없으며(대법원 1987.5.12. 선고 87누98 판결), 건축주를 상대로 민사상 건물철거를 구하기 위해 건축허가가 필요한 것도 아니므로 건축허가 취소를 구할 소의 이익이 없다는 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

354. 소의 이익 (8) : 원상회복이 불가능한 경우

“대법원 2016. 8. 30. 선고 2015두60617 판결”

<주제>

- 원상회복이 불가능한 경우 처분의 취소를 구할 소의 이익

<쟁점>

- 갑 도지사가 도에서 설치·운영하는 을 지방의료원을 폐업하겠다는 결정을 발표하고 그에 따라 폐업을 위한 일련의 조치가 이루어진 후 을 지방의료원을 해산한다는 내용의 조례를 공포하고 을지방의료원의 청산절차가 마쳐진 사안에서, 갑 도지사의 폐업결정은 항고소송의 대상에 해당하지만 취소를 구할 소의 이익을 인정하기 어렵다고 한 사례

<판결요지>

- 갑 도지사가 도에서 설치·운영하는 을 지방의료원을 폐업하겠다는 결정을 발표하고 그에 따라 폐업을 위한 일련의 조치가 이루어진 후 을 지방의료원을 해산한다는 내용의 조례를 공포하고 을지방의료원의 청산절차가 마쳐진 사안에서, 지방의료원의 설립·통합·해산은 지방자치단체의 조례로 결정할 사항이므로, 도가 설치·운영하는 을 지방의료원의 폐업·해산은 도의 조례로 결정할 사항인 점 등을 종합하면, 갑 도지사의 폐업결정은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력 행사로서 입원환자들과 소속 직원들의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 것이므로 항고소송의 대상에 해당하지만, 폐업결정 후 을 지방의료원을 해산한다는 내용의 조례가 제정·시행되었고 조례가 무효라고 볼 사정도 없어 을 지방의료원을 폐업 전의 상태로 되돌리는 원상회복은 불가능하므로 법원이 폐업결정을 취소하더라도 단지 폐업결정이 위법함을 확인하는 의미밖에 없고, 폐업결정의 취소로 회복할 수 있는 다른 권리나 이익이 남아있다고 보기도 어려우므로, 갑 도지사의 폐업결정이 법적으로 권한 없는 자에 의하여 이루어진 것으로서 위법하더라도 취소를 구할 소의 이익을 인정하기 어렵다고 한 사례

<선정이유>

- 폐업결정 후, 후속조치로 폐업을 위한 일련의 조치, 조례의 제정·시행, 청산절차 등이 진행된 경우, 폐업결정을 취소하더라도 폐업결정이 위법하다는 것을 확인하는 것에 불과할 뿐 원상회복이 불가능하므로 소의 이익이 없다는 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

355. 소의 이익 (9) : 원상회복이 불가능하더라도 취소를 구할 이익이 잔존하는 경우

“대법원 2002. 1. 11. 선고 2000두3306 판결”

<주제>

- 공장건물이 멸실된 이후 공장등록취소처분의 취소를 구할 소의 이익

<쟁점>

- [1] 공장건물의 멸실 여부에 불구하고 그 공장등록취소처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있는 경우  
- [2] 공장등록이 취소된 후 그 공장시설물이 철거되었다 하더라도 대도시 안의 공장을 지방으로 이전할 경우 조세특례제한법상의 세액공제 및 소득세 등의 감면혜택이 있고, 영업배치및공장설립에관한법률상의 간이한 이전절차 및 우선 입주의 혜택이 있는 경우, 그 공장등록취소처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 일반적으로 공장등록이 취소된 후 그 공장 시설물이 어떠한 경위로든 철거되어 다시 복구 등을 통하여 공장을 운영할 수 없는 상태라면 이는 공장등록의 대상이 되지 아니하므로 외형상 공장등록취소행위가 잔존하고 있다고 하여도 그 처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 없다 할 것이나, 위와 같은

경우에도 유효한 공장등록으로 인하여 공장등록에 관한 당해 법률이나 다른 법률에 의하여 보호되는 직접적·구체적 이익이 있다면, 당사자로서는 공장건물의 멸실 여부에 불구하고 그 공장등록취소처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있다.

- [2] 공장등록이 취소된 후 그 공장시설물이 철거되었다 하더라도 대도시 안의 공장을 지방으로 이전할 경우 조세특례제한법상의 세액공제 및 소득세 등의 감면혜택이 있고, 공업배치및공장설립에관한법률상의 간이한 이전절차 및 우선 입주 등의 보호되는 직접적·구체적 이익이 있다면, 그 공장등록취소처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 있다고 한 사례

#### <선정이유>

- 공장건물이 멸실되어 공장을 운영할 수 없게 된 경우 형식상 공장등록취소행위가 존재하더라도 원칙적으로 취소를 구할 소의 이익이 없으나, 관련 법령에 따라 설비투자에 대한 감면혜택이나 다른 곳에 공장을 설치할 경우 간이한 이전절차 및 우선입주 등의 보호되는 직접적·구체적 이익이 있다면 소의 이익이 인정된다는 판결

---

#### <제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

#### 356. 소의 이익 (10) : 위법한 행정처분의 반복가능성

“대법원 2014. 2. 13. 선고 2013두20899 판결”

##### <주제>

- 위법한 행정처분이 반복될 가능성이 있는 경우 소의 이익

##### <쟁점>

- 교도소장이 수형자 갑을 접견내용 녹음·녹화 및 접견 시 교도관 참여대상자로 지정하였다가 취소소송 계속 중 그 지정행위를 취소한 경우 소의 이익이 인정되기 위한 요건

##### <판결요지>

- [1] 교도소장이 수형자 갑을 접견내용 녹음·녹화 및 접견 시 교도관 참여대상자로 지정한 사안에서, 위 지정행위는 수형자의 구체적 권리의무에 직접적 변동을 가져오는 행정청의 공법상 행위로서 항고소송의 대상이 되는 처분에 해당한다고 본 원심판단을 정당한 것으로 수긍한 사례  
- [2] 비록 피고가 이 사건 제1심판결 선고 이후 원고를 위 접견내용 녹음·녹화 및 접견 시 교도관 참여대상자에서 해제하기는 하였지만 앞으로도 원고에게 위와 같은 포괄적 접견제한처분을 할 염려가 있는 것으로 예상된다는 이유로 소의 이익을 인정한 사례

#### <선정이유>

- 특별신분관계에 있는 수형자의 지위, 공권력적 사실행위로서의 지정행위의 성격 즉 그 지정행위가 과거 오랜 기간 지속되어 왔고 그 수인강제의 성격을 갖는다는 점들이 고려되어 지정해제 이후에도 위법한 행정처분이 반복될 가능성이 있다고 본 판결

---

#### <제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

#### 357. 소의 이익 (11) : 강학상 인가와 기본행위의 하자

“대법원 2002. 5. 24. 선고 2000두3641 판결”

##### <주제>

- 기본행위의 하자를 이유로 인가처분의 취소를 구할 소의 이익

##### <쟁점>

- 기본행위인 임시이사들에 의한 이사선임결의의 내용 및 그 절차에 하자가 있다는 이유로 이사선임결의의 효력에 관하여 다툼이 있는 경우, 그 보충행위인 임원취임승인처분의 무효확인이나 그 취소를 구할 법률상 이익이 있는지 여부(소극)

##### <판결요지>

- 기본행위인 이사선임결의가 적법·유효하고 보충행위인 승인처분 자체에만 하자가 있다면 그 승인처분의 무효확인이나 그 취소를 주장할 수 있지만, 이 사건 임원취임승인처분에 대한 무효확인이나 그 취소의 소처럼 기본행위인 임시이사들에 의한 이사선임결의의 내용 및 그 절차에 하자가 있다는 이유로 이사선임결의의 효력에 관하여 다툼이 있는 경우에는 민사쟁송으로서 그 기본행위에 해당하는 위 이사선임결의의 무효확인을 구하는 등의 방법으로 분쟁을 해결할 것이지 그 이사선임결의에 대한 보충적 행위로서 그 자체만으로는 아무런 효력이 없는 승인처분만의 무효확인이나 그 취소를 구하는 것은 특단의 사정이 없는 한 분쟁해결의 유효적절한 수단이라 할 수 없으므로, 임원취임승인처분의 무효확인이나 그 취소를 구할 법률상 이익이 없다.

#### <선정이유>

- 강학상 인가(승인처분)는 보충행위로서 그 자체에 하자가 없다면 기본행위인 법률행위(이사선임결의)에 하자가 있더라도 그것을 이유로 인가처분의 무효확인이나 취소를 구할 협의의 소의 이익이 없다는 다수설과 판례의 일관된 입장을 잘 보여주는 판결

---

#### <제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

#### 358. 소의 이익 (12) : 사업양도에 따른 지위승계 신고수리처분

“대법원 2005. 12. 23. 선고 2005두3554 판결”

<주제>

- 사업양도·양수에 따른 허가관청의 지위승계 신고수리처분을 다룰 소의 이익

<쟁점>

- 사업의 양도행위가 무효라고 주장하는 양도자가 양도·양수행위의 무효를 구함이 없이 사업양도·양수에 따른 허가관청의 지위승계 신고수리처분의 무효확인을 구할 법률상 이익이 있는지 여부(적극)

<판결요지>

- 사업양도·양수에 따른 허가관청의 지위승계신고의 수리는 적법한 사업의 양도·양수가 있었음을 전제로 하는 것이므로 그 수리대상인 사업양도·양수가 존재하지 아니하거나 무효인 때에는 수리를 하였다 하더라도 그 수리는 유효한 대상이 없는 것으로서 당연히 무효라 할 것이고, 사업의 양도행위가 무효라고 주장하는 양도자는 민사쟁송으로 양도·양수행위의 무효를 구함이 없이 막바로 허가관청을 상대로 하여 행정소송으로 위 신고수리처분의 무효확인을 구할 법률상 이익이 있다.

<선정이유>

- 영업자지위승계신고의 수리는 강학상 인가와 본질을 달리하므로 전제인 사업양도·양수가 무효인 경우 바로 허가관청의 지위승계신고의 수리처분의 무효확인을 구할 협의의 소익이 있다는 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

359. 소의 이익 (13) : 거부처분에 대한 취소재결

“대법원 2017. 10. 31. 선고 2015두45045 판결”

<주제>

- 거부처분 취소재결의 취소를 구할 소의 이익

<쟁점>

- 당사자의 신청을 받아들이지 않은 거부처분이 재결에서 취소된 경우, 재결의 취소를 구할 법률상 이익이 있는지 여부(소극)

<판결요지>

- 행정청이 한 처분 등의 취소를 구하는 소송은 처분에 의하여 발생한 위법 상태를 배제하여 원래상태로 회복시키고 처분으로 침해된 권리나 이익을 구제하고자 하는 것이다. 따라서 해당 처분 등의 취소를 구하는 것보다 실효적이고 직접적인 구제수단이 있음에도 처분 등의 취소를 구하는 것은 특별한 사정이 없는 한 분쟁해결의 유효적절한 수단이라고 할 수 없어 법률상 이익이 있다고 할 수 없다.

- 그런데 당사자의 신청을 받아들이지 않은 거부처분이 재결에서 취소된 경우에 행정청은 종전 거부처분 또는 재결 후에 발생한 새로운 사유를 내세워 다시 거부처분을 할 수 있다. 그 재결의 취지에 따라 이전의 신청에 대하여 다시 어떠한 처분을 하여야 할지는 처분을 할 때의 법령과 사실을 기준으로 판단하여야 하기 때문이다. 또한 행정청이 재결에 따라 이전의 신청을 받아들이는 후속처분을 하였더라도 후속처분이 위법한 경우에는 재결에 대한 취소소송을 제기하지 않고도 곧바로 후속처분에 대한 항고소송을 제기하여 다룰 수 있다. 나아가 거부처분을 취소하는 재결이 있더라도 그에 따른 후속처분이 있기까지는 제3자의 권리나 이익에 변동이 있다고 볼 수 없고 후속처분 시에 비로소 제3자의 권리나 이익에 변동이 발생하며, 재결에 대한 항고소송을 제기하여 재결을 취소하는 판결이 확정되더라도 그와 별도로 후속처분이 취소되지 않는 이상 후속처분으로 인한 제3자의 권리나 이익에 대한 침해상태는 여전히 유지된다. 이러한 점들을 종합하면, 거부처분이 재결에서 취소된 경우 재결에 따른 후속처분이 아니라 그 재결의 취소를 구하는 것은 실효적이고 직접적인 권리구제수단이 될 수 없어 분쟁해결의 유효적절한 수단이라고 할 수 없으므로 법률상 이익이 없다.

<선정이유>

- 취소소송은 처분의 취소판결을 통해 실효적이고 직접적인 권리구제수단이 되어 분쟁해결의 유효적절한 수단이 되어야 한다는 협의의 소의 이익의 원칙을 거부처분 취소재결에 대한 취소소송에서 협의의 소의 부정을 통하여 보여준 판결

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

360. 소의 이익 (14) : 경원관계에서 탈락한 경원자

“대법원 2015. 10. 29. 선고 2013두27517 판결”

<주제>

- 경원관계에서 탈락한 경원자가 자신에 대한 거부처분의 취소를 구할 소의 이익

<쟁점>

- 인가·허가 등 수익적 행정처분을 신청한 여러 사람이 서로 경원관계에 있는 경우, 허가 등 처분을 받지 못한 사람이 자신에 대한 거부처분의 취소를 구할 원고적격과 소의 이익이 있는지 여부(원칙적 적극)

<판결요지>

- 인가·허가 등 수익적 행정처분을 신청한 여러 사람이 서로 경원관계에 있어서 한 사람에 대한 허가 등 처분이 다른 사람에 대한 불허가 등으로 귀결될 수밖에 없을 때 허가 등 처분을 받지 못한 사람은 신청에 대한 거부처분의 직접 상대방으로서 원칙적으로 자신에 대한 거부처분의 취소를 구할 원고적격이 있고, 취소판결이 확정되는 경우 판결의 직접적인 효과로 경원자에 대한 허가 등 처분이 취소되거나 효력이 소멸되는 것은 아니더라도 행정청은

취소판결의 기속력에 따라 판결에서 확인된 위법사유를 배제한 상태에서 취소판결의 원고와 경원자의 각 신청에 관하여 처분요건의 구비 여부와 우열을 다시 심사하여야 할 의무가 있으며, 재심사 결과 경원자에 대한 수익적 처분이 직권취소되고 취소판결의 원고에게 수익적 처분이 이루어질 가능성을 완전히 배제할 수는 없으므로, 특별한 사정이 없는 한 경원관계에서 허가 등 처분을 받지 못한 사람은 자신에 대한 거부처분의 취소를 구할 소의 이익이 있다.

<선정이유>

- 경원자관계에서 허가 등 처분을 받지 못한 원고가 경원자에 대한 허가 등 처분의 취소소송이나 무효확인소송을 제기하여 구제받을 수 있을 뿐만 아니라, 자신의 신청에 대한 거부처분에 대한 취소소송을 통해 신청의 재심사와 그것을 통한 신청인용의 가능성을 인정받을 수도 있음을 확인한 판결

<제09장 무효등 확인소송.제02절 무효등 확인소송의 요건>

<제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

361. 소의 이익 (15) : 무효확인소송에서 소의 이익(보충성)

“대법원 2008. 3. 20. 선고 2007두6342 전원합의체 판결”

<주제>

- 행정처분의 무효확인을 구할 소의 이익

<쟁점>

- “행정소송법 제35조”에 규정된 무효확인을 구할 법률상 이익이 있는지를 판단할 때 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지를 따져보아야 하는지 여부(소극)

<판결요지>

- 행정소송은 행정청의 위법한 처분 등을 취소·변경하거나 그 효력 유무 또는 존재 여부를 확인함으로써 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고 공법상의 권리관계 또는 법 적용에 관한 다툼을 적정하게 해결함을 목적으로 하므로, 대등한 주체 사이의 사법상 생활관계에 관한 분쟁을 심판대상으로 하는 민사소송과는 목적, 취지 및 기능 등을 달리한다. 또한 “행정소송법 제4조”에서는 무효확인소송을 항고소송의 일종으로 규정하고 있고, “행정소송법 제38조 제1항”에서는 처분 등을 취소하는 확정판결의 기속력 및 행정청의 재처분 의무에 관한 “행정소송법 제30조”를 무효확인소송에도 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있다. 그리고 무효확인소송의 보충성을 규정하고 있는 외국의 일부 입법례와는 달리 우리나라 행정소송법에는 명문의 규정이 없어 이로 인한 명시적 제한이 존재하지 않는다. 이와 같은 사정을 비롯하여 행정에 대한 사법통제, 권익구제의 확대와 같은 행정소송의 기능 등을 종합하여 보면, 행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우에는 “행정소송법 제35조”에 규정된 무효확인을 구할 법률상 이익이 있다고 보아야 하고, 이와 별도로 무효확인소송의 보충성이 요구되는 것은 아니므로 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지 여부를 따질 필요가 없다고 해석함이 상당하다.

<선정이유>

- 무효확인소송의 보충성을 요구하던 종전 판례입장을 변경한 판결

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제01절 행정심판전치주의>

294. 사법(司法)절차의 준용

“헌법재판소 2001. 6. 28.자 2000헌바30 결정”

<주제>

- 사법절차 준용의 의미

<쟁점>

- 이의신청 및 심사청구를 거치지 아니하고서는 지방세 부과처분에 대하여 행정소송을 제기할 수 없도록 한 “지방세법 제78조 제2항”이, 행정심판에 사법절차를 준용하도록 한 “헌법 제107조 제3항” 및 재판청구권을 보장하는 “헌법 제27조”에 위반되는지 여부

<결정요지>

- [1] “헌법 제107조 제3항”은 재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다. 행정심판의 절차는 법률로 정하되, 사법절차가 준용되어야 한다고 규정하고 있으므로, 입법자가 행정심판을 전심절차가 아니라 종심절차로 규정함으로써 정식재판의 기회를 배제하거나, 어떤 행정심판을 필요적 전심절차로 규정하면서도 그 절차에 사법절차가 준용되지 않는다면 이는 위 헌법조항, 나아가 재판청구권을 보장하고 있는 “헌법 제27조”에도 위반되며, “헌법 제107조 제3항”은 사법절차가 준용될 것만을 요구하고 있으나 판단기관의 독립성과 공정성, 대심적 심리구조, 당사자의 절차적 권리보장 등의 면에서 사법절차의 본질적 요소를 현저히 결여하고 있다면 준용의 요청에 마저 위반된다.

- [2] 지방세 부과처분에 대한 이의신청 및 심사청구의 심의·의결기관인 지방세심의위원회는 그 구성과 운영에 있어서 심의·의결의 독립성과 공정성을 객관적으로 신뢰할 수 있는 토대를 충분히 갖추고 있다고 보기 어려운 점, 이의신청 및 심사청구의 심리절차에 사법절차적 요소가 매우 미흡하고 당사자의 절차적 권리보장의 본질적 요소가 결여되어 있다는 점에서 지방세법상의 이의신청·심사청구제도도 “헌법 제107조 제3항”에서 요구하는 사법절차 준용의 요청을 외면하고 있다고 할 것인데, “지방세법 제78조 제2항”은 이러한 이의신청 및 심사청구라는 2중의 행정심판을 거치지 아니하고서는 행정소송을 제기하지 못하도록 하고 있으므로 위 헌법 조항에 위반될 뿐만 아니라, 재판청구권을 보장하고 있는 “헌법 제27조 제3항”에도 위반된다 할

것이며, 나아가 필요적 행정심판전치주의의 예외사유를 규정한 "행정소송법 제18조 제2항, 제3항"에 해당하는 사유가 있어 행정심판제도의 본래의 취지를 살릴 수 없는 경우에까지 그러한 전심절차를 거치도록 강요한다는 점에서도 국민의 재판청구권을 침해한다 할 것이다.

<선정이유>

- 이의신청 및 심사청구를 거치지 아니하고서는 지방세 부과처분에 대하여 행정소송을 제기할 수 없도록 한 "지방세법 제78조 제2항"이, 행정심판에 사법절차를 준용하도록 한 "헌법 제107조 제3항" 및 재판청구권을 보장하는 "헌법 제27조"에 위반된다는 결정으로서 특별행정심판제도를 필요적 전치절차로 하는 것의 헌법적 허용한계를 밝히고 있다는 점에서 의미가 있는 결정

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제01절 행정심판전치주의>

295. 법률이 필요적 전치주의를 규정한 경우

“헌법재판소 2007. 1. 17.자 2005헌바86 결정”

<주제>

- 필요적 전치주의

<쟁점>

- 교원에 대한 징계처분에 관하여 재심청구를 거치지 아니하고서는 행정소송을 제기할 수 없도록 한 "국가공무원법 제16조 제2항" 중 교원에 대한 부분이 "헌법 제107조 제3항"에 위반되는지 여부

<결정요지>

- [1] 재심청구는 불복절차로 행정소송을 제기할 수 있으므로 재판의 전심절차로서의 한계를 준수하고 있고, 판단기관인 재심위원회의 구성과 운영에 있어서 심사·결정의 독립성과 공정성을 객관적으로 신뢰할 수 있으며, 교원지위법과 교원징계처분등의 재심에 관한 규정이 규정하고 있는 재심청구의 절차와 보완적으로 적용되는 행정심판법의 심리절차를 고려하여 보면 심리절차에 사법절차를 준용하고 있으므로, "헌법 제107조 제3항"에 위반된다고 할 수 없다.

- [2] 입법자는 행정심판을 통한 권리구제의 실효성, 행정청에 의한 자기시정의 개연성, 문제되는 행정처분의 특수성 등을 고려하여 행정심판을 임의적 전치절차로 할 것인지, 아니면 필요적 전치절차로 할 것인지를 결정하는 입법형성권을 가지고 있는데, 교원에 대한 징계처분은 그 적법성을 판단함에 있어서 전문성과 자주성에 기한 사전심사가 필요하고, 판단기관인 재심위원회의 독립성 및 공정성이 확보되어 있고 심리절차에 있어서도 상당한 정도로 사법절차가 준용되어 권리구제절차로서의 실효성을 가지고 있으며, 재판청구권의 제약은 경미한 데 비하여 그로 인하여 달성되는 공익은 크므로, 재심제도가 입법형성권의 한계를 벗어나 국민의 재판청구권을 침해하는 제도라고 할 수 없다.

<선정이유>

- 교원에 대한 징계처분에 관하여 재심청구를 거치지 아니하고서는 행정소송을 제기할 수 없도록 한 "국가공무원법 제16조 제2항" 중 교원에 대한 부분이 "헌법 제107조 제3항"에 위반되지 않는다는 결정으로서 특별행정심판제도를 필요적 전치절차로 하는 것의 헌법적 허용성을 밝히고 있다는 점에서 의미가 있는 결정

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

365. 제소기간 (1)

“대법원 2019. 8. 9. 선고 2019두38656 판결”

<주제>

- 처분의 효력이 발생하기 전에 제기한 취소소송의 제소기간

<쟁점>

- [1] 상대방 있는 행정처분은 상대방에게 고지되어야 효력이 발생하는지 여부(원칙적 적극) 및 상대방 있는 행정처분이 상대방에게 고지되지 않았으나 상대방이 다른 경로를 통해 행정처분의 내용을 알게 된 경우, 행정처분의 효력이 발생하는지 여부(소극)

- [2] 취소소송의 제소기간 기산점으로 "행정소송법 제20조 제1항"이 정한 처분 등이 있음을 안 날과 "같은 조 제2항"이 정한 처분 등이 있는 날의 의미 및 이러한 법리가 행정심판의 청구기간에 관해서도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극)

<판결요지>

- [1] 상대방 있는 행정처분은 특별한 규정이 없는 한 의사표시에 관한 일반법리에 따라 상대방에게 고지되어야 효력이 발생하고, 상대방 있는 행정처분이 상대방에게 고지되지 아니한 경우에는 상대방이 다른 경로를 통해 행정처분의 내용을 알게 되었다고 하더라도 행정처분의 효력이 발생한다고 볼 수 없다.

- [2] 취소소송의 제소기간 기산점으로 "행정소송법 제20조 제1항"이 정한 처분 등이 있음을 안 날은 유효한 행정처분이 있음을 안 날을, "같은 조 제2항"이 정한 처분 등이 있는 날은 그 행정처분의 효력이 발생한 날을 각 의미한다. 이러한 법리는 행정심판의 청구기간에 관해서도 마찬가지로 적용된다.

- [3] 피고가 인터넷 홈페이지에 처분의 결정 내용을 게시한 것만으로는 "행정절차법 제14조"에서 정한 바에 따라 송달이 이루어졌다고 볼 수 없고, 원고가 그 홈페이지에 접속하여 결정 내용을 확인하여 알게 되었다고 하더라도 마찬가지이다. 또한 피고가 이 사건 처분서를 "행정절차법 제14조 제1항"에 따라 원고 또는 그 대리인의 주소·거소(거소)·영업소·사무소로 송달하였거나 "같은 조 제3항" 또는 "제4항"에서 정한 요건을 갖추어 정보통신망을 이용하거나 혹은 관보, 공보, 게시판, 일간신문 중 하나 이상에 공고하고 인터넷에도 공고하는 방법으로 송달하였다는 점에 관한 주장·증명도

없다. 따라서 처분이 상대방인 원고에게 고지되어 효력이 발생하였다고 볼 수 없으므로, 이에 관하여 "구 공무원연금법 제80조 제2항"에서 정한 심사청구기간이나 "행정소송법 제20조 제1항", "제2항"에서 정한 취소소송의 제소기간이 진행한다고 볼 수 없다.

<선정이유>

- 상대방 있는 행정처분은 특별한 규정이 없는 한 의사표시에 관한 일반법리에 따라 상대방에게 고지되어야 효력이 발생하고, 그 고지가 없는 상태에서 다른 경로로 그 상대방이 알게 되었다고 하여도 처분의 효력이 발생하는 것이 아니므로 취소소송의 제소기간이 진행한다고 볼 수 없다고 함으로써, 제소기간에 관한 "행정소송법 제20조 제1항"의 처분등이 있음을 안 날과 "제2항"의 처분등이 있는 날의 의미를 밝힌 판결

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

366. 제소기간 (2)

“대법원 2007. 6. 14. 선고 2004두619 판결”

<주제>

- 고시 또는 공고에 의한 행정처분에 대한 취소소송에서 제소기간 기산일

<쟁점>

- 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우, 그에 대한 취소소송 제소기간의 기산일(=고시 또는 공고의 효력발생일)

<판결요지>

- 통상 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우에는 그 처분의 상대방이 불특정 다수인이고 그 처분의 효력이 불특정 다수인에게 일률적으로 적용되는 것이므로, 그 행정처분에 이해관계를 갖는 자가 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날 행정처분이 있음을 알았다고 보아야 한다.  
- 인터넷 웹사이트에 대하여 구 청소년보호법에 따른 청소년유해매체물 결정 및 고시처분을 한 사안에서, 위 결정은 이해관계인이 고시가 있었음을 알았는지 여부에 관계없이 관보에 고시됨으로써 효력이 발생하고, 그가 위 결정을 통지받지 못하였다는 것이 제소기간을 준수하지 못한 것에 대한 정당한 사유가 될 수 없다고 한 사례

<선정이유>

- 고시 또는 공고에 의하여 행정처분을 하는 경우 그 행정처분에 이해관계를 갖는 자가 고시 또는 공고가 있었다는 사실을 현실적으로 알았는지 여부에 관계없이 고시가 효력을 발생하는 날 행정처분이 있음을 알았다고 보아야 한다고 하여 처분의 상대방이 불특정 상대방인 경우 제소기간의 불안정성을 방지하고자 한 판결

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

367. 제소기간 (3)

“대법원 2004. 11. 25. 선고 2004두7023 판결”

<주제>

- 소의 변경이 있는 경우 새로운 소에 대한 제소기간 준수여부 기준시점

<쟁점>

- 취소소송에 있어서 소의 변경이 있는 경우, 새로운 소에 대한 소 제기기간 준수 여부의 기준시점(=소 변경시)

<판결요지>

- [1] 취소소송은 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하고, 처분 등이 있는 날부터 1년을 경과하면 제기하지 못하며("행정소송법 제20조 제1항, 제2항"), 청구취지를 변경하여 구소가 취하되고 새로운 소가 제기된 것으로 변경되었을 때에 새로운 소에 대한 제소기간의 준수 등은 원칙적으로 소의 변경이 있을 때를 기준으로 하여야 한다.  
- [2] 원고가 2002. 6. 26.자 처분인 이 사건 제2처분의 취소를 구하는 소를 제소기간 내에 제기하였다가 2002. 9. 9. 제1심에서 2000. 8. 5.자 처분인 이 사건 제1처분의 취소를 구하는 것으로 청구취지를 교환적으로 변경하였고, 2003. 9. 23. 원심에서 다시 청구취지를 교환적으로 변경하여 이 사건 제1처분의 실효확인과 제2처분의 취소를 선택적으로 청구하는 경우, 위 2003. 9. 23.자 청구취지의 변경은 원고가 이 사건 제2처분이 있음을 안 날로부터 90일, 그 처분이 있는 날로부터 1년을 경과한 후에 이루어진 것이기 역수상 명백하므로 이 사건 소 중 이 사건 제2처분에 관한 취소청구 부분의 소는 제소기간을 준수하지 못하여 부적법하다고 본 사례

<선정이유>

- 취소소송에서 청구취지를 변경하여 구 소가 취하되고 새로운 소가 제기된 것으로 변경되었을 때에 새로운 소에 대한 제소기간의 준수 등은 원칙적으로 소의 변경이 있을 때를 기준으로 하여야 한다고 하여 소 변경 시 제소기간의 기준시점을 명확히 한 판결

<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>

368. 제소기간 (4)

**“대법원 2014. 4. 24. 선고 2013두10809 판결”**

**<주제>**

- "행정소송법 제20조 제1항"에서 말하는 행정심판의 의미

**<쟁점>**

- "행정소송법 제20조 제1항"에서 말하는 행정심판의 의미

**<판결요지>**

- [1] "행정소송법 제20조 제1항"에 따르면, 취소소송은 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하는데, 행정심판청구를 할 수 있는 경우에 행정심판청구가 있는 때의 기간은 재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산한다. 이처럼 취소소송의 제소기간을 제한함으로써 처분 등을 둘러싼 법률관계의 안정과 신속한 확정을 도모하려는 입법 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 행정심판은 "행정심판법"에 따른 일반행정심판과 이에 대한 특례로서 다른 법률에서 사안의 전문성과 특수성을 살리기 위하여 특히 필요하여 일반행정심판을 갈음하는 특별한 행정불복절차를 정한 경우의 특별행정심판("행정심판법 제4조")을 뜻한다.

- [2] 갑 광역시 교육감이 "공공감사에 관한 법률(이하 '공공감사법') 등"에 따라 을 학교법인이 운영하는 병 고등학교에 대한 특정감사를 실시한 후 병 학교의 학교장과 직원에 대하여 징계(해임)를 요구하는 처분을 하였는데, 을 법인이 위 처분에 대한 이의신청을 하였다가 기각되자 위 처분의 취소를 구하는 소를 제기한 사안에서, "공공감사법"상의 재심의신청 및 구 갑 광역시교육청 행정감사규정상의 이의신청은 자체감사를 실시한 중앙행정기관 등의 장으로 하여금 감사결과나 그에 따른 요구사항의 적법·타당 여부를 스스로 다시 심사하도록 한 절차로서 행정심판을 거친 경우의 제소기간의 특례가 적용될 수 없다고 보고, 이의신청에 대한 결과통지일이 아니라 을 법인이 위 처분이 있음을 알았다고 인정되는 날부터 제소기간을 기산하여 위 소가 제소기간의 도과로 부적법하다고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례

**<선정이유>**

- 행정심판신청이 청구를 할 수 있는 경우에 행정심판청구가 있는 때의 제소기간은 재결서의 정본을 송달받은 날부터 기산하도록 하고 있는 "행정소송법 제20조 제1항"에서 말하는 행정심판의 의미에 관한 판결

**<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>**

**369. 제소기간 (5)**

**“대법원 2007. 4. 27. 선고 2004두9302 판결”**

**<주제>**

- 변경명령재결에 따라 당초처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우 제소기간의 판단 기준

**<쟁점>**

- 행정청이 식품위생법령에 따라 영업자에게 행정제재처분을 한 후 당초처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우, 취소소송의 대상 및 제소기간 판단 기준이 되는 처분(=당초처분)

**<판결요지>**

- [1] 행정청이 식품위생법령에 따라 영업자에게 행정제재처분을 한 후 그 처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우, 변경처분에 의하여 당초처분은 소멸하는 것이 아니고 당초부터 유리하게 변경된 내용의 처분으로 존재하는 것이므로, 변경처분에 의하여 유리하게 변경된 내용의 행정제재가 위법하다 하여 그 취소를 구하는 경우 그 취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초처분이지 변경처분은 아니고, 제소기간의 준수 여부도 변경처분이 아닌 변경된 내용의 당초처분을 기준으로 판단하여야 한다.

- [2] 피고는 2002. 12. 26. 원고에 대하여 3월의 영업정지처분이라는 이 사건 당초처분을 하였고, 이에 대하여 원고가 행정심판청구를 하자 재결청은 2003. 3. 6. '피고가 2002. 12. 26. 원고에 대하여 한 3월의 영업정지처분을 2월의 영업정지에 갈음하는 과징금부과처분으로 변경하라'는 일부기각(일부 인용)의 이행재결을 하였으며, 2003. 3. 10. 그 재결서 정본이 원고에게 도달한 사실, 피고는 위 재결취지에 따라 2003. 3. 13. '3월의 영업정지처분을 과징금 560만 원으로 변경한다'는 취지의 이 사건 후속 변경처분을 하였으며, 원고는 2003. 6. 12. 이 사건 소를 제기하면서 청구취지로서 2003. 3. 13.자 과징금부과처분의 취소를 구하고 있다.

- 이 사건 후속 변경처분에 의하여 유리하게 변경된 내용의 행정제재인 과징금부과가 위법하다 하여 그 취소를 구하는 이 사건 소송에 있어서 위 청구 취지는 이 사건 후속 변경처분에 의하여 당초부터 유리하게 변경되어 존속하는 2002. 12. 26.자 과징금부과처분의 취소를 구하고 있는 것으로 보아야 할 것이고, 일부기각(일부 인용)의 이행재결에 따른 후속 변경처분에 의하여 변경된 내용의 당초처분의 취소를 구하는 이 사건 소 또한 행정심판재결서 정본을 송달받은 날로부터 90일 이내 제기되어야 하는데 원고가 위 재결서의 정본을 송달받은 날로부터 90일이 경과하여 이 사건 소를 제기하였다는 이유로 이 사건 소가 부적법하다고 판단한 원심판결은 정당하다.

**<선정이유>**

- 행정청이 영업자에게 행정제재처분을 한 후 그 처분을 영업자에게 유리하게 변경하는 처분을 한 경우, 변경처분에 의하여 당초처분은 소멸하는 것이 아니고 당초부터 유리하게 변경된 내용의 처분으로 존재하는 것이므로, 변경처분에 의하여 유리하게 변경된 내용의 행정제재가 위법하다 하여 그 취소를 구하는 경우 그 취소소송의 대상은 변경된 내용의 당초처분이지 변경처분은 아니고, 제소기간의 준수 여부도 변경처분이 아닌 변경된 내용의 당초처분을 기준으로 판단하여야 한다는 판결

**<제04장 취소소송의 기타 소송요건.제02절 제소기간>**

**370. 제소기간 (6)**

“대법원 2007. 4. 27. 선고 2004두9302 판결”

<주제>

- 행정청의 행정심판청구기간 오고지가 행정소송의 제소기간에 미치는 영향

<쟁점>

- [1] “행정소송법 제20조 제1항, 제3항”의 제소기간의 법적 성질(=불변기간) 및 “같은 법 제8조”에 의하여 제소행위의 추완에 준용되는 “민사소송법 제160조 제1항” 소정의 당사자가 책임질 수 없는 사유의 의미
- [2] 행정심판청구기간에 관한 “행정심판법 제18조 제5항”의 규정이 행정소송 제기에도 당연히 적용되는지 여부(소극)
- [3] 행정청으로부터 행정처분이나 그 이후 행정심판 제기기간에 관하여 법정 심판청구기간보다 긴 기간으로 잘못 통지받아 행정소송법상 법정 제소기간을 도과한 경우, 그것이 당사자가 책임질 수 없는 사유에 해당하는지 여부(소극)

<판결요지>

- [1] “행정소송법 제20조 제1항, 제3항”에서 말하는 취소소송은 처분 등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 한다.는 제소기간은 불변기간이고, 다만 당사자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 이를 준수할 수 없었던 경우에는 “같은 법 제8조”에 의하여 준용되는 “민사소송법 제160조 제1항”에 의하여 그 사유가 없어진 후 2주일 내에 해태된 제소행위를 추완할 수 있다고 할 것이며, 여기서 당사자가 책임질 수 없는 사유란 당사자가 그 소송행위를 하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 말한다.
- [2] 행정청이 법정 심판청구기간보다 긴 기간으로 잘못 알린 경우에 그 잘못 알린 기간 내에 심판청구가 있으면 그 심판청구는 법정 심판청구기간 내에 제기된 것으로 본다는 취지의 “행정심판법 제18조 제5항”의 규정은 행정심판 제기에 관하여 적용되는 규정이지, 행정소송 제기에도 당연히 적용되는 규정이라고 할 수는 없다.
- [3] 행정심판과 행정소송은 그 성질, 불복사유, 제기기간, 판단기관 등에서 본질적인 차이점이 있고, 임의적 전치주의는 당사자가 행정심판과 행정소송의 유·불리를 스스로 판단하여 행정심판을 거칠지 여부를 선택할 수 있도록 한 취지에 불과하므로 어느 쟁송 형태를 취한 이상 그 쟁송에는 그에 관련된 법률 규정만이 적용될 것이지 두 쟁송 형태에 관련된 규정을 통틀어 당사자에게 유리한 규정만이 적용된다고 할 수는 없으며, 행정처분이나 그 이후 행정청으로부터 행정심판 제기기간에 관하여 법정심판청구기간보다 긴 기간으로 잘못 통지받은 경우에 보호할 신뢰 이익은 그 통지받은 기간 내에 행정심판을 제기한 경우에 한하는 것이지 행정소송을 제기한 경우에 까지 확대된다고 할 수 없으므로, 당사자가 행정처분이나 그 이후 행정청으로부터 행정심판 제기기간에 관하여 법정심판청구기간보다 긴 기간으로 잘못 통지받아 행정소송법상 법정 제소기간을 도과하였다고 하더라도, 그것이 당사자가 책임질 수 없는 사유로 인한 것이라고 할 수는 없다.

<선정이유>

- 제소기간 오고지에 대한 “행정심판법”의 규정(“현 제27조 제5항”)은 그 본질에 있어서 차이가 있으므로 행정소송 제기에 적용되지 않는다고 한 판결

<제05장 취소소송의 심리.제01절 심리>

378. 직권심리주의 (1)

“대법원 1994. 10. 11. 선고 94누4820 판결”

<주제>

- 직권심리의 범위와 한계

<쟁점>

- 행정소송에 있어서의 법원의 직권조사 범위

<판결요지>

- “행정소송법 제26조”가 법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다고 규정하고 있지만, 이는 행정소송의 특수성에 연유하는 당사자주의, 변론주의에 대한 일부 예외 규정일 뿐 법원이 아무런 제한 없이 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판단할 수 있는 것은 아니고, 일건 기록에 현출되어 있는 사항에 관하여서만 직권으로 증거조사를 하고 이를 기초로 하여 판단할 수 있을 따름이고, 그것도 법원이 필요하다고 인정할 때에 한하여 청구의 범위내에서 증거조사를 하고 판단할 수 있을 뿐이다.

<선정이유>

- 직권심리의 범위와 한계에 관한 판결로서 “행정소송법 제26조” 직권심리규정은 변론주의의 원칙을 보충하는 규정이라는 변론주의보충설을 법원이 취하고 있음을 보여준 판결

<제05장 취소소송의 심리.제01절 심리>

379. 직권심리주의 (2)

“대법원 2010. 2. 11. 선고 2009두18035 판결”

<주제>

- 직권심리의 범위와 직권탐지의무

<쟁점>

- 행정소송에서 기록상 자료가 나타나 있다면 당사자가 주장하지 않더라도 판단할 수 있는지 여부(적극)

#### <판결요지>

- 행정소송에서 기록상 자료가 나타나 있다면 당사자가 주장하지 않았더라도 판단할 수 있고, 당사자가 제출한 소송자료에 의하여 법원이 처분의 적법 여부에 관한 합리적인 의심을 품을 수 있음에도 단지 구체적 사실에 관한 주장을 하지 아니하였다는 이유만으로 당사자에게 석명을 하거나 직권으로 심리·판단하지 아니함으로써 구체적 타당성이 없는 판결을 하는 것은 "행정소송법 제26조"의 규정과 행정소송의 특수성에 반하므로 허용될 수 없다.

#### <선정이유>

- 종래 인정되어 온 직권심리의 범위보다 직권탐지에 대해 적극적인 태도를 표명한 판결

### <제05장 취소소송의 심리.제01절 심리>

#### 380. 직권심리주의 (3)

“대법원 2013. 8. 22. 선고 2011두26589 판결”

##### <주제>

- 직권심리의 범위와 한계

##### <쟁점>

- 행정청이 공무수행과 상이 사이에 인과관계가 없다는 이유로 국가유공자 비해당결정을 한 데 대하여 법원이 인과관계의 존재는 인정하면서 직권으로 본인 과실이 경합된 사유가 있다는 이유로 그 처분이 정당하다고 판단하는 것이 적법한지 여부(소극)

#### <판결요지>

- 국가유공자 인정 요건, 즉 공무수행으로 상이를 입었다는 점이나 그로 인한 신체장애의 정도가 법령에 정한 등급 이상에 해당한다는 점은 국가유공자 등록신청인이 증명할 책임이 있지만, 그 상이가 불가피한 사유 없이 본인의 과실이나 본인의 과실이 경합된 사유로 입은 것이라는 사정, 즉 지원대상자 요건에 해당한다는 사정은 국가유공자 등록신청에 대하여 지원대상자로 등록하는 처분을 하는 처분청이 증명책임을 진다고 보아야 한다. 이러한 점과 더불어 공무수행으로 상이를 입었는지 여부와 그 상이가 불가피한 사유 없이 본인의 과실이나 본인의 과실이 경합된 사유로 입은 것인지 여부는 처분의 상대방의 입장에서 볼 때 방어권 행사의 대상과 방법이 서로 다른 별개의 사실이고, 그에 대한 방어권을 어떻게 행사하는지 등에 따라 국가유공자에 해당하는지 지원대상자에 해당하는지에 관한 판단이 달라져 법령상 서로 다른 처우를 받을 수 있는 점 등을 종합해 보면, 같은 국가유공자 비해당결정이라도 그 사유가 공무수행과 상이 사이에 인과관계가 없다는 것과 본인 과실이 경합되어 있어 지원대상자에 해당할 뿐이라는 것은 기본적 사실관계의 동일성이 없다고 보아야 한다. 따라서 처분청이 공무수행과 사이에 인과관계가 없다는 이유로 국가유공자 비해당결정을 한 데 대하여 법원이 그 인과관계의 존재는 인정하면서 직권으로 본인 과실이 경합된 사유가 있다는 이유로 그 처분이 정당하다고 판단하는 것은 행정소송법이 허용하는 직권심사주의의 한계를 벗어난 것으로서 위법하다.

#### <선정이유>

- 직권심리의 범위와 한계에 관한 판결로서, 행정소송에서 당사자주의나 변론주의 원칙은 그대로 유효하고, 따라서 새로운 사유를 인정하여 처분의 정당 여부를 판단하는 것은 당초 처분사유와 기본적 사실관계에 있어서 동일성이 인정되는 한도 내에서만 허용된다는 법리를 확인한 판결

### <제05장 취소소송의 심리.제01절 심리>

#### 387. 증명책임 (1) : 취소소송에서 증명책임

“대법원 1996. 4. 26. 선고 96누1627 판결”

##### <주제>

- 취소소송에서 증명책임

##### <쟁점>

- 과세처분취소소송에 있어서의 입증책임 및 입증의 필요

#### <판결요지>

- 과세처분의 위법을 이유로 그 취소를 구하는 행정소송에 있어 처분의 적법성 및 과세요건사실의 존재에 관하여는 원칙적으로 과세관청이 그 입증책임을 부담하나, 경험칙상 이례에 속하는 특별한 사정의 존재에 관하여는 납세의무자에게 입증책임 내지는 입증의 필요가 돌아가는 것이고, 납세의무자가 법인세 신고시 손금으로 신고한 노무비 중 일부가 실지비용인지 여부가 다투어진 사건에서 과세관청에 의하여 위 노무비 중 일부가 장부상 2중으로 계상되었음이 밝혀졌다면, 특별한 사정이 없는 한 그 2중 계상은 추정된다 할 것이므로 위 노무비를 장부상 2중으로 계상한 것이 일용노무자의 노임에 대한 갑종근로소득세의 원천징수를 피하기 위한 편법이었을 뿐이고, 위 노무비도 실제로 노임으로 지급된 비용이라는 사실은 그 구체적 비용지출 사실에 관한 장부기장과 증빙 등 일체의 자료를 제출하기 용이한 납세의무자가 이를 반증할 필요가 있다.

#### <선정이유>

- 과세처분취소소송에서의 입증책임 분배기준을 제시한 판결

<제05장 취소소송의 심리.제01절 심리>

388. 증명책임 (2) : 무효확인소송에서 증명책임

“대법원 2010. 5. 13. 선고 2009두3460 판결”

<주제>

- 무효확인소송에서 증명책임

<쟁점>

- 행정처분무효확인소송에서 행정처분의 무효 사유에 대한 증명책임자(=원고) 및 구치소 등에 구속된 사람에 대한 납세고지서의 송달 방법

<판결요지>

- 행정처분의 당연무효를 주장하여 그 무효확인을 구하는 행정소송에 있어서는 원고에게 그 행정처분이 무효인 사유를 주장·입증할 책임이 있다. 한편 국세기본법에는 “민사소송법 제182조”(구속된 사람 등에게 할 송달)와 같은 특별규정이나 민사소송법 중 송달에 관한 규정을 준용하는 규정이 없으므로, 구치소 등에 구속된 사람에 대한 납세고지서의 송달은 특별한 사정이 없으면 “국세기본법 제8조 제1항”에 따라 주소·거소·영업소 또는 사무소로 하면 되고, 이 경우 그 곳에서 송달받을 사람을 만나지 못한 때에는 그 사용인 기타 종업원 또는 동거인으로서 사리를 판별할 수 있는 사람에게 송달할 수 있다.

<선정이유>

- 무효확인소송의 경우 원고에게 행정처분이 무효인 사유를 주장·입증할 책임이 있다고 판시한 판결

<제05장 취소소송의 심리.제03절 처분사유의 추가·변경>

384. 처분사유의 추가·변경 (1) : 기본적 사실관계의 동일성

“대법원 2003. 12. 11. 선고 2001두8827 판결”

<주제>

- 처분사유 추가·변경의 한계

<쟁점>

- [1] 행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서 당초의 처분사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없는 별개의 사실을 처분사유로 주장하는 것을 허용하지 아니하는 입법취지 및 추가 또는 변경된 사유가 당초의 처분시 이미 존재하고 있었고 당사자도 그 사실을 알고 있었다 하여 당초의 처분사유와 동일성이 있는 것인지 여부(소극)  
- [2] 당초의 정보공개거부처분사유인 “공공기관의정보공개에관한법률 제7조 제1항 제4호 및 제6호”의 사유는 새로이 추가된 “같은 항 제5호”의 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않는다고 한 사례

<판결요지>

- [1] 행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서, 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있고, 여기서 기본적 사실관계의 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지 여부에 따라 결정되며 이와 같이 기본적 사실관계와 동일성이 인정되지 않는 별개의 사실을 들어 처분사유로 주장하는 것이 허용되지 않는다고 해석하는 이유는 행정처분의 상대방의 방어권을 보장함으로써 실질적 법치주의를 구현하고 행정처분의 상대방에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 취지가 있고, 추가 또는 변경된 사유가 당초의 처분시 그 사유를 명기하지 않았을 뿐 처분시에 이미 존재하고 있었고 당사자도 그 사실을 알고 있었다 하여 당초의 처분사유와 동일성이 있는 것이라 할 수 없다.  
- [2] 당초의 정보공개거부처분사유인 “공공기관의정보공개에관한법률 제7조 제1항 제4호” 및 “제6호”의 사유는 새로이 추가된 “같은 항 제5호”의 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없다고 한 사례

<선정이유>

- 처분사유의 추가·변경의 한계 및 취지와 그 허용기준인 기본적 사실관계의 동일성의 의미에 관한 판결

<제05장 취소소송의 심리.제03절 처분사유의 추가·변경>

385. 처분사유의 추가·변경 (2) : 처분 근거법령의 변경

“대법원 2011. 5. 26. 선고 2010두28106 판결”

<주제>

- 처분의 근거 법령 변경이 허용되지 않는 경우

<쟁점>

- [1] 도로법 적용을 받는 도로가 되기 위한 요건  
- [2] 행정청이 도로 일부를 침범하고 있는 건물 소유자들에게 “도로법 제94조”에 따라 변상금 부과처분을 한 사안에서, 위 도로는 도로법 적용을 받는 도로라고 할 수 없으므로, 이와 달리 본 원심판결에 위법이 있다고 한 사례

- [3] 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 처분의 근거 법령만을 추가·변경하는 것이 허용되는지 여부(원칙적 적극) 및 처분의 근거 법령 변경이 허용되지 아니하는 경우

- [4] 행정청이 점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 사람에 대하여 "도로법 제94조"에 의한 변상금부과처분을 하였다가, 처분에 대한 취소소송이 제기된 후 해당 도로가 도로법 적용을 받는 도로에 해당하지 않을 경우를 대비하여 처분의 근거 법령을 "구 국유재산법 제51조"와 그 시행령 등으로 변경하여 주장한 사안에서, 위와 같이 근거 법령을 변경하는 것은 종전 "도로법 제94조"에 의한 변상금 부과처분과 동일성을 인정할 수 없는 별개의 처분을 하는 것과 다름 없어 허용될 수 없으므로, 이와 달리 판단한 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

#### <판결요지>

- [1] 도로는 도로의 형태를 갖추고, 도로법에 따른 노선 지정 또는 인정 공고 및 도로구역 결정·고시를 한 때 또는 도시계획법이나 도시재개발법에서 정한 절차를 거쳐야 비로소 도로법 적용을 받는 도로로 되는 것이고, 도로로 실제 사용되었다는 사정만으로는 도로법 적용을 받는 도로라고 할 수 없다.

- [2] 행정청이 도로 일부를 침범한 건물 소유자들에게 사용·수익허가 없이 해당 도로를 무단 점유하고 있다는 이유로 "도로법 제94조"에 따라 변상금 부과처분을 한 사안에서, 위 도로가 도로법에 따른 노선 지정 또는 인정 공고 및 도로구역 결정·고시되었다는 점을 인정할 자료가 없고, 일반인의 통행을 위한 도로로 실제 사용되어 온 사정만으로는 도로법 적용을 받는 도로라고 할 수 없으므로, 위 도로가 도로법 적용을 받는 도로에 해당한다고 보아 변상금 부과처분이 적법하다고 본 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례.

- [3] 행정처분이 적법한지는 특별한 사정이 없는 한 처분 당시 사유를 기준으로 판단하면 되고, 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실을 변경하지 아니하는 범위 내에서 단지 처분의 근거 법령만을 추가·변경하는 것은 새로운 처분사유의 추가라고 볼 수 없으므로 이와 같은 경우에는 처분청이 처분 당시 적시한 구체적 사실에 대하여 처분 후 추가·변경한 법령을 적용하여 처분의 적법 여부를 판단하여도 무방하다. 그러나 처분의 근거 법령을 변경하는 것이 종전 처분과 동일성을 인정할 수 없는 별개의 처분을 하는 것과 다름 없는 경우에는 허용될 수 없다.

- [4] 행정청이 점용허가를 받지 않고 도로를 점용한 사람에 대하여 "도로법 제94조"에 의한 변상금부과처분을 하였다가 처분에 대한 취소소송이 제기된 후 해당 도로가 도로법의 적용을 받는 도로에 해당하지 않을 경우를 대비하여 처분의 근거 법령을 도로의 소유자가 국가인 부분은 "구 국유재산법 제51조"와 "그 시행령" 등으로, 소유자가 서울특별시 종로구인 부분은 "구 공유재산 및 물품관리법 제81조"와 "그 시행령" 등으로 변경하여 주장한 사안에서, 도로법과 구 국유재산법령 및 구 공유재산 및 물품관리법령의 해당 규정은 별개 법령에 규정되어 입법 취지가 다르고, 해당 규정내용을 비교하여 보면 변상금의 징수목적, 산정 기준금액, 징수 재량 유무, 징수절차 등이 서로 달라 위와같이 근거 법령을 변경하는 것은 종전 "도로법 제94조"에 의한 변상금 부과처분과 동일성을 인정할 수 없는 별개의 처분을 하는 것과 다름 없어 허용될 수 없으므로, 이와 달리 판단한 원심판결에 법리를 오해한 위법이 있다고 한 사례

#### <선정이유>

- 처분의 근거법령만을 추가·변경하는 것은 새로운 처분사유의 추가·변경이라고 볼 수 없으나, 종전 처분과 동일성을 인정할 수 없는 별개의 처분과 다름없는 근거법령의 변경은 허용될 수 없다고 판시한 판결

### <제05장 취소소송의 심리.제03절 처분사유의 추가·변경>

#### 386. 처분사유의 추가·변경 (3) : 처분사유의 근거가 되는 기초사실 내지 평가요소의 추가

"대법원 2018. 12. 13. 선고 2016두31616 판결"

#### <주제>

- 처분사유 추가·변경의 한계

#### <쟁점>

- [1] "구 국적법 제5조 각호" 사유 중 일부를 갖추지 못하였다는 이유로 행정청이 귀화 신청을 받아들이지 않는 처분을 한 경우, 그 각호 사유 중 일부를 갖추지 못하였다는 판단 자체가 처분의 사유인지 여부(적극)

- [2] 외국인 갑이 법무부장관에게 귀화신청을 하였으나 법무부장관이 심사를 거쳐 품행 미단정을 불허사유로 국적법상의 요건을 갖추지 못하였다고 신청을 받아들이지 않는 처분을 하였는데, 법무부장관이 갑을 품행 미단정이라고 판단한 이유에 대하여 제1심 변론절차에서 자동차관리법위반죄로 기소유예를 받은 전력 등을 고려하였다고 주장하였다가 원심 변론절차에서 불법 체류한 전력이 있다는 추가적인 사정까지 고려하였다고 주장한 사안에서, 법무부장관이 원심에서 추가로 제시한 불법 체류 전력 등의 제반 사정은 처분사유의 근거가 되는 기초 사실 내지 평가요소에 지나지 않으므로, 추가로 주장할 수 있다고 한 사례

#### <판결요지>

- [1] "구 국적법 제5조 각호"와 같이 귀화는 요건이 항목별로 구분되어 구체적으로 규정되어 있다. 그리고 성질상 행정절차를 거치기 곤란하거나 거칠 필요가 없다고 인정되어 처분의 이유제시 등을 규정한 행정절차법이 적용되지 않는다("제3조 제2항 제9호"). 귀화의 이러한 특수성을 고려하면, 귀화의 요건인 "구 국적법 제5조 각호" 사유 중 일부를 갖추지 못하였다는 이유로 행정청이 귀화 신청을 받아들이지 않는 처분을 한 경우에 그 각호 사유 중 일부를 갖추지 못하였다는 판단 자체가 처분의 사유가 된다.

- [2] 외국인 갑이 법무부장관에게 귀화신청을 하였으나 법무부장관이 심사를 거쳐 품행 미단정을 불허사유로 국적법상의 요건을 갖추지 못하였다고 신청을 받아들이지 않는 처분을 하였는데, 법무부장관이 갑을 품행 미단정이라고 판단한 이유에 대하여 제1심 변론절차에서 자동차관리법위반죄로 기소유예를 받은 전력 등을 고려하였다고 주장하였다가 원심 변론절차에서 불법 체류한 전력이 있다는 추가적인 사정까지 고려하였다고 주장한 사안에서, 법무부장관이 처분 당시 갑의 전력등을 고려하여 갑이 "구 국적법 제5조 제3호"의 품행단정 요건을 갖추지 못하였다고 판단하여 처분을 하였고, 그 처분서에 처분사유로 품행 미단정이라고 기재하였으므로, 품행 미단정이라는 판단 결과를 위 처분의 처분사유로 보아야 하는데, 법무부장관이 원심에서 추가로 제시한 불법 체류 전력 등의 제반 사정은 불허가처분의 처분사유 자체가 아니라 그 근거가 되는 기초 사실 내지 평가요소에 지나지 않으므로, 법무부장관이 이러한 사정을 추가로 주장할 수 있다고 한 사례

#### <선정이유>

- 처분사유의 추가·변경의 한계와 관련하여 불허가처분의 처분사유 자체가 아니라 그 근거가 되는 기초사실 내지 평가요소에 지나지 않는 사정은 추가로 주장할 수 있다고 판시한 판결

**<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>**

**389. 기속행위의 일부취소판결 (1)**

**“대법원 2004. 7. 22. 선고 2002두868 판결”**

**<주제>**

- 기속행위의 일부취소판결 가부

**<쟁점>**

- 개발부담금부과처분 취소소송에 있어서 취소의 범위

**<판결요지>**

- 개발부담금부과처분 취소소송에 있어 당사자가 제출한 자료에 의하여 적법하게 부과될 정당한 부과금액이 산출할 수 없을 경우에는 부과처분 전부를 취소할 수밖에 없으나, 그렇지 않은 경우에는 그 정당한 금액을 초과하는 부분만 취소하여야 한다.

**<선정이유>**

- 개발부담금부과처분 취소소송의 경우 일부취소의 허용 여부 및 취소의 범위에 관하여 판시한 판결

**<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>**

**390. 기속행위의 일부취소판결 (2)★**

**“대법원 2012. 3. 29. 선고 2011두9263 판결”**

**<주제>**

- 기속행위의 일부취소판결 가부

**<쟁점>**

- 여러 개의 상이에 대한 국가유공자요건비해당처분에 대한 취소소송에서 그 중 일부 상이가 국가유공자요건이 인정되는 상이에 해당하고 나머지 상이는 해당하지 않는 경우, 비해당처분 전부를 취소해야 하는지 여부(소극)

**<판결요지>**

- "국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제4조 제1항 제6호" 등 관련 법령의 내용, 형식 및 입법취지를 비롯하여 국가유공자등록신청 당시 신청인이 여러 개의 상이를 주장함으로써 국가유공자요건의 관련 사실을 확인하는 과정에서 여러 개의 상이가 문제 되는 경우 각각의 상이 별로 국가유공자요건에 해당하는지 여부에 대한 심사가 이루어지는 점, 이에 따라 법의 적용대상자로 될 상이를 입은 것이 아닌 사람 또는 국가유공자요건이 인정되지 않은 상이에 대하여는 상이등급의 판정을 위한 신체검사를 실시하지 아니하는 점, 나아가 여러 개의 상이를 주장하면서 국가유공자등록신청을 한 신청인의 의사는 단지 국가유공자로 등록되는 데 그치는 것이 아니라 교육훈련 또는 직무수행 중 입은 각각의 상이의 정도와 그 상이등급에 상응하는 국가유공자로 등록해 줄 것을 구하는 것이라고 봄이 타당한 점, 외형상 하나의 행정처분이라 하더라도 가분성이 있거나 그 처분대상의 일부가 특정될 수 있다면 그 일부만의 취소도 가능하고 그 일부의 취소는 당해 취소부분에 관하여 효력이 생긴다고 할 것인 점 등을 종합하면, 여러 개의 상이에 대한 국가유공자요건비해당처분에 대한 취소소송에서 그 중 일부 상이가 국가유공자요건이 인정되는 상이에 해당하더라도 나머지 상이에 대하여 위 요건이 인정되지 아니하는 경우에는 국가유공자요건비해당처분 중 위 요건이 인정되는 상이에 대한 부분만을 취소하여야 할 것이고, 그 비해당처분 전부를 취소할 수는 없다고 할 것이다.

**<선정이유>**

- 여러 개의 상이에 대한 국가유공자요건비해당처분에 대한 취소소송에서 일부취소가 가능한 경우에는 전부취소를 하여서는 아니 되며 일부취소를 하여야 한다고 판시한 판결

**<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>**

**391. 재량행위에 대한 일부취소판결 (1)**

**“대법원 2007. 10. 26. 선고 2005두3172 판결”**

**<주제>**

- 재량행위의 일부취소판결 가부

**<쟁점>**

- 처분 여부와 처분 정도에 관하여 재량이 인정되는 공정거래위원회의 과징금 납부명령이 재량권을 일탈한 경우 및 수개의 위반행위에 대하여 하나의 과징금 납부명령을 하였으나 일부의 위반행위만이 위법하고 소송상 그 일부의 위반행위를 기초로 한 과징금액을 산정할 수 있는 자료가 없는 경우, 법원

이 취소해야 할 과징금 납부명령의 범위(=전부취소)

<판결요지>

- 처분을 할 것인지 여부와 처분의 정도에 관하여 재량이 인정되는 과징금 납부명령에 대하여 그 명령이 재량권을 일탈하였을 경우 법원으로서 재량권의 일탈 여부만 판단할 수 있을 뿐이지 재량권의 범위 내에서 어느 정도가 적절한 것인지에 관하여 판단할 수 없으므로 그 전부를 취소할 수밖에 없고, 법원이 적정하다고 인정되는 부분을 초과한 부분만 취소할 수는 없는 것이며(대법원 1998. 4. 10. 선고 98두2270 판결 참조), 또한 수 개의 위반행위에 대하여 하나의 과징금 납부명령을 하였으나 수 개의 위반행위 중 일부의 위반행위만이 위법하지만, 소송상 그 일부의 위반행위를 기초로 한 과징금액을 산정할 수 있는 자료가 없는 경우에는 하나의 과징금 납부명령 전부를 취소할 수밖에 없다(대법원 2004. 10. 14. 선고 2003두2881 판결 참조)

<선정이유>

- 과징금 납부명령과 같은 재량행위에 대해서 재량하자가 인정되는 경우 일부취소가 허용되지 않고 전부취소를 하여야 한다고 판시한 판결

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

392. 재량행위에 대한 일부취소판결 (2)★

“대법원 2020. 5. 14. 선고 2019두63515 판결”

<주제>

- 재량행위의 일부취소판결 가부

<쟁점>

- [1] 여러 처분사유에 관하여 하나의 제재처분을 하였을 때 그중 일부가 인정되지 않으나 나머지 처분사유들만으로도 처분의 정당성이 인정되는 경우, 그 처분을 위법하다고 보아 취소할 수 있는지 여부(소극)  
- [2] 행정청이 여러 개의 위반행위에 대하여 하나의 제재처분을 하였으나, 위반행위별로 제재처분의 내용을 구분하는 것이 가능하고 여러 개의 위반행위 중 일부의 위반행위에 대한 제재처분 부분만이 위법한 경우, 제재처분 전부를 취소할 수 있는지 여부(소극)

<판결요지>

- [1] 여러 처분사유에 관하여 하나의 제재처분을 하였을 때 그중 일부가 인정되지 않는다고 하더라도 나머지 처분사유들만으로도 처분의 정당성이 인정되는 경우에는 그 처분을 위법하다고 보아 취소하여서는 아니 된다.  
- [2] 행정청이 여러 개의 위반행위에 대하여 하나의 제재처분을 하였으나, 위반행위별로 제재처분의 내용을 구분하는 것이 가능하고 여러 개의 위반행위 중 일부의 위반행위에 대한 제재처분 부분만이 위법하다면, 법원은 제재처분 중 위법성이 인정되는 부분만 취소하여야 하고 제재처분 전부를 취소하여서는 아니 된다.

<선정이유>

- 재량행위에 속하는 폐기물처리업자에 대한 제재처분과 관련하여, 여러 처분사유에 관하여 하나의 제재처분을 하였으나, 제재처분의 내용을 구분하는 것이 가능하고 여러 개의 위반행위 중 일부의 위반행위에 대한 제재처분 부분만이 위법한 경우에는 제재처분 전부를 취소할 수는 없고 일부만 취소판결할 수 있다고 본 판결

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

393. 처분대상의 일부가 특정될 수 있는 경우의 취소판결

“대법원 1995. 11. 16. 선고 95누8850 전원합의체 판결”

<주제>

- 복수 운전면허의 일부 취소

<쟁점>

- [1] 한 사람이 여러 종류의 자동차 운전면허를 취득한 경우, 이를 취소·정지함에 있어서 서로 별개의 것으로 취급하여야 하는지 여부  
- [2] 외형상 하나의 행정처분이라 하더라도 가분성이 있거나 그 처분대상의 일부가 특정될 수 있는 경우, 일부 취소의 가능성

<판결요지>

- [1] 한 사람이 여러 종류의 자동차 운전면허를 취득하는 경우뿐 아니라 이를 취소 또는 정지함에 있어서도 서로 별개의 것으로 취급하여야 하는 것이 원칙이고, 한 사람이 여러 종류의 자동차 운전면허를 취득하는 경우 1개의 운전면허증을 발급하고 그 운전면허증의 면허번호는 최초로 부여한 면허번호로 하여 이를 통합관리하고 있다고 하더라도, 이는 자동차 운전면허증 및 그 면허번호 관리상의 편의를 위한 것에 불과할 뿐 그렇다고 하여 여러 종류의 면허를 서로 별개의 것으로 취급할 수 없다거나 각 면허의 개별적인 취소 또는 정지를 분리하여 집행할 수 없는 것은 아니다.  
- [2] 외형상 하나의 행정처분이라 하더라도 가분성이 있거나 그 처분대상의 일부가 특정될 수 있다면 그 일부만의 취소도 가능하고 그 일부의 취소는 당해 취소부분에 관하여 효력이 생긴다고 할 것인바, 이는 한 사람이 여러 종류의 자동차 운전면허를 취득한 경우 그 각 운전면허를 취소하거나 그 운전면허의 효력을 정지함에 있어서도 마찬가지이다.  
- [3] 제1종 보통, 대형 및 특수 면허를 가지고 있는 자가 레이카크레인운을 음주운전한 행위는 제1종 특수면허의 취소사유에 해당될 뿐 제1종 보통 및 대형 면허의 취소사유는 아니므로, 3종의 면허를 모두 취소한 처분 중 제1종 보통 및 대형 면허에 대한 부분은 이를 이유로 취소하면 될 것이나, 제1종 특

수면허에 대한 부분은 원고가 재량권의 일탈·남용하여 위법하다는 주장을 하고 있음에도, 원심이 그 점에 대하여 심리·판단하지 아니한 채 처분 전체를 취소한 조치는 위법하다고 하여 원심판결 중 제1종 특수면허에 대한 부분을 파기환송한 사례

<선정이유>

- 외형상 하나의 행정처분에 대한 일부취소의 가능성 및 인정기준을 제시한 판결

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

394. 일부취소판결과 사정판결 ★

“대법원 2016. 7. 14. 선고 2015두4167 판결”

<주제>

- 처분의 일부 취소, 사정판결의 요건과 판단기준

<쟁점>

- [1] 금전 부과처분 취소소송에서 부과금액 산출과정의 잘못 때문에 부과처분이 위법하나 사실심 변론종결 시까지 제출된 자료에 의하여 정당한 부과금액이 산출되는 경우, 이를 초과하는 부분만 취소하여야 하는지 여부(적극) 및 이때 처분청이 처분 시를 기준으로 정당한 부과금액이 얼마인지 주장·증명하지 않는 경우, 법원이 이를 산출할 의무를 부담하는지 여부(소극)  
- [2] “행정소송법 제28조”에서 정한 사정판결의 요건에 해당하는지 판단하는 방법과 기준 / 사정판결의 요건을 갖추었다고 판단되는 경우, 법원이 취할 조치

<판결요지>

- [1] 일반적으로 금전 부과처분 취소소송에서 부과금액 산출과정의 잘못 때문에 부과처분이 위법한 것으로 판단되더라도 사실심 변론종결 시까지 제출된 자료에 의하여 적법하게 부과될 정당한 부과금액이 산출되는 때에는 부과처분 전부를 취소할 것이 아니라 정당한 부과금액을 초과하는 부분만 취소하여야 하지만, 처분청이 처분 시를 기준으로 정당한 부과금액이 얼마인지 주장·증명하지 않고 있는 경우에도 법원이 적극적으로 직권증거조사를 하거나 처분청에게 증명을 촉구하는 등의 방법으로 정당한 부과금액을 산출할 의무까지 부담하는 것은 아니다.  
- [2] “행정소송법 제28조”에서 정한 사정판결은 행정처분이 위법함에도 불구하고 이를 취소·변경하게 되면 그것이 도리어 현저히 공공의 복리에 적합하지 않은 경우에 극히 예외적으로 할 수 있으므로, 그 요건에 해당하는지는 위법·부당한 행정처분을 취소·변경하여야 할 필요와 취소·변경으로 발생할 수 있는 공공복리에 반하는 사태 등을 비교·교량하여 엄격하게 판단하되, 처분에 이르기까지의 경과 및 처분 상대방의 관여 정도, 위법사유의 내용과 발생원인 및 전체 처분에서 위법사유가 관련된 부분이 차지하는 비중, 처분을 취소할 경우 예상되는 결과, 특히 처분을 기초로 새로운 법률관계나 사실상태가 형성되어 다수 이해관계인의 신뢰 보호 등 처분의 효력을 존속시킬 공익적 필요성이 있는지 여부 및 정도, 처분의 위법으로 인해 처분 상대방이 입게 된 손해 등 권익 침해의 내용, 행정청의 보완조치 등으로 위법상태의 해소 및 처분 상대방의 피해 전보가 가능한지 여부, 처분 이후 처분청이 위법상태의 해소를 위해 취한 조치 및 적극성의 정도와 처분 상대방의 태도 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.  
- 나아가 사정판결은 처분이 위법하나 공익상 필요 등을 고려하여 취소하지 아니하는 것일 뿐 처분이 적법하다고 인정하는 것은 아니므로, 사정판결의 요건을 갖추었다고 판단되는 경우 법원으로서 “행정소송법 제28조 제2항”에 따라 원고가 입게 될 손해의 정도와 배상방법, 그 밖의 사정에 관하여 심리하여야 하고, 이 경우 원고는 “행정소송법 제28조 제3항”에 따라 손해배상, 제해시설의 설치 그 밖에 적당한 구제방법의 청구를 병합하여 제기할 수 있으므로, 당사자가 이를 간과하였음이 분명하다면 적절하게 석명권을 행사하여 그에 관한 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.

<선정이유>

- 금전 부과처분에 대한 일부취소의 인정기준과 사정판결의 요건 및 판단기준을 제시한 판결

<제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

395. 항고소송에서 위법판단의 기준시

“대법원 1993. 5. 27. 선고 92누19033 판결”

<주제>

- 처분의 위법판단 기준시

<쟁점>

- 행정처분의 위법 여부를 판단하는 기준 시점은 처분시라고 하는 의미

<판결요지>

- 항고소송에 있어서 행정처분의 위법 여부를 판단하는 기준 시점에 대하여 판결시가 아니라 처분시라고 하는 의미는 행정처분이 있을 때의 법령과 사실상태를 기준으로 하여 위법 여부를 판단할 것이며 처분 후 법령의 개폐나 사실상태의 변동에 영향을 받지 않는다는 뜻이고 처분 당시 존재하였던 자료나 행정청에 제출되었던 자료만으로 위법 여부를 판단한다는 의미는 아니므로, 처분 당시의 사실상태 등에 대한 입증은 사실심 변론종결 당시까지 할 수 있고, 법원은 행정처분 당시 행정청이 알고 있었던 자료뿐만 아니라 사실심 변론종결 당시까지 제출된 모든 자료를 종합하여 처분당시 존재하였던 객관적 사실을 확정하고 그 사실에 기초하여 처분의 위법 여부를 판단할 수 있다.

<선정이유>

- 항고소송에 있어서 행정처분의 위법판단의 기준시에 관한 판결

---

## <제06장 취소소송의 종료.제01절 법원의 판결>

### 396. 항고소송에서 처분의 위법판단의 기준 법령 등 ★

“대법원 2023. 2. 2. 선고 2020두43722 판결”

#### <주제>

- 항고소송에서 위법판단의 기준이 되는 법령 및 행정청이 신청을 수리한 후 정당한 이유없이 처리를 지연하여 그 사이에 법령 및 보상기준이 변경된 경우 그 변경된 법령 및 보상기준에 따라서 한 처분의 위법여부(적극)

#### <쟁점>

- 행정처분의 근거 법령이 개정된 경우, 처분의 기준이 되는 법령이 무엇이고, 행정청이 신청을 수리한 후 정당한 이유 없이 처리를 지연하여 그 사이에 법령 및 보상 기준이 변경된 경우, 그 변경된 법령 및 보상 기준에 따라서 한 처분이 위법한지(적극) 및 이때 정당한 이유 없이 처리를 지연하였는지 판단 하는 방법

#### <판결요지>

- 행정처분은 그 근거 법령이 개정된 경우에도 경과 규정에서 달리 정함이 없는 한 처분 당시 시행되는 개정 법령과 거기에서 정한 기준에 의하는 것이 원칙이고, 개정 법령의 적용과 관련하여 개정 전 법령의 존속에 대한 국민의 신뢰가 개정 법령의 적용에 관한 공익상의 요구보다 더 보호가치가 있다고 인정되는 경우에 국민의 신뢰를 보호하기 위하여 개정 법령의 적용이 제한될 수 있는 여지가 있다. 행정청이 신청을 수리하고도 정당한 이유 없이 처리를 지연하여 그 사이에 법령 및 보상 기준이 변경된 경우에는 그 변경된 법령 및 보상 기준에 따라서 한 처분은 위법하고, 정당한 이유 없이 처리를 지연하였는지는 법정 처리기간이나 통상적인 처리기간을 기초로 당해 처분이 지연되게 된 구체적인 경위나 사정을 중심으로 살펴 판단하되, 개정 전 법령의 적용을 회피하려는 행정청의 동기나 의도가 있었는지, 처분지연을 쉽게 피할 가능성이 있었는지 등도 아울러 고려할 수 있다.

#### <선정이유>

- 항고소송에 있어서 행정처분의 위법판단의 기준 법령 등에 관한 판결

#### <관련판례>

- 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022두57381 판결에서는 행정처분의 근거 법령이 개정된 경우, 행정처분에 적용되는 법령(=처분 시 시행되는 개정 법령) 및 법령 위반행위에 대하여 행정상 제재처분을 할 때 적용되는 법령(=위반행위 시 시행되던 법령)으로 밝히고 있다.

---

## <제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

### 397. 판결의 효력 (1) : 기속력

“대법원 1990. 12. 11. 선고 90누3560 판결”

#### <주제>

- 판결의 기속력(반복금지효), 기속력에 반하는 처분의 효력

#### <쟁점>

- 확정판결을 받은 처분행정청이 그 행정소송을 사실심 변론종결 이전의 사유를 내세워 다시 한 확정판결과 저촉되는 행정처분의 효력 유무(소극)

#### <판결요지>

- 확정판결의 당사자인 처분행정청이 그 행정소송의 사실심 변론종결 이전의 사유를 내세워 다시 확정판결과 저촉되는 행정처분을 하는 것은 허용되지 않는 것으로서 이러한 행정처분은 그 하자가 중대하고도 명백한 것이어서 당연무효라 할 것이다.

#### <선정이유>

- 확정판결의 기속력과 기속력에 반하는 처분의 효력에 관한 판결

---

## <제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

### 398. 판결의 효력 (2) : 원상회복의무

“대법원 2019. 10. 17. 선고 2018두104 판결”

#### <주제>

- 판결의 기속력(원상회복의무)

#### <쟁점>

- 위법한 행정처분에 대한 취소판결이 확정된 경우, 행정청이 취할 조치 및 행정처분이 불복기간의 경과로 확정될 경우, 그 효력으로서 확정력의 의미

#### <판결요지>

- 어떤 행정처분을 위법하다고 판단하여 취소하는 판결이 확정되면 행정청은 취소판결의 기속력에 따라 그 판결에서 확인된 위법사유를 배제한 상태에서 다시 처분을 하거나 그 밖에 위법한 결과를 제거하는 조치를 할 의무가 있다(“행정소송법 제30조”). 그리고 행정처분이 불복기간의 경과로 인하여 확

정될 경우 그 확정력은, 처분으로 인하여 법률상 이익을 침해받은 자가 해당 처분이나 재결의 효력을 더 이상 다툴 수 없다는 의미일 뿐, 더 나아가 판결에 있어서와 같은 기판력이 인정되는 것은 아니어서 처분의 기초가 된 사실관계나 법률적 판단이 확정되고 당사자들이나 법원이 이에 기속되어 모순되는 주장이나 판단을 할 수 없게 되는 것은 아니다.

<선정이유>

- 확정판결의 기속력(원상회복의무), 제소기간 도과로 인한 불가쟁력과 기판력의 구별에 관한 판결

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

399. 판결의 효력 (3) : 재처분의무

“대법원 1998. 1. 7.자 97두22 결정”

<주제>

- 확정판결의 기속력(재처분의무)

<쟁점>

- [1] 거부처분 취소의 확정판결을 받은 행정청이 거부처분 후에 법령이 개정·시행된 경우, 새로운 사유로 내세워 다시 거부처분을 한 경우도 “행정소송법 제30조 제2항” 소정의 재처분에 해당하는지 여부(적극)
- [2] 건축불허가처분취소 판결이 확정된 후 관계 법령이 개정된 경우, 당해 지방자치단체장이 개정된 신법령에서 정한 사유를 들어 재차 거부처분을 한 것이 “행정소송법 제30조 제2항” 소정의 확정판결의 취지에 따라 이전의 신청에 대한 처분을 한 경우에 해당하는지 여부(적극)

<결정요지>

- [1] “행정소송법 제30조 제2항”의 규정에 의하면 행정청의 거부처분을 취소하는 판결이 확정된 때에는 그 처분을 행한 행정청이 판결의 취지에 따라 이전의 신청에 대하여 재처분할 의무가 있으나, 이 때 확정판결의 당사자인 처분 행정청은 그 확정판결에서 적시된 위법사유를 보완하여 새로운 처분을 할 수 있다.
- [2] 행정처분의 적법 여부는 그 행정처분이 행하여진 때의 법령과 사실을 기준으로 하여 판단하는 것이므로 거부처분 후에 법령이 개정·시행된 경우에는 개정된 법령 및 허가기준을 새로운 사유로 들어 다시 이전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있으며 그러한 처분도 “행정소송법 제30조 제2항”에 규정된 재처분에 해당된다.
- [3] 건축불허가처분을 취소하는 판결이 확정된 후 국토이용관리법시행령이 준농림지역 안에서의 행위제한에 관하여 지방자치단체의 조례로써 일정 지역에서 숙박업을 영위하기 위한 시설의 설치를 제한할 수 있도록 개정된 경우, 당해 지방자치 단체장이 위 처분 후에 개정된 신법령에서 정한 사유를 들어 새로운 거부처분을 한 것이 “행정소송법 제30조 제2항” 소정의 확정판결의 취지에 따라 이전의 신청에 대한 처분을 한 경우에 해당한다.

<선정이유>

- 거부처분 후에 법령이 개정·시행된 경우 개정된 법령 및 허가기준을 새로운 사유로 들어 다시 이전의 신청에 대한 거부처분을 하는 것은 확정판결의 기속력에 반하지 않는다는 결정

<제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

400. 판결의 효력 (4) : 재처분의무

“대법원 2005. 1. 14. 선고 2003두13045 판결”

<주제>

- 확정판결의 기속력(재처분의무)

<쟁점>

- [1] 행정청이 확정판결의 취지에 따라 절차, 방법의 위법사유를 보완하여 다시 종전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있는지 여부(적극) 및 그러한 처분도 “행정소송법 제30조 제2항”에 규정된 재처분에 해당하는지 여부(적극)
- [2] 방송위원회가 중계유선방송사업자에게 한 종합유선방송사업 승인거부처분이 심사의 기준시점을 경원자와 달리하여 평가한 것이 위법이라는 사유로 취소하는 확정판결의 취지에 따라 재처분 무렵을 기준으로 재심사한 결과에 따라 이루어진 재승인거부처분도 “행정소송법 제30조 제2항”에 규정된 재처분에 해당한다고 한 사례

<판결요지>

- [1] “행정소송법 제30조 제2항”의 규정에 의하면 행정청의 거부처분을 취소하는 판결이 확정된 경우에는 그 처분을 행한 행정청이 판결의 취지에 따라 이전의 신청에 대하여 재처분할 의무가 있다고 할 것이나, 그 취소사유가 행정처분의 절차, 방법의 위법으로 인한 것이라면 그 처분 행정청은 그 확정판결의 취지에 따라 그 위법사유를 보완하여 다시 종전의 신청에 대한 거부처분을 할 수 있고, 그러한 처분도 위 조항에 규정된 재처분에 해당한다.
- [2] 방송위원회가 중계유선방송사업자에게 한 종합유선방송사업 승인거부처분이 심사의 기준시점을 경원자와 달리하여 평가한 것이 위법이라는 사유로 취소하는 확정판결의 취지에 따라 재처분 무렵을 기준으로 재심사한 결과에 따라 이루어진 재승인거부처분도 “행정소송법 제30조 제2항”에 규정된 재처분에 해당한다고 한 사례

<선정이유>

- 취소판결 확정 이후 재차 거부처분을 하더라도 판결의 취지에 따른 처분이라면 재처분의무를 이행한 것이라고 판시한 판결

---

## <제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

### 401. 판결의 효력 (5) : 간접강제

“대법원 2004. 1. 15. 선고 2002두2444 판결”

#### <주제>

- 간접강제결정에 기한 배상금의 성질

#### <쟁점>

- “행정소송법 제34조” 소정의 간접강제결정에 기한 배상금의 성질 및 확정판결의 취지에 따른 재처분이 간접강제결정에서 정한 의무이행기한이 경과한 후에 이루어진 경우, 간접강제결정에 기한 배상금의 추심이 허용되는지 여부(소극)

#### <판결요지>

- “행정소송법 제34조” 소정의 간접강제결정에 기한 배상금은 거부처분취소판결이 확정된 경우 그 처분을 행한 행정청으로 하여금 확정판결의 취지에 따른 재처분의무의 이행을 확실히 담보하기 위한 것으로서, 확정판결의 취지에 따른 재처분의무내용의 불확정성과 그에 따른 재처분에의 해당 여부에 관한 쟁송으로 인하여 간접강제결정에서 정한 재처분의무의 기한 경과에 따른 배상금이 증가될 가능성이 자칫 행정청으로 하여금 인용처분을 강제하여 행정청의 재량권을 박탈하는 결과를 초래할 위험성이 있는 점 등을 감안하면, 이는 확정판결의 취지에 따른 재처분의 지연에 대한 제재나 손해배상이 아니고 재처분의 이행에 관한 심리적 강제수단에 불과한 것으로 보아야 하므로, 특별한 사정이 없는 한 간접강제결정에서 정한 의무이행기한이 경과한 후 예라도 확정판결의 취지에 따른 재처분의 이행이 있으면 배상금을 추심함으로써 심리적 강제를 꾀할 목적이 상실되어 처분상대방이 더 이상 배상금을 추심하는 것은 허용되지 않는다.

#### <선정이유>

- 간접강제결정에 기한 배상금의 법적 성질 및 배상금 추심의 한계에 관한 판결
- 

## <제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

### 402. 판결의 효력 (6) : 형성력

“대법원 1986. 8. 19. 선고 83다카2022 판결”

#### <주제>

- 취소판결의 형성력

#### <쟁점>

- 취소판결이 행정처분을 기초로 새로 형성된 제3자의 권리에 미치는 효력의 의미

#### <판결요지>

- [1] 행정처분을 취소하는 확정판결이 제3자에 대하여도 효력이 있다고 하더라도 일반적으로 판결의 효력은 주문에 포함한 것에 한하여 미치는 것이니 그 취소판결 자체의 효력으로써 그 행정처분을 기초로 하여 새로 형성된 제3자의 권리까지 당연히 그 행정처분 전의 상태로 환원되는 것이라고는 할 수 없고, 단지 취소판결의 존재와 취소판결에 의하여 형성되는 법률관계를 소송당사자가 아니었던 제3자라 할지라도 이를 용인하지 않으면 아니된다는 것을 의미하는 것에 불과하다 할 것이며, 따라서 취소판결의 확정으로 인하여 당해 행정처분을 기초로 새로 형성된 제3자의 권리관계에 변동을 초래하는 경우가 있다 하더라도 이는 취소판결 자체의 형성력에 기한 것이 아니라 취소판결의 위와 같은 의미에서의 제3자에 대한 효력의 반사적 효과로서 그 취소판결이 제3자의 권리관계에 대하여 그 변동을 초래할 수 있는 새로운 법률요건이 되는 까닭이라 할 것이다.
- [2] 환지계획변경처분으로 원고명의로 소유권이전등기가 경료되었으나 그후 위 변경처분으로 인하여 불이익을 입게 된 소외인이 동 처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기하여 승소판결을 받아이를 근거로 원고명의로 소유권이전등기의 말소청구소송을 제기하여 동 소외인 승소판결이 확정됨에 따라 원고가 그 소유권상실의 손해를 입게 된 경우, 원고명의로 소유권이전등기는 위 취소판결자체의 효력에 의하여 당연히 말소되는 것이 아니라 소외인이 위 취소판결의 존재를 법률요건으로 주장하여 원고에게 그 말소를 구하는 소송을 제기하여 승소의 확정판결을 얻어야 비로소 말소될 수 있는 것이며, 위 말소청구소송에서의 승패 또한 위 취소판결의 존재가 주장되었다는 한가지 사실만으로 바로 판가름나는 것이라 할 수 없고 당사자의 주장 입증내용에 따라 달라질 여지가 있는 것이라 할 것이므로 원고는 위 말소청구의 소장부분을 송달받은 때가 아니라 위 말소청구의 소에서 원고패소가 확정됨으로써 비로소 그 손해를 알게 되었다고 봄이 상당하다.

#### <선정이유>

- 취소판결의 대세효(제3자효)의 인정범위와 취소된 처분에 의하여 형성된 법률관계를 기초로 행해진 사법상 행위에 의하여 권리를 취득한 자에 대한 영향에 관하여 판시한 판결
- 

## <제06장 취소소송의 종료.제02절 판결의 효력>

### 403. 판결의 효력 (7) : 기판력

“대법원 1996. 4. 26. 선고 95누5820 판결”

<주제>

- 취소판결의 기판력

<쟁점>

- 전소와 후소가 소송물을 달리하는 경우, 전소 확정판결의 기판력이 후소에 미치는지 여부(소극)

<판결요지>

- [1] 취소판결의 기판력은 소송물로 된 행정처분의 위법성 존부에 관한 판단 그 자체에만 미치는 것이므로 전소와 후소가 그 소송물을 달리하는 경우에는 전소 확정판결의 기판력이 후소에 미치지 아니한다.
- [2] 전 소송은 이 사건에서의 피고 보조참가인이 원고가 되어 피고를 상대로 피고가 1990. 2.3.에 한 이 사건 변경승인취소처분의 취소를 구하는 소송에서 이 사건에서의 원고가 피고 보조참가인이 되어 원고(이 사건에서의 피고 보조참가인)의 청구를 다투는 형식이었는데 반하여, 이 사건 소송은 원고가 피고를 상대로 1988. 9. 6.자 피고의 이 사건 변경승인의 무효확인(주위적으로) 또는 취소(예비적으로)를 구하는 소송에서 피고 보조참가인이 피고를 보조하여 원고의 청구를 다투는 것이어서, 전 소송과 이 사건 소송은 그 청구취지를 달리하는 것이므로 전 소송의 판결의 기판력은 그 소송물이었던 1990. 2. 3.자 변경승인취소처분의 위법성 존부에 관한 판단 그 자체에만 미치는 것이고 그 소송물을 달리하는 이 사건 소에는 미치지 아니한다고 보아야 할 것이다.

<선정이유>

- 기판력이 미치는 범위와 관련하여 전소와 후소가 소송물을 달리하는 경우 전소 확정판결의 기판력은 후소에 미치지 않는다고 판시한 판결

<제06장 취소소송의 종류.제02절 판결의 효력>

404. 판결의 효력 (8) : 기판력

“대법원 2014. 11. 27. 선고 2014두37665 판결”

<주제>

- 공사중지명령에 대한 취소청구를 기각하는 확정판결의 기판력

<쟁점>

- 행정청의 공사중지명령에 대한 취소소송에서 명령이 적법한 것으로 확정된 경우, 이후 그 명령의 상대방이 명령의 해제신청을 거부한 처분의 취소를 구하는 소송에서 명령의 적법성을 다툴 수 있는지 여부(소극) 및 공사중지명령의 해제를 구하기 위한 요건

<판결요지>

- 행정청이 관련 법령에 근거하여 행한 공사중지명령의 상대방이 명령의 취소를 구한 소송에서 패소함으로써 그 명령이 적법한 것으로 이미 확정되었다면, 이후 이러한 공사중지명령의 상대방은 그 명령의 해제신청을 거부한 처분의 취소를 구하는 소송에서 그 명령의 적법성을 다툴 수 없다. 그와 같은 공사중지명령에 대하여 그 명령의 상대방이 해제를 구하기 위해서는 명령의 내용 자체로 또는 성질상으로 명령 이후에 원인사유가 해소되었음이 인정되어야 한다.

<선정이유>

- 공사중지명령 취소소송에서 명령이 적법한 것으로 판단되어 기각판결이 확정된 경우 그 기판력은 명령의 상대방이 제기한 명령해제신청 거부처분 취소소송에서 명령의 적법성 판단에 미친다고 판시한 판결

<제07장 취소소송의 가구제.제01절 집행정지>

371. 집행정지의 대상

“대법원 1991. 5. 2.자 91두15 결정”

<주제>

- 거부처분에 대해서는 집행정지가 허용되지 않음

<쟁점>

- [1] 행정처분의 효력정지신청을 기각한 결정에 대하여 행정처분 자체의 적법여부를 가지고 불복사유로 삼을 수는 있는지 여부(소극)
- [2] 교도소장의 접견허가신청에 대한 거부처분과 효력정지의 필요성 유무(소극)

<판결요지>

- [1] 행정처분의 효력정지나 집행정지를 구하는 신청사건에 있어서는 행정처분자체의 적법 여부를 판단할 것이 아니고 그 행정처분의 효력이나 집행 등을 정지시킬 필요가 있는지의 여부, 즉 “행정소송법 제23조 제2항” 소정 요건의 존부만이 판단대상이 되는 것이므로 이러한 요건을 결여하였다는 이유로 효력정지신청을 기각한 결정에 대하여 행정처분 자체의 적법 여부를 가지고 불복사유로 할 수 없다.
- [2] 허가신청에 대한 거부처분은 그 효력이 정지되더라도 그 처분이 없었던 것과 같은 상태를 만드는 것에 지나지 아니하는 것이고 그 이상으로 행정청에 대하여 어떠한 처분을 명하는 등 적극적인 상태를 만들어 내는 경우를 포함하지 아니하는 것이므로, 교도소장이 접견을 불허한 처분에 대하여 효력정지를 한다 하여도 이로 인하여 위 교도소장에게 접견의 허가를 명하는 것이 되는 것도 아니고 또 당연히 접견이 되는 것도 아니어서 접견허가거부처분에 의하여 생길 회복할 수 없는 손해를 피하는 데 아무런 보탬도 되지 아니하니 접견허가거부처분의 효력을 정지할 필요성이 없다.

#### <선정이유>

- 거부처분은 적극적인 상태를 만들어 내는 것이 아니므로 이에 대해서는 집행정지가 허용되지 않는다고 한 결정으로, 예외적으로 집행정지신청의 이익이 있을 경우 제한적으로 긍정할 수 있다는 견해에 대응하여 법원의 기본입장을 확인할 수 있는 판결

#### <제07장 취소소송의 가구제.제01절 집행정지>

#### 372. 집행정지의 요건 (1)

**"대법원 1992. 8. 7.자 92두30 결정"**

#### <주제>

- 효력정지신청의 이익, 효력정지신청의 요건

#### <쟁점>

- [1] 미결수용중 다른 교도소로 이송된 피고인이 법원의 이송처분효력정지결정에 의하여 이송처분이 있기 전과 같은 교도소로 다시 이송되어 수용중인 경우 효력정지신청의 이익 유무(적극)
- [2] "행정소송법 제23조 제2항" 소정의 회복하기 어려운 손해의 의미
- [3] 상고심에 계속중인 형사피고인을 안양교도소로부터 진주교도소로 이송함으로써 회복하기 어려운 손해가 발생할 염려가 있다고 본 사례
- [4] 행정처분의 효력정지나 집행정지를 구하는 신청사건에서의 판단대상 및 본안소송에서 처분취소가능성 없음이 명백할 경우 행정처분의 효력정지나 집행정지의 가부(소극)

#### <판결요지>

- [1] 미결수용중 다른 교도소(진주교도소)로 이송된 피고인이 그 이송처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기하고 아울러 그 효력정지를 구하는 신청을 제기한 데 대하여 법원에서 위 이송처분의 효력정지신청을 인용하는 결정을 하였고 이에 따라 신청인이 다시 이송되어 현재 위 이송처분이 있기 전과 같은 교도소(안양교도소)에 수용중이라 하여도 이는 법원의 효력정지 결정에 의한 것이어서 그로 인하여 효력정지신청이 그 신청의 이익이 없는 부적법한 것으로 되는 것은 아니다.
- [2] 행정처분의 집행정지나 효력정지결정을 하기 위하여는 "행정소송법 제23조 제2항"에 따라 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있어야 하고, 여기서 말하는 회복하기 어려운 손해라 함은 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해라 할 것이며 이는 금전보상이 불능한 경우뿐만 아니라 금전보상으로는 사회관념상 행정처분을 받은 당사자가 참고 견딜 수 없거나 또는 참고 견디기가 현저히 곤란한 경우의 유형, 무형의 손해를 일컫는다.
- [3] 상고심에 계속중인 형사피고인을 안양교도소로부터 다시 진주교도소로 이송함으로써 위 회복하기 어려운 손해가 발생할 염려가 있다고 본 사례
- [4] 행정처분의 효력정지나 집행정지를 구하는 신청사건에 있어서는 행정처분 자체의 적법 여부는 원칙적으로는 판단할 것이 아니고 그 행정처분의 효력이나 집행을 정지할 것인가에 대한 "행정소송법 제23조 제2항" 소정의 요건의 존부만이 판단의 대상이 되나 본안소송에서의 처분의 취소가능성이 없음에도 불구하고 처분의 효력정지나 집행정지를 인정한다는 것은 제도의 취지에 반하므로 집행정지사건 자체에 의하여도 신청인의 본안청구가 이유 없음이 명백할 때에는 행정처분의 효력정지나 집행정지를 명할 수 없다.

#### <선정이유>

- 효력정지신청의 이익과 신청요건으로서 회복하기 어려운 손해의 의미를 분명히 하고, 신청인의 본안청구가 이유 없음이 명백할 때에는 예외적으로 처분의 효력정지나 집행행지를 명할 수 없음을 밝힌 판결

#### <제07장 취소소송의 가구제.제01절 집행정지>

#### 373. 집행정지의 요건 (2)

**"대법원 2011. 4. 21.자 2010무111 전원합의체 결정"**

#### <주제>

- 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위한 긴급한 필요의 판단 기준

#### <쟁점>

- [1] 항고소송 대상이 되는 처분의 의미
- [2] 국토해양부, 환경부, 문화체육관광부, 농림수산부, 식품부가 합동으로 2009. 6. 8. 발표한 4대강 살리기 마스터플랜 등은 행정기관 내부에서 사업의 기본방향을 제시하는 계획일 뿐 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 것이 아니어서, 행정처분에 해당하지 않는다고 한 사례
- [3] "행정소송법 제23조 제2항"의 효력정지 요건인 회복하기 어려운 손해의 의미 및 처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있는지의 판단 기준
- [4] 국토해양부 등에서 발표한 4대강 살리기 마스터플랜에 따른 한강 살리기 사업 구간 인근에 거주하는 주민들이 각 공구별 사업실시계획승인처분에 대한 효력정지를 신청한 사안에서, 토지소유권 수용 등으로 인한 손해는 "행정소송법 제23조 제2항"의 효력정지 요건인 금전으로 보상할 수 없거나 사회관념상 금전보상으로는 참고 견디기 어렵거나 현저히 곤란한 경우의 유·무형 손해에 해당하지 않는다고 본 원심판단을 수긍한 사례
- [5] "행정소송법 제23조 제2항"에서 정한 요건을 결여하였다는 이유로 효력정지 신청을 기각한 결정에 대하여, 행정처분 자체의 적법 여부를 가지고 불복사유로 삼을 수 있는지 여부(소극)

#### <판결요지>

- [1] 항고소송 대상이 되는 행정청의 처분이란 원칙적으로 행정청의 공법상 행위로서 특정사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 직접 발생하게 하는 등 국민의 권리의무에 직접 관계가 있는 행위를 말하므로, 행정청의 내부적인 의사결정 등과 같이 상대방 또는 관계자들의 법률상 지위에 직접 법률적 변동을 일으키지 않는 행위는 그에 해당하지 아니한다.

- [2] 국토해양부, 환경부, 문화체육관광부, 농림수산부, 식품부가 합동으로 2009. 6. 8. 발표한 4대강 살리기 마스터플랜 등은 4대강 정비사업과 주변 지역의 관련 사업을 체계적으로 추진하기 위하여 수립한 종합계획이자 4대강 살리기 사업의 기본방향을 제시하는 계획으로서, 행정기관 내부에서 사업의 기본방향을 제시하는 것일 뿐, 국민의 권리·의무에 직접 영향을 미치는 것이 아니어서 행정처분에 해당하지 않는다고 한 사례

- [3] "행정소송법 제23조 제2항"에서 정하고 있는 효력정지 요건인 회복하기 어려운 손해란, 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해로서 금전보상이 불가능한 경우 내지는 금전보상으로는 사회관념상 행정처분을 받은 당사자가 참고 견딜 수 없거나 참고 견디기가 현저히 곤란한 경우의 유형, 무형의 손해를 일컫는다. 그리고 처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있는지는 처분의 성질과 태양 및 내용, 처분상대방이 입는 손해의 성질·내용 및 정도, 원상회복·금전배상의 방법 및 난이 등은 물론 본안청구의 승소가 능성 정도 등을 종합적으로 고려하여 구체적·개별적으로 판단하여야 한다.

- [4] 국토해양부 등에서 발표한 4대강 살리기 마스터플랜에 따른 한강 살리기 사업 구간 인근에 거주하는 주민들이 각 공구별 사업실시계획승인처분에 대한 효력정지를 신청한 사안에서, 위 사업구간에 편입되는 팔당지역 농지 대부분이 국가 소유의 하천부지이고, 유기농업에 종사하는 주민들 대부분은 국가로부터 하천점용허가를 받아 경작을 해온 점, 위 점용허가의 부관에 따라 허가를 한 행정청은 공익상 또는 법령이 정하는 것에 따르거나 하천정비사업을 시행하는 경우 허가변경·취소 등을 할 수 있는 점 등에 비추어, 주민들 중 환경영향평가대상지역 및 근접 지역에 거주하거나 소유권 기타 권리를 가지고 있는 사람들이 위 사업으로 인하여 토지 소유권 기타 권리를 수용당하고 이로 인하여 정착지를 떠나 타지로 이주를 해야 하며 더 이상 농사를 지을 수 없게 되고 팔당지역의 유기농업이 사실상 해체될 위기에 처하게 된다고 하더라도, 그러한 손해는 "행정소송법 제23조 제2항"에서 정하고 있는 효력정지 요건인 금전으로 보상할 수 없거나 사회관념상 금전보상으로는 참고 견디기 어렵거나 현저히 곤란한 경우의 유·무형 손해에 해당하지 않는다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

- [5] [다수의견] 행정처분의 효력정지나 집행정지를 구하는 신청사건에서는 행정처분 자체의 적법여부를 판단할 것이 아니고 행정처분의 효력이나 집행 등을 정지시킬 필요가 있는지 여부, 즉 "행정소송법 제23조 제2항"에서 정한 요건의 존부만이 판단대상이 된다. 나아가 처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인한 손해발생의 우려 등 적극적 요건에 관한 주장·소명 책임은 원칙적으로 신청인 측에 있으며, 이러한 요건을 결여하였다는 이유로 효력정지 신청을 기각한 결정에 대하여 행정처분 자체의 적법 여부를 가지고 불복사유로 삼을 수 없다.

#### <선정이유>

- "행정소송법 제23조 제2항"의 효력정지 요건인 회복하기 어려운 손해의 의미 및 처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있는지의 판단 기준에 관한 이해도를 높일 수 있는 판결

#### <제07장 취소소송의 가구제.제01절 집행정지>

#### 374. 집행정지의 요건 (3)

"대법원 2001. 10. 10.자 2001무29 결정"

##### <주제>

- 회복하기 어려운 손해의 판단 기준

##### <쟁점>

- 과징금납부명령의 처분이 사업자의 자금사정이나 경영전반에 미치는 파급효과가 매우 중대하다는 이유로 그로 인한 손해는 효력정지 내지 집행정지의 적극적 요건인 회복하기 어려운 손해에 해당한다고 한 사례

##### <판결요지>

- 사업여건의 악화 및 막대한 부채비율로 인하여 외부자금의 신규차입이 사실상 중단된 상황에서 285억 원 규모의 과징금을 납부하기 위하여 무리하게 외부자금을 신규차입하게 되면 주거은행과의 재무구조개선약정을 지키지 못하게 되어 사업자가 중대한 경영상의 위기를 맞게 될 것으로 보이는 경우, 그 과징금납부명령의 처분으로 인한 손해는 효력정지 내지 집행정지의 적극적 요건인 회복하기 어려운 손해에 해당한다고 한 사례

#### <선정이유>

- 집행정지의 적극적 요건인 회복하기 어려운 손해에 관하여 특별한 사정이 없는 한 금전으로 보상할 수 없는 손해가 인정되는 좋은 예를 보여주는 판결

#### <제07장 취소소송의 가구제.제01절 집행정지>

#### 375. 집행정지의 효력 (1)

"대법원 2003. 7. 11. 선고 2002다48023 판결"

##### <주제>

- 집행정지의 효력

##### <쟁점>

- [1] "행정소송법 제23조" 소정의 처분에 대한 집행정지의 취지 및 그 효력의 시적 범위

- [2] 일정한 납부기한을 정한 과징금부과처분에 대한 집행정지결정이 내려진 경우 그 집행정지기간 동안 납부기간이 진행되는지 여부(소극)

<판결요지>

- [1] "행정소송법 제23조"에 정해져 있는 처분에 대한 집행정지는 행정처분의 집행으로 인하여 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있고 달리 공공복리에 중대한 영향을 미치지 아니할 것을 요건으로 하여 본안판결이 있을 때까지 당해 행정처분의 집행을 잠정적으로 정지함으로써 위와 같은 손해를 예방하고자 함에 그 취지가 있고, 그 집행정지의 효력 또한 당해 결정의 주문에 표시된 시기까지 존속하다가 그 시기의 도래와 동시에 당연히 소멸한다.
- [2] 일정한 납부기한을 정한 과징금부과처분에 대하여 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있고 달리 공공복리에 중대한 영향을 미치지 아니한다는 이유로 집행정지결정이 내려졌다면 그 집행정지기간 동안은 과징금부과처분에서 정한 과징금의 납부기간은 더 이상 진행되지 아니하고 집행정지결정이 당해 결정의 주문에 표시된 시기의 도래로 인하여 실효되면 그 때부터 당초의 과징금부과처분에서 정한 기간(집행정지결정 당시 이미 일부 진행되었다면 그 나머지 기간)이 다시 진행되는 것으로 보아야 한다.

<선정이유>

- 집행정지의 효력 및 그 효력의 시적 범위에 관한 판결로서, 납부기한이 정해진 과징금부과처분에 집행정지결정이 내려지면 그 납부기간은 판결확정 시까지 진행되지 아니하며, 그 집행정지결정이 결정의 주문에 표시된 시기의 도래로 실효 시 그 때부터 당초 과징금부과처분에서 정한 기간이 다시 진행하는 것으로 확인한 판결

<제07장 취소소송의 가구제.제01절 집행정지>

376. 집행정지의 효력 (2)

"대법원 2017. 7. 11. 선고 2013두25498 판결"

<주제>

- 효력정지의 효력

<쟁점>

- 보조금 교부결정의 일부를 취소한 행정청의 처분에 대한 효력정지결정의 효력이 소멸하여 보조금 교부결정 취소처분의 효력이 되살아난 경우, "구 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 제31조 제1항"에 따라 취소처분에 의하여 취소된 부분의 보조사업에 대하여 효력정지기간 동안 교부된 보조금의 반환을 명하여야 하는지 여부(원칙적 적극)

<판결요지>

- "구 사회적기업 육성법"에 의하면, 노동부장관은 사회적서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위 안에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비·운영경비·자문비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다("제14조 제1항"). 그리고 "구 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률(이하 '보조금법')에 의하면, 보조금의 예산편성 및 관리에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 보조금법이 정하는 바에 따르고("제3조 제1항"), 보조사업자가 보조금을 다른 용도에 사용하거나 보조금 교부결정의 내용 등에 위반한 때에는 보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있으며("제30조 제1항"), 보조금의 교부결정을 취소한 경우에 취소된 부분의 보조사업에 대하여 이미 보조금이 교부되어 있을 때에는 취소한 부분에 해당하는 보조금의 반환을 명하여야 한다("제31조 제1항").
- 한편 "행정소송법 제23조"에 의한 효력정지결정의 효력은 결정주문에서 정한 시기까지 존속하고 그 시기의 도래와 동시에 효력이 당연히 소멸하므로, 보조금 교부결정의 일부를 취소한 행정청의 처분에 대하여 법원이 효력정지결정을 하면서 주문에서 그 법원에 계속 중인 본안소송의 판결 선고 시까지 처분의 효력을 정지한다고 선언하였을 경우, 본안소송의 판결 선고에 의하여 정지결정의 효력은 소멸하고 이와 동시에 당초의 보조금 교부결정 취소처분의 효력이 당연히 되살아난다.
- 따라서 효력정지결정의 효력이 소멸하여 보조금 교부결정 취소처분의 효력이 되살아난 경우, 특별한 사정이 없는 한 행정청으로서는 "보조금법 제31조 제1항"에 따라 취소처분에 의하여 취소된 부분의 보조사업에 대하여 효력정지기간 동안 교부된 보조금의 반환을 명하여야 한다.

<선정이유>

- 보조금 교부결정의 일부를 취소한 행정청의 처분에 대하여 법원이 효력정지결정을 하면서 주문에서 그 법원에 계속 중인 본안소송의 판결 선고 시까지 처분의 효력을 정지한다고 선언하였을 경우, 본안소송의 판결 선고에 의하여 정지결정의 효력은 소멸하고 이와 동시에 당초의 보조금 교부결정 취소처분의 효력이 당연히 되살아나므로 효력정지기간 동안 교부된 보조금의 반환을 명하여야 한다는 판결

<제07장 취소소송의 가구제.제01절 집행정지>

377. 행정쟁송에서 집행정지 결정의 종기

"대법원 2022. 2. 11. 선고 2021두40720 판결"

<주제>

- 행정쟁송에서 집행정지 결정의 종기

<쟁점>

- [1] 효력기간이 정해져 있는 제재적 행정처분에 대한 취소소송에서 법원이 본안소송의 판결 선고시까지 집행정지결정을 한 경우, 처분에서 정해 둔 효력기간은 판결 선고 시까지 진행하지 않다가 선고된 때에 다시 진행하는지 여부(적극) / 처분에서 정해 둔 효력기간의 시기와 종기가 집행정지기간 중에 모두 경과한 경우에도 마찬가지인지 여부(적극) / 이러한 법리는 행정심판위원회가 "행정심판법 제30조"에 따라 집행정지결정을 한 경우에도 그대로 적용되는지 여부(적극)

- [2] 효력기간이 정해져 있는 제재적 행정처분의 효력이 발생한 이후 행정청이 상대방에 대한 별도의 처분으로 효력기간의 시기와 종기를 다시 정할 수 있는지 여부(적극) / 위와 같은 후속 변경처분서에 당초 행정처분의 집행을 특정 소송사건의 판결 시까지 유예한다고 기재한 경우, 처분의 효력기간은 판결 선고 시까지 진행이 정지되었다가 선고되면 다시 진행하는지 여부(적극) / 당초의 제재적 행정처분에서 정한 효력기간이 경과한 후 동일한 사유로 다시 제재적 행정처분을 하는 것이 위법한 이중처분에 해당하는지 여부(적극)

<판결요지>

- [1] "행정소송법 제23조"에 따른 집행정지결정의 효력은 결정 주문에서 정한 종기까지 존속하고, 그 종기가 도래하면 당연히 소멸한다. 따라서 효력기간이 정해져 있는 제재적 행정처분에 대한 취소소송에서 법원이 본안소송의 판결 선고 시까지 집행정지결정을 하면, 처분에서 정해 둔 효력기간(집행정지결정 당시 이미 일부 집행되었다면 그 나머지 기간)은 판결 선고 시까지 진행하지 않다가판결이 선고되면 그때 집행정지결정의 효력이 소멸함과 동시에 처분의 효력이 당연히 부활하여 처분에서 정한 효력기간이 다시 진행된다. 이는 처분에서 효력기간의 시기(시기)와 종기(종기)를 정해두었는데, 그 시기와 종기가 집행정지기간 중에 모두 경과한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 마찬가지이다. 이러한 법리는 행정심판위원회가 "행정심판법 제30조"에 따라 집행정지결정을 한 경우에도 그대로 적용된다. 행정심판위원회가 행정심판 청구 사건의 재결이 있을 때까지 처분의 집행을 정지한다고 결정한 경우에는, 재결서 정본이 청구인에게 송달된 때 재결의 효력이 발생하므로("행정심판법 제48조 제2항", "제1항" 참조) 그때 집행정지결정의 효력이 소멸함과 동시에 처분의 효력이 부활한다.

- [2] 효력기간이 정해져 있는 제재적 행정처분의 효력이 발생한 이후에도 행정청은 특별한 사정이 없는 한 상대방에 대한 별도의 처분으로써 효력기간의 시기와 종기를 다시 정할 수 있다. 이는 당초의 제재적 행정처분이 유효함을 전제로 그 구체적인 집행시기만을 변경하는 후속 변경처분이다. 이러한 후속 변경처분도 특별한 규정이 없는 한 의사표시에 관한 일반법리에 따라 상대방에게 고지되어야 효력이 발생한다. 위와 같은 후속 변경처분서에 효력기간의 시기와 종기를 다시 특정하는 대신 당초 제재적 행정처분의 집행을 특정 소송사건의 판결 시까지 유예한다고 기재되어 있다면, 처분의 효력기간은 원칙적으로 그 사건의 판결 선고 시까지 진행이 정지되었다가 판결이 선고되면 다시 진행된다. 다만 이러한 후속 변경처분 권한은 특별한 사정이 없는 한 당초의 제재적 행정처분의 효력이 유지되는 동안에만 인정된다. 당초의 제재적 행정처분에서 정한 효력기간이 경과하면 그로써 처분의 집행은 종료되어 처분의 효력이 소멸하는 것이므로("행정소송법 제12조" 후문 참조), 그 후 동일한 사유로 다시 제재적 행정처분을 하는 것은 위법한 이중처분에 해당한다.

<선정이유>

- 행정소송법에 따른 집행정지결정의 효력은 결정 주문에서 정한 종기까지 존속하므로 효력기간이 정해져 있는 제재적 행정처분에 대한 취소소송에서 법원이 본안소송의 판결 선고 시까지 집행정지결정을 하면, 판결 선고 시까지 진행하지 않다가 판결이 선고되면 그때 집행정지결정의 효력이 소멸함과 동시에 처분의 효력이 당연히 부활하여 처분에서 정한 효력기간이 다시 진행하며 이러한 법리는 행정심판위원회가 "행정심판법 제30조"에 따라 집행정지결정을 한 경우에도 그대로 적용되므로, 행정심판위원회가 행정심판 청구 사건의 재결이 있을 때까지 처분의 집행을 정지한다고 결정한 경우에는, 재결서 정본이 청구인에게 송달된 때 재결의 효력이 발생하므로("행정심판법 제48조 제2항", "제1항" 참조) 그때 집행정지결정의 효력이 소멸함과 동시에 처분의 효력이 부활한다고 본 판결

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제01절 관련청구소송의 병합·이송>

381. 관련청구소송의 병합 (1) : 병합의 요건

“대법원 2001. 11. 27. 선고 2000두697 판결”

<주제>

- 관련청구소송 병합의 요건

<쟁점>

- [1] "행정소송법 제10조"에 의한 관련청구소송의 병합은 본래의 항고소송이 적법함을 요건으로 하는지 여부(적극)
- [2] 도로관리청이 원인자부담금 부과처분에 의한 부과금 징수를 위하여 압류처분을 하고 이어 압류등기를 한 경우, 관련청구소송으로서 압류등기의 말소청구소송에 대한 "행정소송법 제38조", "제10조" 소정의 본래의 항고소송의 범위(=원인자부담금 부과처분 또는 압류처분에 대한 항고소송)

<판결요지>

- [1] "행정소송법 제38조", "제10조"에 의한 관련청구소송의 병합은 본래의 항고소송이 적법할 것을 요건으로 하는 것이어서 본래의 항고소송이 부적법하여 각하되면 그에 병합된 관련청구도 소송요건을 흠결한 부적합한 것으로 각하되어야 한다.
- [2] 도로관리청이 원인자부담금 부과처분에 의한 부과금 징수를 위하여 압류처분을 하고 그에 이어 압류등기를 한 경우, 이해관계인은 그 압류처분에 대한 항고소송 외에 그 압류등기의 말소청구소송을 제기할 수 있고, 그 경우 "행정소송법 제38조", "제10조"에서 말하는 본래의 항고소송은 원인자부담금 부과처분 또는 압류처분에 대한 항고소송을 모두 포함한다.

<선정이유>

- 상호관련성 있는 여러 청구를 하나의 절차에서 심판하도록 하여 심리중복과 재판모순을 방지하고 재판의 신속성을 제고하기 위한 관련청구소송의 병합은 본래의 항고소송이 적법함을 요건으로 한다고 판시한 판결

<제08장 청구의 병합과 소의 변경.제01절 관련청구소송의 병합·이송>

382. 관련청구소송의 병합 (2) : 선결문제와 부당이득반환청구

“대법원 2009. 4. 9. 선고 2008두23153 판결”

<주제>

- 처분의 취소소송에 병합된 부당이득반환청구가 인용되려면 소송절차에서 당해 처분의 취소가 확정되어야 하는지 여부

#### <쟁점>

- 행정처분의 취소를 구하는 취소소송에 당해 처분의 취소를 선결문제로 하는 부당이득반환청구가 병합된 경우, 그 청구가 인용되려면 소송절차에서 당해 처분의 취소가 확정되어야 하는지 여부(소극)

#### <판결요지>

- [1] "행정소송법 제10조"는 처분의 취소를 구하는 취소소송에 당해 처분과 관련되는 부당이득반환소송을 관련 청구로 병합할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 조항을 둔 취지에 비추어 보면, 취소소송에 병합할 수 있는 당해 처분과 관련되는 부당이득반환소송에는 당해 처분의 취소를 선결문제로 하는 부당이득반환청구가 포함되고, 이러한 부당이득반환청구가 인용되기 위해서는 그 소송절차에서 판결에 의해 당해 처분이 취소되면 충분하고 그 처분의 취소가 확정되어야 하는 것은 아니라고 보아야 한다.

- [2] 보험료부과처분에 대한 취소소송에서 90,946,000원의 보험료부과처분 중 67,194,980원의 보험료부과처분을 취소하면서도, 관련 청구로 병합된 부당이득반환소송에서는 그 처분의 취소를 전제로 인용 여부를 판단하지 않고 처분의 취소가 확정되지 않았다는 이유로 기각한 것은 위법하다고 한 사례

#### <선정이유>

- 행정처분의 취소를 구하는 취소소송에 당해 처분의 취소를 선결문제로 하는 부당이득반환청구가 병합된 경우, 부당이득반환청구가 인용되기 위하여 그 소송절차에서 판결에 의해 당해 처분이 취소되면 충분하고 그 처분의 취소가 확정되어야 하는 것은 아니라고 판시한 판결

### <제08장 청구의 병합과 소의 변경.제01절 관련청구소송의 병합·이송>

#### 383. 관련청구소송의 병합 (3) : 제소기간

"대법원 2005. 12. 23. 선고 2005두3554 판결"

#### <주제>

- 동일한 처분에 대한 소의 병합과 제소기간

#### <쟁점>

- 동일한 행정처분에 대하여 무효확인인 소를 제기하였다가 그 후 그 처분의 취소를 구하는 소를 추가적으로 병합한 경우, 주된 청구인 무효확인인 소가 적법한 제소기간 내에 제기되었다면 추가로 병합된 취소청구의 소도 적법하게 제기된 것으로 볼 수 있는지 여부(적극)

#### <판결요지>

- 하자 있는 행정처분을 놓고 이를 무효로 볼 것인지 아니면 단순히 취소할 수 있는 처분으로 볼 것인지는 동일한 사실관계를 토대로 한 법률적 평가의 문제에 불과하고, 행정처분의 무효확인을 구하는 소에는 특단의 사정이 없는 한 그 취소를 구하는 취지도 포함되어 있다고 보아야 하는 점 등에 비추어 볼 때, 동일한 행정처분에 대하여 무효확인인 소를 제기하였다가 그 후 그 처분의 취소를 구하는 소를 추가적으로 병합한 경우, 주된 청구인 무효확인인 소가 적법한 제소기간 내에 제기되었다면 추가로 병합된 취소청구의 소도 적법하게 제기된 것으로 봄이 상당하다.

#### <선정이유>

- 무효확인인 소에 동일한 처분에 대한 취소청구의 소를 추가적으로 병합한 경우 병합된 소의 제소기간 준수 여부를 판단하는 기준시에 대하여 판시한 판결

### <제09장 무효등 확인소송.제02절 무효등 확인소송의 요건>

#### <제03장 취소소송의 당사자적격.제03절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

#### 361. 소의 이익 (15) : 무효확인소송에서 소의 이익(보충성)

"대법원 2008. 3. 20. 선고 2007두6342 전원합의체 판결"

#### <주제>

- 행정처분의 무효확인을 구할 소의 이익

#### <쟁점>

- "행정소송법 제35조"에 규정된 무효확인을 구할 법률상 이익이 있는지를 판단할 때 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지를 따져보아야 하는지 여부(소극)

#### <판결요지>

- 행정소송은 행정청의 위법한 처분 등을 취소·변경하거나 그 효력 유무 또는 존재 여부를 확인함으로써 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고 공법상의 권리관계 또는 법 적용에 관한 다툼을 적절하게 해결함을 목적으로 하므로, 대등한 주체 사이의 사법상 생활관계에 관한 분쟁을 심판대상으로 하는 민사소송과는 목적, 취지 및 기능 등을 달리한다. 또한 "행정소송법 제4조"에서는 무효확인소송을 항고소송의 일종으로 규정하고 있고, "행정소송법 제38조 제1항"에서는 처분 등을 취소하는 확정판결의 기속력 및 행정청의 재처분 의무에 관한 "행정소송법 제30조"를 무효확인소송에도 준용하고 있으므로 무효확인판결 자체만으로도 실효성을 확보할 수 있다. 그리고 무효확인소송의 보충성을 규정하고 있는 외국의 일부 입법례와는 달리 우리나라 행정소송법에는 명문의 규정이 없어 이로 인한 명시적 제한이 존재하지 않는다. 이와 같은 사정을 비롯하여 행정에 대한 사법통제, 권익구제의 확대와 같은

행정소송의 기능 등을 종합하여 보면, 행정처분의 근거 법률에 의하여 보호되는 직접적이고 구체적인 이익이 있는 경우에는 "행정소송법 제35조"에 규정된 무효확인을 구할 법률상 이익이 있다고 보아야 하고, 이와 별도로 무효확인소송의 보충성이 요구되는 것은 아니므로 행정처분의 무효를 전제로 한 이행소송 등과 같은 직접적인 구제수단이 있는지 여부를 따질 필요가 없다고 해석함이 상당하다.

<선정이유>

- 무효확인소송의 보충성을 요구하던 종전 판례 입장을 변경한 판결

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제01절 부작위위법확인소송>

334. 대상적격 (31) : 부작위위법확인소송의 경우

"대법원 2000. 2. 25. 선고 99두11455 판결"

<주제>

- 부작위위법확인소송의 요건

<쟁점>

- [1] "행정소송법 제4조 제3호" 소정의 부작위위법확인소의 소의 취지 및 요건
- [2] 국회의원인 대통령 및 외교통상부장관의 특임공관장에 대한 인사권 행사 등과 관련하여 그 임면과정이나 지위 변경 등에 관한 요구를 할 수 있는 법규상 또는 조리상 신청권을 갖고 있는지 여부(소극)

<판결요지>

- [1] "행정소송법 제4조 제3호"가 정하는 부작위위법확인소의 소는 행정청이 당사자의 법규상 또는 조리상의 권리에 기한 신청에 대하여 상당한 기간 내에 신청을 인용하는 적극적 처분 또는 각하하거나 기각하는 등의 소극적 처분을 하여야 할 법률상 응답의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 경우 그 부작위가 위법하다는 것을 확인함으로써 행정청의 응답을 신속하게 하여 부작위 또는 무응답이라고 하는 소극적 위법상태를 제거하는 것을 목적으로 하는 제도이고, 이러한 소송은 처분의 신청을 한 자로서 부작위가 위법하다는 확인을 구할 법률상의 이익이 있는 자만이 제기 할 수 있는 것이므로, 당사자가 행정청에 대하여 어떠한 행정처분을 하여 줄 것을 요청할 수 있는 법규상 또는 조리상의 권리를 갖고 있지 아니하거나 부작위의 위법확인을 구할 법률상의 이익이 없는 경우에는 항고소송의 대상이 되는 위법한 부작위가 있다고 볼 수 없거나 원고적격이 없어 그 부작위위법확인소의 소는 부적법하다.
- [2] 외무공무원의 정년 등을 규정한 외무공무원법상 일반 국민이나 국회의원 등이 외무공무원의 임면권자에 대하여 특임공관장의 임면과정이나 지위 변경 등에 관하여 어떠한 신청을 할 수 있다는 규정이 없을 뿐 아니라, 나아가 국회의원은 헌법이 부여한 권한에 따라 국정감사·조사권, 국무위원 등의 국회출석요구권·질문권, 국무위원 등의 해임건의권 등의 다양한 권한행사를 통하여 행정부의 위법·부당한 행위를 통제할 수 있고, 또한 국회법상 국회통일외교통상위원회는 외무공무원의 인사에 관한 사항 등 외교통상부 소관에 속하는 의안과 청원의 심사 등의 직무를 행하도록 규정되어 있기는 하지만, 이러한 규정들에 의하여 국회의원이 국무위원인 외교통상부장관에 대하여 정치적인 책임을 물을 수 있음은 별론으로 하고 국회의원 개개인에게 특임공관장의 인사사항에 관한 구체적인 신청권을 부여한 것이라고 할 수 없어서, 국회의원에게는 대통령 및 외교통상부장관의 특임공관장에 대한 인사권 행사 등과 관련하여 대사의 직을 계속 보유하게 하여서는 아니된다는 요구를 할 수 있는 법규상 신청권이 있다고 할 수 없고, 그 밖에 조리상으로도 그와 같은 신청권이 있다고 보여지지 아니한다.

<선정이유>

- 부작위위법확인소송이 적법하기 위해서는 부작위의 대상이 되는 행위를 신청할 신청권이 존재해야 하고 부작위의 위법을 확인할 법률상이 이익이 있어야 한다는 것을 밝힌 판결

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

405. 항고소송의 대상과 당사자소송의 대상

"대법원 2008. 4. 17. 선고 2005두16185 전원합의체 판결"

<주제>

- 특별법상 보상금의 지급을 구하는 소송의 유형

<쟁점>

- 민주화운동관련자 명예회복 및 보상 심의위원회의 보상금 등의 지급 대상자에 관한 결정이 행정처분인지 여부(적극) 및 "민주화운동관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률"에 따른 보상금 등의 지급을 구하는 소송의 형태(=취소소송)

<판결요지>

[다수의견]

- [1] "민주화운동관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률 제2조 제1호", "제2호 본문", "제4조", "제10조", "제11조", "제13조" 규정들의 취지와 내용에 비추어 보면, "같은 법 제2조 제2호 각목"은 민주화운동과 관련한 피해 유형을 추상적으로 규정한 것에 불과하여 "제2조 제1호"에서 정의하고 있는 민주화운동의 내용을 함께 고려하더라도 그 규정들만으로는 바로 법상의 보상금 등의 지급 대상자가 확정된다고 볼 수 없고, 민주화운동관련자 명예회복 및 보상 심의위원회에서 심의·결정을 받아야만 비로소 보상금 등의 지급 대상자로 확정될 수 있다. 따라서 그와 같은 심의위원회의 결정은 국민의 권리의무에 직접 영향을 미치는 행정처분에 해당하므로, 관련자 등으로서 보상금 등을 지급받고자 하는 신청에 대하여 심의위원회가 관련자 해당 요건

의 전부 또는 일부를 인정하지 아니하여 보상금 등의 지급을 기각하는 결정을 한 경우에는 신청인은 심의위원회를 상대로 그 결정의 취소를 구하는 소송을 제기하여 보상금 등의 지급대상자가 될 수 있다.

- [2] "민주화운동관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률 제17조"는 보상금 등의 지급에 관한 소송의 형태를 규정하고 있지 않지만, 위 규정 전단에서 말하는 보상금 등의 지급에 관한 소송은 민주화운동관련자 명예회복 및 보상 심의위원회의 보상금 등의 지급신청에 관하여 전부 또는 일부를 기각하는 결정에 대한 불복을 구하는 소송이므로 취소소송을 의미한다고 보아야 하며, 후단에서 보상금 등의 지급신청을 한 날부터 90일을 경과한 때에는 그 결정을 거치지 않고 위 소송을 제기할 수 있도록 한 것은 관련자 등에 대한 신속한 권리구제를 위하여 위 기간 내에 보상금 등의 지급여부 등에 대한 결정을 받지 못한 때에는 지급 거부 결정이 있는 것으로 보아 곧바로 법원에 심의위원회를 상대로 그에 대한 취소소송을 제기할 수 있다고 규정한 취지라고 해석될 뿐, 위 규정이 보상금 등의 지급에 관한 처분의 취소소송을 제한하거나 또는 심의위원회에 의하여 관련자 등으로 결정되지 아니한 신청인에게 국가를 상대로 보상금 등의 지급을 구하는 이행소송을 직접 제기할 수 있도록 허용하는 취지라고 풀이할 수는 없다.

<선정이유>

- "민주화운동관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률"에 따른 보상금 등의 지급을 구하는 소송은 행정처분인 민주화운동관련자 명예회복 및 보상 심의위원회의 지급기각결정의 취소를 구하는 취소소송이라는 판결

<관련판례>

- 대법원은 위와 달리 "구 광주민주화운동관련자보상등에관한법률"에 따른 보상금지급 청구 소송은 당사자소송에 의하여야 한다고 보았다(대법원 199 2. 12. 24. 선고 92누3335 판결).

- 광주민주화운동관련자보상등에관한법률 제15조 본문의 규정에서 말하는 광주민주화운동관련자보상심의위원회의 결정을 거치는 것은 보상금 지급에 관한 소송을 제기하기 위한 전치요건에 불과하다고 할 것이므로 위 보상심의위원회의 결정은 취소소송의 대상이 되는 행정처분이라고 할 수 없다. 같은 법에 의거하여 관련자 및 유족들이 갖게 되는 보상 등에 관한 권리는 "헌법 제23조 제3항"에 따른 재산권침해에 대한 손실보상청구나 국가배상법에 따른 손해배상청구와는 그 성질을 달리하는 것으로서 법률이 특별히 인정하고 있는 공법상의 권리라고 하여야 할 것이므로 그에 관한 소송은 "행정소송법 제3조 제2호" 소정의 당사자소송에 의하여야 할 것이며 보상금 등의 지급에 관한 법률관계의 주체는 대한민국이다.

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

406. 당사자소송의 대상 (1)

"대법원 2013. 3. 28. 선고 2012다102629 판결"

<주제>

- 공무원의 보수지급을 구하는 소송의 법적 성격

<쟁점>

- 지방소방공무원의 보수에 관한 법률관계가 공법상 법률관계인지 여부(적극) 및 지방소방공무원이 소속 지방자치단체를 상대로 초과근무수당의 지급을 구하는 소송을 제기하는 경우, 행정소송법상 당사자소송의 절차에 따라야 하는지 여부(적극)

<판결요지>

- 지방자치단체와 그 소속 경력직 공무원인 지방소방공무원 사이의 관계, 즉 지방소방공무원의 근무관계는 사법상의 근로계약관계가 아닌 공법상의 근무관계에 해당하고, 그 근무관계의 주요한 내용 중 하나인 지방소방공무원의 보수에 관한 법률관계는 공법상의 법률관계라고 보아야 한다. 나아가 "지방공무원법 제44조 제4항", "제45조 제1항"이 지방공무원의 보수에 관하여 이른바 근무조건 법정주의를 채택하고 있고, "지방공무원 수당 등에 관한 규정 제15조" 내지 "제17조"가 초과근무수당의 지급 대상, 시간당 지급 액수, 근무시간의 한도, 근무시간의 산정 방식에 관하여 구체적이고 직접적인 규정을 두고 있는 등 관계 법령의 내용, 형식 및 체제 등을 종합하여 보면, 지방소방공무원의 초과근무수당 지급청구권은 법령의 규정에 의하여 직접 그 존부나 범위가 정하여지고 법령에 규정된 수당의 지급요건에 해당하는 경우에는 곧바로 발생한다고 할 것이므로, 지방소방공무원이 자신이 소속된 지방자치단체를 상대로 초과근무수당의 지급을 구하는 청구에 관한 소송은 "행정소송법 제3조 제2호"에 규정된 당사자소송의 절차에 따라야 한다.

<선정이유>

- 지방소방공무원이 소속 지방자치단체를 상대로 초과근무수당의 지급을 구하는 소송은 행정소송법상 당사자소송이라는 판결

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

407. 당사자소송의 대상 (2)

"대법원 2016. 5. 24. 선고 2013두14863 판결"

<주제>

- 명예퇴직수당액이 법령상의 정당한 수당액에 미치지 못한다고 주장하며 차액의 지급을 구하는 소송의 법적 성격

<쟁점>

- [1] 공법상 법률관계에 관한 당사자소송의 피고적격 및 원고가 고의 또는 중대한 과실 없이 당사자소송으로 제기하여야 할 것을 항고소송으로 잘못 제기한 경우, 법원이 취할 조치

- [2] 법관이 이미 수령한 명예퇴직수당액이 "구 법관 및 법원공무원 명예퇴직수당 등 지급규칙 제4조 [별표 1]"에서 정한 정당한 수당액에 미치지 못한다고 주장하며 차액의 지급을 신청한 것에 대하여 법원행정처장이 거부하는 의사를 표시한 경우, 위 의사표시를 행정처분으로 볼 수 있는지 여부(소극) / 명예퇴직한 법관이 미지급 명예퇴직수당액의 지급을 구하는 경우, 소송 형태(=행정소송법의 당사자소송)

### <판결요지>

- [1] 공법상의 법률관계에 관한 당사자소송에서는 그 법률관계의 한쪽 당사자를 피고로 하여 소송을 제기하여야 한다("행정소송법 제3조 제2호", "제39조"). 다만 원고가 고의 또는 중대한 과실 없이 당사자소송으로 제기하여야 할 것을 항고소송으로 잘못 제기한 경우에, 당사자소송으로서의 소송요건을 결하고 있음이 명백하여 당사자소송으로 제기되었더라도 어차피 부적법하게 되는 경우가 아닌 이상, 법원으로서 원고가 당사자소송으로 소 변경을 하도록 하여 심리·판단하여야 한다.

- [2] 명예퇴직수당 지급대상자의 결정과 수당액 산정 등에 관한 "구 국가공무원법 제74조의2 제1항", "제4항", "구 법관 및 법원공무원 명예퇴직수당 등 지급규칙(이하 명예퇴직수당규칙) 제3조 제1항", "제2항", "제7조", "제4조 [별표 1]"의 내용과 취지 등에 비추어 보면, 명예퇴직수당은 명예퇴직수당 지급신청자 중에서 일정한 심사를 거쳐 피고가 명예퇴직수당 지급대상자로 결정한 경우에 비로소 지급될 수 있지만, 명예퇴직수당 지급대상자로 결정된 법관에 대하여 지급할 수당액은 "명예퇴직수당규칙 제4조 [별표 1]"에 산정 기준이 정해져 있으므로, 위 법관은 위 규정에서 정한 정당한 산정기준에 따라 산정된 명예퇴직수당액을 수령할 구체적인 권리를 가진다. 따라서 위 법관이 이미 수령한 수당액이 위 규정에서 정한 정당한 명예퇴직수당액에 미치지 못한다고 주장하며 차액의 지급을 신청함에 대하여 법원행정처장이 거부하는 의사를 표시했더라도, 그 의사표시는 명예퇴직수당액을 형성·확정하는 행정처분이 아니라 공법상의 법률관계의 한쪽 당사자로서 지급의무의 존부 및 범위에 관하여 자신의 의견을 밝힌 것에 불과하므로 행정처분으로 볼 수 없다. 결국 명예퇴직한 법관이 미지급 명예퇴직수당액에 대하여 가지는 권리는 명예퇴직수당 지급대상자 결정 절차를 거쳐 명예퇴직수당규칙에 의하여 확정된 공법상 법률관계에 관한 권리로서, 그 지급을 구하는 소송은 행정소송법의 당사자소송에 해당하며, 그 법률관계의 당사자인 국가를 상대로 제기하여야 한다.

### <선정이유>

- 명예퇴직한 법관이 미지급 명예퇴직수당액의 지급을 구하는 소송은 행정소송법상 당사자소송으로서 그 법률관계의 당사자인 국가를 상대로 제기하여야 한다고 판시한 판결

## <제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

### 408. 당사자소송의 대상 (3)

"대법원 2009. 9. 17. 선고 2007다2428 전원합의체 판결"

#### <주제>

- 관리처분계획안에 대한 조합 총회결의의 효력을 다투는 소송의 법적 성격, 소의 이익, 소의 이송

#### <쟁점>

- [1] 도시 및 주거환경정비법상의 주택재건축정비사업조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 조합총회결의의 효력을 다투는 소송의 법적 성질(=행정소송법상 당사자소송)
- [2] 도시 및 주거환경정비법상의 주택재건축정비사업조합이 "같은 법 제48조"에 따라 수립한 관리처분계획에 대하여 관할 행정청의 인가·고시가 있는 후에, 그 관리처분계획안에 대한 총회결의의 무효확인을 구할 수 있는지 여부(소극)
- [3] 도시 및 주거환경정비법상의 주택재건축정비사업조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 총회결의의 무효확인을 구하는 소를 민사소송으로 제기한 사안에서, 그 소는 행정소송법상 당사자소송에 해당하므로 행정법원의 전속관할에 속한다고 한 사례
- [4] 주택재건축정비사업조합의 관리처분계획에 대하여 그 관리처분계획안에 대한 총회결의의 무효확인을 구하는 소가 관할을 위반하여 민사소송으로 제기된 후에 관할 행정청의 인가·고시가 있었다는 사정만으로 그 소가 이송된 후 부적법 각하될 것이 명백한 경우에 해당한다고 보기 어려워, 위 소는 관할법원인 행정법원으로 이송함이 상당하다고 한 사례

### <판결요지>

- [1] 도시 및 주거환경정비법상 행정주체인 주택재건축정비사업조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 조합 총회결의의 효력 등을 다투는 소송은 행정처분에 이르는 절차적 요건의 존부나 효력 유무에 관한 소송으로서 그 소송결과에 따라 행정처분의 위법 여부에 직접 영향을 미치는 공법상 법률관계에 관한 것이므로, 이는 행정소송법상의 당사자소송에 해당한다.
- [2] "도시 및 주거환경정비법"상 주택재건축정비사업조합이 "같은 법 제48조"에 따라 수립한 관리처분계획에 대하여 관할 행정청의 인가·고시까지 있게 되면 관리처분계획은 행정처분으로서 효력이 발생하게 되므로, 총회결의의 하자를 이유로 하여 행정처분의 효력을 다투는 항고소송의 방법으로 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구하여야 하고, 그와 별도로 행정처분에 이르는 절차적 요건 중 하나에 불과한 총회결의의 부분만을 따로 떼어내어 효력 유무를 다투는 확인의 소를 제기하는 것은 특별한 사정이 없는 한 허용되지 않는다.
- [3] "도시 및 주거환경정비법"상의 주택재건축정비사업조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 총회결의의 무효확인을 구하는 소를 민사소송으로 제기한 사안에서, 그 소는 행정소송법상 당사자소송에 해당하므로 전속관할이 행정법원에 있다고 한 사례.
- [4] 주택재건축정비사업조합의 관리처분계획에 대하여 그 관리처분계획안에 대한 총회결의의 무효확인을 구하는 소가 관할을 위반하여 민사소송으로 제기된 후에 관할 행정청의 인가·고시가 있었던 경우 따로 총회결의의 무효확인만을 구할 수는 없게 되었으나, 이송 후 행정법원의 허가를 얻어 관리처분계획에 대한 취소소송 등으로 변경될 수 있음을 고려하면, 그와 같은 사정만으로 이송 후 그 소가 부적법하게 되어 각하될 것이 명백한 경우에 해당한다고 보기 어려우므로, 위 소는 관할법원인 행정법원으로 이송함이 상당하다고 한 사례

### <선정이유>

- 관리처분계획안에 대한 조합 총회결의의 효력을 다투는 소송은 "행정소송법"상 당사자소송에 해당하나, 관할청의 인가·고시로 관리처분계획에 행정처분으로서의 효력이 발생한 이후에는 항고소송에서 관리처분계획의 취소 또는 무효확인을 구하여야 하고, 행정처분에 이르는 절차적 요건 중 하나에 불과한 총회결의의 부분만을 따로 떼어내어 당사자소송으로 다투는 것은 허용되지 않음을 명확히 한 판결

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

409. 당사자소송에서 소의 이익

“대법원 2002. 11. 26. 선고 2002두1496 판결”

<주제>

- 당사자소송에서 소의 이익

<쟁점>

- 지방자치단체와 채용계약에 의하여 채용된 계약직공무원이 그 계약기간 만료 이전에 채용계약해지 등의 불이익을 받은 후 그 계약기간이 만료된 경우, 채용계약 해지의사표시의 무효확인을 구할 소의 이익이 있는지 여부(소극)

<판결요지>

- 지방자치단체와 채용계약에 의하여 채용된 계약직공무원이 그 계약기간 만료 이전에 채용계약해지 등의 불이익을 받은 후 그 계약기간이 만료된 때에는 그 채용계약 해지의 의사표시가 무효라고 하더라도, 지방공무원법이나 지방계약직공무원규정 등에서 계약기간이 만료되는 계약직공무원에 대한 재계약의무를 부여하는 근거규정이 없으므로 계약기간의 만료로 당연히 계약직공무원의 신분을 상실하고 계약직공무원의 신분을 회복할 수 없는 것이므로, 그 해지의사표시의 무효확인청구는 과거의 법률관계의 확인청구에 지나지 않는다 할 것이고, 한편 과거의 법률관계라 할지라도 현재의 권리 또는 법률상 지위에 영향을 미치고 있고 현재의 권리 또는 법률상 지위에 대한 위험이나 불안을 제거하기 위하여 그 법률관계에 관한 확인판결을 받는 것이 유효 적절한 수단이라고 인정될 때에는 그 법률관계의 확인소송은 즉시확정의 이익이 있다고 보아야 할 것이나, 계약직공무원에 대한 채용계약이 해지된 경우에는 공무원 등으로 임용되는 데에 있어서 법령상의 아무런 제약사유가 되지 않을 뿐만 아니라, 계약기간 만료 전에 채용계약이 해지된 전력이 있는 사람이 공무원 등으로 임용되는 데에 있어서 그러한 전력이 없는 사람보다 사실상 불이익한 장애사유로 작용한다고 하더라도 그것만으로는 법률상의 이익이 침해되었다고 볼 수는 없으므로 그 무효확인을 구할 이익이 없다.

<선정이유>

- 공법상 계약의 무효확인을 구하는 당사자소송은 확인의 이익이 요구되며, 계약직공무원이 계약기간 만료 이전에 채용계약 해지 등의 불이익을 받았다 하더라도 그 계약기간이 만료된 경우에는 채용계약 해지의사표시의 무효확인을 구할 소의 이익이 없다고 판시한 판결

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제02절 당사자소송>

410. 당사자소송에서 가구제

“대법원 2015. 8. 21.자 2015무26 결정”

<주제>

- 민사집행법상 가처분 규정의 준용

<쟁점>

- 도시 및 주거환경정비법상 주택재건축정비사업조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 조합 총회결의의 효력을 다투는 소송을 본안으로 하는 가처분에 대하여 민사집행법상 가처분에 관한 규정이 준용되는지 여부(적극)

<판결요지>

- “도시 및 주거환경정비법(이하 ‘도시정비법’이라 한다)”상 행정주체인 주택재건축정비사업조합을 상대로 관리처분계획안에 대한 조합 총회결의의 효력을 다투는 소송은 행정처분에 이르는 절차적 요건의 존부나 효력 유무에 관한 소송으로서 소송결과에 따라 행정처분의 위법 여부에 직접 영향을 미치는 공법상 법률관계에 관한 것이므로, 이는 행정소송법상 당사자소송에 해당한다. 그리고 이러한 당사자소송에 대하여는 “행정소송법 제23조 제2항”의 집행정지에 관한 규정이 준용되지 아니하므로(“행정소송법 제44조 제1항” 참조), 이를 본안으로 하는 가처분에 대하여는 “행정소송법 제8조 제2항”에 따라 민사집행법상 가처분에 관한 규정이 준용되어야 한다.

<선정이유>

- 항고소송과는 달리 당사자소송에 대하여는 “민사집행법”상 가처분에 관한 규정이 준용된다는 판결

<제11장 행정심판의 일반론.제01절 서설>

290. 이의신청과 제소기간

“대법원 2012. 11. 15. 선고 2010두8676 판결”

<주제>

- 이의신청과 행정심판

<쟁점>

- 민원사무처리법에서 정한 민원 이의신청에 대하여 행정소송법에서 정한 행정심판을 거친 경우의 제소기간의 특례가 적용되는지 여부

<판결요지>

- [1] "행정소송법 제18조" 내지 "제20조", "행정심판법 제3조 제1항", "제4조 제1항", "민원사무처리에 관한 법률(이하 '민원사무처리법'이라 한다)제18조", "같은 법 시행령 제29조" 등의 규정들과 그 취지를 종합하여 보면, 민원사무처리법에서 정한 민원 이의신청의 대상인 거부처분에 대하여는 민원 이의신청과 상관없이 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있으며, 또한 민원 이의신청은 민원사무처리에 관하여 인정된 기본사항의 하나로 처분청으로 하여금 다시 거부처분에 대하여 심사하도록 한 절차로서 행정심판법에서 정한 행정심판과는 성질을 달리하고 또한 사안의 전문성과 특수성을 살리기 위하여 특별한 필요에 따라 둔 행정심판에 대한 특별 또는 특례 절차라 할 수도 없어 행정소송법에서 정한 행정심판을 거친 경우의 제소기간의 특례가 적용된다고 할 수도 없으므로, 민원 이의신청에 대한 결과를 통지받은 날부터 취소소송의 제소기간이 기산된다고 할 수 없다. 그리고 이와 같이 민원 이의신청 절차와는 별도로 그 대상이 된 거부처분에 대하여 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있도록 보장하고 있는 이상, 민원 이의신청 절차에 의하여 국민의 권익 보호가 소홀하게 된다고나 "헌법 제27조"에서 정한 재판청구권이 침해된다고 볼 수도 없다.

- [2] "민원사무처리에 관한 법률(이하 '민원사무처리법'이라 한다)제18조 제1항"에서 정한 거부처분에 대한 이의신청(이하 '민원 이의신청'이라 한다)은 행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위로 침해된 국민의 권리 또는 이익을 구제함을 목적으로 하여 행정청과 별도의 행정심판기관에 대하여 불복할 수 있도록 한 절차인 행정심판과는 달리, 민원사무처리법에 의하여 민원사무처리를 거부한 처분청이 민원인의 신청 사항을 다시 심사하여 잘못이 있는 경우 스스로 시정하도록 한 절차이다. 이에 따라, 민원인의신청을 받아들이는 경우에는 이의신청 대상인 거부처분을 취소하지 않고 바로 최초의 신청을 받아들이는 새로운 처분을 하여야 하지만, 이의신청을 받아들이지 않는 경우에는 다시 거부처분을 하지 않고 그 결과를 통지함에 그칠 뿐이다. 따라서 이의신청을 받아들이지 않는 취지의 기각 결정 내지는 그 취지의 통지는, 종전의 거부처분을 유지함을 전제로 한 것에 불과하고 또한 거부처분에 대한 행정심판이나 행정소송의 제기에도 영향을 주지 못하므로, 결국 민원 이의신청인의 권리 · 의무에 새로운 변동을 가져오는 공권력의 행사나 이에 준하는 행정작용이라고 할 수 없어, 독자적인 항고소송의 대상이 된다고 볼 수 없다고 봄이 타당하다.

#### <선정이유>

- 민원사무처리법에서 정한 민원 이의신청에 대하여 행정소송법에서 정한 행정심판을 거친 경우의 제소기간의 특례가 적용되지 않고, 이의신청을 받아들이지 않는 취지의 기각 결정 내지는 그 취지의 통지는 항고소송의 대상이 되지 않는다는 판결

---

### <제11장 행정심판의 일반론.제01절 서설>

#### 291. 이의신청의 기각과 거부처분

“대법원 2021. 1. 14. 선고 2020두50324 판결”

##### <주제>

- 이의신청이 기각이 거부처분에 해당하는지 여부

##### <쟁점>

- [1] 행정청의 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지 결정하는 방법 및 행정청의 행위가 처분에 해당하는지 불분명한 경우, 이를 판단하는 방법
- [2] 수직적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 있을 후 당사자가 새로운 신청을 하는 취지로 다시 신청을 하였으나 행정청이 이를 다시 거절한 경우, 새로운 거부처분인지 여부(적극)

##### <판결요지>

- [1] 항고소송의 대상인 처분이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용("행정소송법 제2조 제1항 제1호")을 말한다. 행정청의 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지는 추상적 · 일반적으로 결정할 수 없고, 구체적인 경우에 관련 법령의 내용과 취지, 그 행위의 주체 · 내용 · 형식 · 절차, 그 행위와 상대방 등 이해관계인이 입는 불이익 사이의 실질적 견련성, 법치행정의 원리와 그 행위에 관련된 행정청이나 이해관계인의 태도 등을 고려하여 개별적으로 결정하여야 한다. 행정청의 행위가 처분에 해당하는지 불분명한 경우에는 그에 대한 불복방법 선택에 중대한 이해관계를 가지는 상대방의 인식가능성과 예측가능성을 중요하게 고려하여 규범적으로 판단하여야 한다.
- [2] 수직적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분은 당사자의 신청에 대하여 관할 행정청이 이를 거절하는 의사를 대외적으로 명백히 표시함으로써 성립된다. 거부처분이 있을 후 당사자가 다시 신청을 한 경우에는 신청의 제목 여하에 불구하고 그 내용이 새로운 신청을 하는 취지라면 관할 행정청이 이를 다시 거절하는 것은 새로운 거부처분이라고 보아야 한다. 관계 법령이나 행정청이 사전에 공표한 처분기준에 신청기간을 제한하는 특별한 규정이 없는 이상 재신청을 불허할 법적 근거가 없으며, 실령 신청기간을 제한하는 특별한 규정이 있더라도 재신청이 신청기간을 도과하였는지는 본안에서 재신청에 대한 거부처분이 적법한가를 판단하는 단계에서 고려할 요소이지, 소송요건 심사단계에서 고려할 요소가 아니다.

#### <선정이유>

- 수직적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 있을 후 당사자가 새로운 신청을 하는 취지로 다시 신청을 하였으나 행정청이 이를 다시 거절한 경우, 이를 이의신청의 기각으로 보아 제소기간을 원래의 처분시로 보지 않고 새로운 거부처분으로 보아 이의신청의 기각결정을 받은 날로부터 기산한다고 보았다는 점에서 의미있는 판결

---

### <제11장 행정심판의 일반론.제01절 서설>

#### 292. 이의신청을 거친 2차통지의 처분성

“대법원 2022. 3. 17. 선고 2021두53894 판결”

##### <주제>

- 이의신청을 거친 2차 통지의 처분성

##### <쟁점>

- [1] 행정청의 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지 결정하는 방법 및 행정청의 행위가 처분에 해당하는지가 불분명한 경우, 이를 판단하는 방법

- [2] 수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 있을 후 당사자가 새로운 신청을 하는 취지로 다시 신청을 하였으나 행정청이 이를 다시 거절한 경우, 새로운 거부처분인지 여부(적극) / 어떤 처분이 수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 아니더라도 해당 처분에 대한 이의신청의 내용이 새로운 신청을 하는 취지로 볼 수 있는 경우, 그 이의신청에 대한 결정의 통보를 새로운 처분으로 볼 수 있는지 여부(적극)

**<판결요지>**

- [1] 항고소송의 대상인 처분이란 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용 ("행정소송법 제2조 제1항 제1호")을 말한다. 행정청의 행위가 항고소송의 대상이 될 수 있는지는 추상적·일반적으로 결정할 수 없고, 구체적인 경우에 관련 법령의 내용과 취지, 그 행위의 주체·내용·형식·절차, 그 행위와 상대방 등 이해관계인이 입는 불이익 사이의 실질적 견련성, 법치행정의 원리와 그 행위에 관련된 행정청이나 이해관계인의 태도 등을 고려하여 개별적으로 결정하여야 한다. 행정청의 행위가 처분에 해당하는지가 불분명한 경우에는 그에 대한 불복방법 선택에 중대한 이해관계를 가지는 상대방의 인식가능성과 예측가능성을 중요하게 고려하여 규범적으로 판단하여야 한다.

- [2] 수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 있을 후 당사자가 다시 신청을 한 경우에는 신청의 제목 여하에 불구하고 그 내용이 새로운 신청을 하는 취지라면 관할 행정청이 이를 다시 거절하는 것은 새로운 거부처분이라고 보아야 한다. 나아가 어떠한 처분이 수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 아니라고 하더라도, 해당 처분에 대한 이의신청의 내용이 새로운 신청을 하는 취지로 볼 수 있는 경우에는, 그 이의신청에 대한 결정의 통보를 새로운 처분으로 볼 수 있다.

- [3] 갑 시장이 을 소유 토지의 경계확정으로 지적공부상 면적이 감소되었다는 이유로 지적재조사위원회의 의결을 거쳐 을에게 조정금 수령을 통지하자(1차 통지), 을이 구체적인 이의신청 사유와 소명자료를 첨부하여 이의를 신청하였으나, 갑 시장이 지적재조사위원회의 재산정 심의·의결을 거쳐 종전과 동일한 액수의 조정금 수령을 통지한(2차 통지) 사안에서, "구 지적재조사에 관한 특별법 제21조의2"가 신설되면서 조정금에 대한 이의신청 절차가 법률상 절차로 변경되었으므로 그에 관한 절차적 권리는 법률상 권리로 볼 수 있는 점, 을이 이의신청을 하기 전에는 조정금 산정결과 및 수령을 통지한 1차 통지만 존재하였고 을은 신청 자체를 한 적이 없으므로 을의 이의신청은 새로운 신청으로 볼 수 있는 점, 2차 통지서의 문언상 종전 통지와 별도로 심의·의결하였다는 내용이 명백하고, 단순히 이의신청을 받아들이지 않는다는 내용에 그치는 것이 아니라 조정금에 대하여 다시 재산정, 심의·의결절차를 거친 결과, 그 조정금이 종전 금액과 동일하게 산정되었다는 내용을 알리는 것이므로, 2차 통지를 새로운 처분으로 볼 수 있는 점 등을 종합하면, 2차 통지는 1차 통지와 별도로 행정쟁송의 대상이 되는 처분으로 보는 것이 타당함에도 2차통지의 처분성을 부정한 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

**<선정이유>**

- 수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 있을 후 당사자가 새로운 신청을 하는 취지로 다시 신청을 하였으나 행정청이 이를 다시 거절한 경우, 새로운 거부처분으로 보았고, 어떤 처분이 수익적 행정처분을 구하는 신청에 대한 거부처분이 아니더라도 해당 처분에 대한 이의신청의 내용이 새로운 신청을 하는 취지로 볼 수 있는 경우, 그 이의신청에 대한 결정의 통보를 새로운 처분으로 볼 수 있다고 본 판결

**<제11장 행정심판의 일반론.제01절 서설>**

**293. 이의신청 단계에서 처분사유의 추가·변경**

**"대법원 2012. 9. 13. 선고 2012두3859 판결"**

**<주제>**

- 이의신청 단계에서의 처분사유의 추가·변경

**<쟁점>**

- 산업재해보상보험법상 심사청구에 관한 절차의 성격(=근로복지공단 내부의시정절차)및 그 절차에서 근로복지공단이 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않는 사유를 처분사유로 추가·변경할 수 있는지 여부

**<판결요지>**

- [1] 산업재해보상보험법 규정의 내용, 형식 및 취지 등에 비추어 보면, 산업재해보상보험법상 심사청구에 관한 절차는 보험급여 등에 관한 처분을 한 근로복지공단으로 하여금 스스로의 심사를 통하여 당해 처분의 적법성과 합목적성을 확보하도록 하는 근로복지공단 내부의 시정절차에 해당한다고 보아야 한다. 따라서 처분청이 스스로 당해 처분의 적법성과 합목적성을 확보하고자 행하는 자신의 내부 시정절차에서는 당초처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않는 사유라고 하더라도 이를 처분의 적법성과 합목적성을 뒷받침하는 처분사유로 추가·변경할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

- [2] 근로복지공단이 우측 감각신경성 난청으로 장해보상청구를 한 근로자 甲에 대하여 소멸시효 완성을 이유로 장해보상급여부지급결정을 하였다가, 甲이 불복하여 심사청구를 하자 甲의 상병이 업무상 재해인 소음성 난청으로 보기 어렵다는 처분사유를 추가하여 심사청구를 기각한 사안에서, 근로복지공단이 산업재해보상보험법상 심사청구에 대한 자신의 심리·결정 절차에서 추가한 사유인 甲의 상병과 업무 사이의 상당인과관계 부존재는 당초 처분의 근거로 삼은 사유인 소멸시효 완성과 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는지와 상관없이 처분의 적법성의 근거가 되는 것으로서 취소소송에서 처음부터 판단대상이 되는 처분사유에 해당한다는 이유로, 甲의 상병과 업무사이의 상당인과관계 부존재를 처분사유 중 하나로 본 원심판단을 정당하다고 한 사례

**<선정이유>**

- 처분청이 스스로 당해 처분의 적법성과 합목적성을 확보하고자 행하는 자신의 내부 시정절차에서는 당초처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않는 사유라고 하더라도 이를 처분의 적법성과 합목적성을 뒷받침하는 처분사유로 추가·변경할 수 있다고 한 판결

**<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제03절 행정심판의 청구>**

**296. 심판청구기간**

“대법원 1996. 9. 6. 선고 95누16233 판결”

<주제>

- 행정심판의 심판청구기간

<쟁점>

- 행정처분의 상대방이 아닌 제3자가 그 행정처분이 있음을 알았거나 쉽게 알 수 있는 경우, 행정심판의 청구기간

<판결요지>

- [1] 특별한 사유가 없는 한 “구 행정심판법 제18조 제3항 단서” 소정의 정당한 사유가 있는 것으로 보아 심판청구가 가능하나, 그 제3자가 어떤 경우든 행정처분이 있음을 알았거나 쉽게 알 수 있는 등 “행정심판법 제18조 제1항” 소정의 심판청구기간 내에 심판청구가 가능하였다는 사정이 있는 경우에는 그 때로부터 60일 이내에 행정심판을 청구하여야 한다. (\*헌행 행정심판법의 청구기간은 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내임, “동법 제27조 제1항”)

- [2] 행정처분의 상대방이 아닌 제3자가 당사자로 된 소송에서 그 행정처분에 의하여 발급된 농지매매증명서가 증거로 제출되고 이를 기초로 판결이 선고된 경우, 그 제3자는 적어도 그 증거가 제출된 날 또는 적어도 그 판결문이 송달된 날 그 행정처분(농지매매증명 발급처분)이 있었음을 알았거나 쉽게 알 수 있었다고 보아야 하므로, 그 날로부터 60일이 지나서 제기한 행정심판 청구는 부적법하다는 이유로, 그 심판청구를 전심절차로 하여 제기한 행정소송을 각하한 사례.

<선정이유>

- 행정처분의 상대방이 아닌 제3자는 일반적으로 처분이 있는 것을 바로 알 수 없는 처지에 있으므로 “구 행정심판법 제18조 제3항” (“헌 행정심판법 제27조 제3항”)의 정당한 사유가 있는 것으로보아 예외적으로 처분이 있는 날로부터 180일이 경과하더라도 행정심판을 청구할 수 있으나, 행정처분의 상대방이 아닌 제3자가 그 행정처분이 있음을 알았거나 쉽게 알 수 있는 경우는 그와 같은 예외에 해당하지 않는다는 판결

<제12장 행정심판의 청구요건 및 가구제.제03절 행정심판의 청구>

297. 심판청구의 방식

“대법원 2000. 6. 9. 선고 98두2621 판결”

<주제>

- 행정심판청구의 방식

<쟁점>

- 불비된 사항이 있거나 취지가 불명확한 행정심판청구서의 처리방법

<판결요지>

- [1] “행정심판법 제19조”, “제23조”의 규정 취지와 행정심판제도의 목적에 비추어 보면 행정소송의 전치요건인 행정심판청구는 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위로 해석되므로, 위법 부당한 행정처분으로 인하여 권리나 이익을 침해당한 자로부터 그 처분의 취소나 변경을 구하는 서면이 제출되었을 때에는 그 표제와 제출기관의 여하를 불문하고 이를 “행정소송법 제18조” 소정의 행정심판청구로 보고, 불비된 사항이 보정가능한 때에는 보정을 명하고 보정이 불가능하거나 보정명령에 따르지 아니한 때에 비로소 부적법 각하를 하여야 할 것이며, 더욱이 심판청구인은 일반적으로 전문적 법률지식을 갖고 있지 못하여 제출된 서면의 취지가 불명확한 경우도 적지 않으나, 이러한 경우에도 행정청으로서의 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 해석하고 처리하여야 한다.

- [2] 비록 제목이 진정서로 되어 있고, 재결청의 표시, 심판청구의 취지 및 이유, 처분을 한 행정청의 고지의 유무 및 그 내용 등 “행정심판법 제19조 제2항” 소정의 사항들을 구분하여 기재하고 있지 아니하여 행정심판청구서로서의 형식을 다 갖추고 있다고 볼 수는 없으나, 피청구인인 처분청과 청구인의 이름과 주소가 기재되어 있고, 청구인의 기명이 되어 있으며, 문서의 기재 내용에 의하여 심판청구의 대상이 되는 행정처분의 내용과 심판청구의 취지 및 이유, 처분이 있는 것을 안날을 알 수 있는 경우, 위 문서에 기재되어 있지 않은 재결청, 처분을 한 행정청의 고지의 유무 등의 내용과 날인 등의 불비한 점은 보정이 가능하므로 위 문서를 행정처분에 대한 행정심판청구로 보는 것이 옳다고 한 사례

<선정이유>

- 위법 부당한 행정처분으로 인하여 권리나 이익을 침해당한 자로부터 그 처분의 취소나 변경을 구하는 서면이 제출되었을 때에는 그 표제와 제출기관의 여하를 불문하고 이를 “행정소송법 제18조” 소정의 행정심판청구로 보고, 불비된 사항이 보정가능한 때에는 보정을 명하고 보정이 불가능하거나 보정명령에 따르지 아니한 때에 비로소 부적법 각하를 하여야 할 것이라는 판결

<제13장 행정심판의 심리·재결.제01절 행정심판의 심리>

298. 처분사유의 추가·변경

“대법원 2014. 5. 16. 선고 2013두26118 판결”

<주제>

- 행정심판 단계에서의 처분사유의 추가·변경

<쟁점>

- 항고소송에서 행정청이 처분의 근거 사유를 추가하거나 변경하기 위한 요건인 기본적 사실관계의 동일성 유무의 판단 방법 및 이러한 법리가 행정심판 단계에서도 적용되는지 여부

<판결요지>

- 행정처분의 취소를 구하는 항고소송에서 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가 또는 변경할 수 있고, 이러한 기본적 사실관계의 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지에 따라 결정되므로, 추가 또는 변경된 사유가 처분 당시에 이미 존재하고 있었다거나 당사자가 그 사실을 알고 있었다고 하여 당초의 처분사유와 동일성이 있다고 할 수 없다. 그리고 이러한 법리는 행정심판 단계에서도 그대로 적용된다.

<선정이유>

- 행정처분의 취소를 구하는 항고소송에서 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가 또는 변경할 수 있는바, 이 법리는 행정심판에서도 그대로 적용된다는 판결

<제13장 행정심판의 심리·재결.제02절 행정심판의 재결>

299. 재결의 효력 (1)

“대법원 2003. 4. 25. 선고 2002두3201 판결”

<주제>

- 재결의 기속력의 내용으로서의 재처분의무

<쟁점>

- 행정청이 당해 처분에 관하여 위법한 것으로 재결에서 판단된 사유와 기본적 사실관계에 있어 동일성이 인정되는 사유를 내세워 다시 동일한 내용의 처분을 하는 것이 허용되는지 여부

<판결요지>

- [1] "행정심판법 제37조"가 정하고 있는 재결은 당해 처분에 관하여 재결주문 및 그 전제가 된 요건사실의 인정과 판단에 대하여 처분청을 기속하므로, 당해 처분에 관하여 위법한 것으로 재결에서 판단된 사유와 기본적 사실관계에 있어 동일성이 인정되는 사유를 내세워 다시 동일한 내용의 처분을 하는 것은 허용되지 않는다.  
- [2] 건축허가권자는 건축허가신청이 건축법, 도시계획법 등 관계 법규에서 정하는 어떠한 제한에 배치되지 않는 이상 당연히 같은 법조에서 정하는 건축허가를 하여야 하고, 증대한 공익상의 필요가 없음에도 불구하고, 요건을 갖춘 자에 대한 허가를 관계 법령에서 정하는 제한 사유 이외의 사유를 들어 거부할 수는 없다.

<선정이유>

- 행정청이 당해 처분에 관하여 위법한 것으로 재결에서 판단된 사유와 기본적 사실관계에 있어 동일성이 인정되는 사유를 내세워 다시 동일한 내용의 처분을 하는 것이 허용되지 않는다는 판결로서 행정심판 재결의 기속력에 관하여 판단하고 있는 판결

<제13장 행정심판의 심리·재결.제02절 행정심판의 재결>

300. 재결의 효력 (2)

“대법원 1998. 4. 24. 선고 97누17131 판결”

<주제>

- 재결의 형성력

<쟁점>

- 원처분에 대한 형성적 취소재결이 확정된 후 처분청이 다시 원처분을 취소한 경우, 위 처분이 항고소송의 대상이 되는 처분인지 여부

<판결요지>

- [1] "행정심판법 제32조 제3항"에 의하면 재결청은 취소심판의 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 처분을 취소·변경하거나 처분청에게 취소·변경할 것을 명한다고 규정하고 있으므로, 행정심판 재결의 내용이 처분청에게 처분의 취소를 명하는 것이 아니라 재결청이 스스로 처분을 취소하는 것일 때에는 그 재결의 형성력에 의하여 당해 처분은 별도의 행정처분을 기다릴 것 없이 당연히 취소되어 소멸되는 것이다.  
- [2] 당해 의약품제조품목허가처분취소재결은 보건복지부장관이 재결청의 지위에서 스스로 제약회사에 대한 위 의약품제조품목허가처분을 취소한 이른바 형성재결임이 명백하므로, 위 회사에 대한의약품제조품목허가처분은 당해 취소재결에 의하여 당연히 취소·소멸되었고, 그 이후에 다시 위 허가처분을 취소한 당해 처분은 당해 취소재결의 당사자가 아니어서 그 재결이 있었음을 모르고 있는 위 회사에게 위 허가처분이 취소·소멸되었음을 확인하여 알려주는 의미의 사실 또는 관념의 통지에 불과할 뿐 위 허가처분을 취소·소멸시키는 새로운 형성적 행위가 아니므로 항고소송의 대상이 되는 처분이라고 할 수 없다.  
- [3] 당해 사안에서와 같이 원처분의 상대방이 아닌 제3자가 행정심판을 청구하여 재결청이 원처분을 취소하는 형성재결을 한 경우에 그 원처분의 상대방은 그 재결에 대하여 항고소송을 제기할 수밖에 없고, 이 경우 재결은 원처분과 내용을 달리 하는 것이어서 재결의 취소를 구하는 것은 원처분에 없는 재결 고유의 위법을 주장하는 것이 된다.

<선정이유>

- 행정심판 재결의 내용이 처분청에게 처분의 취소를 명하는 것이 아니라 재결청이 스스로 처분을 취소하는 것일 때에는 그 재결의 형성력에 의하여 당해 처분은 별도의 행정처분을 기다릴 것 없이 당연히 취소되어 소멸되므로, 형성적 취소재결이 확정된 후 처분청이 다시 원처분을 취소한 경우, 그 취소 처분은 항고소송의 대상이 되지 않는다는 판결

<제13장 행정심판의 심리·재결.제02절 행정심판의 재결>

301. 재결의 효력 (3)

“대법원 2015. 11. 27. 선고 2013다6759 판결”

<주제>

- 행정심판 재결의 효력

<쟁점>

- 재결이 확정된 경우, 처분의 기초가 되는 사실관계나 법률적 판단이 확정되고 당사자들이나 법원이 이에 기속되어 모순되는 주장이나 판단을 할 수 없는지 여부

<판결요지>

- [1] 행정심판의 재결은 피청구인인 행정청을 기속하는 효력을 가지므로 재결청이 취소심판의 청구가 이유 있다고 인정하여 처분청에 처분을 취소할 것을 명하면 처분청으로서는 재결의 취지에 따라 처분을 취소하여야 하지만, 나아가 재결에 판결에서와 같은 기판력이 인정되는 것은 아니어서 재결이 확정된 경우에도 처분의 기초가 된 사실관계나 법률적 판단이 확정되고 당사자들이나 법원이 이에 기속되어 모순되는 주장이나 판단을 할 수 없게 되는 것은 아니다.

- [2] 행정청의 처분을 구하는 신청에 대하여 상당한 기간 처분 여부 결정이 지체되었다고 하여 곧바로 공무원의 고의 또는 과실에 의한 불법행위를 구성한다고 단정할 수는 없고, 행정처분의 담당공무원이 보통 일반의 공무원을 표준으로 하여 볼 때 객관적 주의의무를 결하여 처분 여부 결정을 지체함으로써 객관적 정당성을 상실하였다고 인정될 정도에 이른 경우에 비로소 “국가배상법 제2조”가 정한 국가배상책임의 요건을 충족한다. 이때 객관적 정당성을 상실하였는지는 신청의 대상이 된 처분이 기속행위인지 재량행위인지 등 처분의 성질, 처분의 지연에 따라 신청인이 입은 불이익의 내용과 정도, 행정처분의 담당공무원이 정당한 이유 없이 처리를 지연하였는지 등을 종합적으로 고려하되, 손해의 전보책임을 국가 또는 지방자치단체에게 부담시킬 만한 실질적인 이유가 있는지도 살펴서 판단하여야 한다. 여기서 정당한 이유 없이 처리를 지연하였는지는 법정 처리기간이나 통상적인 처리기간을 기초로 처분이 지연된 구체적인 경위나 사정을 중심으로 살펴 판단하되, 처분을 아니하려는 행정청의 악의적인 동기나 의도가 있었는지, 처분 지연을 쉽게 피할 가능성이 있었는지 등도 아울러 고려할 수 있다.

<선정이유>

- 재결에 판결에서와 같은 기판력이 인정되는 것은 아니어서 재결이 확정된 경우에도 처분의 기초가 된 사실관계나 법률적 판단이 확정되고 당사자들이나 법원이 이에 기속되어 모순되는 주장이나 판단을 할 수 없게 되는 것은 아니라는 판결

<제13장 행정심판의 심리·재결.제02절 행정심판의 재결>

302. 재결의 효력 (4)

“대법원 1998. 5. 8. 선고 97누15432 판결”

<주제>

- 행정심판 재결에 대한 처분청의 불복가능성

<쟁점>

- “행정심판법 제37조 제1항”에 따라 처분행정청은 재결에 기속되어 재결의 취지에 따른 처분의무를 부담하게 되므로 이에 불복하여 행정소송을 제기할 수 없는지 여부

<판결요지>

- “헌법 제117조 제1항”은 지방자치단체는 주민의 복리에 관한 사무를 처리하고 재산을 관리하며, 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다. “제2항”은 지방자치단체의 종류는 법률로 정한다고 규정하는 등 지방자치의 제도적 보장, 지방자치단체의 권능과 종류의 법정주의를 규정하고 있고, 한편 지방자치제도는 국가와는 별개의 법인격을 가지는 지방자치단체를 두어 그 권한과 책임으로 지방에 관한 여러 사무를 처리시키는 것이기 때문에 지방자치단체의 자주성·자율성은 최대한 존중되어야 하므로 이에 대한 국가의 관여는 가능한 한 배제하는 것이 바람직하다 할 것이다. 그러나 지방자치제도도 헌법과 법률에 의하여 국가법질서의 테두리 안에서 인정된 것이고, 지방자치행정도 중앙행정과 마찬가지로 국가행정의 일부이어서 상호 완전히 독립된 것이 아니고 밀접한 관계가 있는 것이므로 지방자치단체는 지방자치의 본질에 반하고, 지방자치의 제도적 보장을 파괴하지 아니하는 범위 내에서 어느 정도 국가의 지도·감독을 받지 않을 수 없는 것이다. 그리고 국가가 행정감독적인 수단으로 통일적이고 능률적인 행정을 위하여 중앙 및 지방행정기관 내부의 의사를 자율적으로 통제하고 국민의 권리구제를 신속하게 할 목적의 일환으로 행정심판제도를 도입하였는데, 심판청구의 대상이 된 행정청에 대하여 재결에 관한 항쟁수단을 별도로 인정하는 것은 행정상의 통제를 스스로 파괴하고, 국민의 신속한 권리구제를 지연시키는 작용을 하게 될 것이다. 그리하여 “행정심판법 제37조 제1항”은 재결은 피청구인인 행정청과 그 밖의 관계행정청을 기속한다고 규정하였고, 이에 따라 처분행정청은 재결에 기속되어 재결의 취지에 따른 처분의무를 부담하게 되므로 이에 불복하여 행정소송을 제기할 수 없다 할 것이며 그렇다고 하더라도 위 법령의 규정이 지방자치의 내재적 제약의 범위를 일탈하여 헌법상의 지방자치의 제도적 보장을 침해하는 것으로 볼 수는 없다고 할 것이다.

<선정이유>

- "행정심판법 제37조 제1항"에 따라 처분행정청은 재결에 기속되어 재결의 취지에 따른 처분의무를 부담하게 되므로 이에 불복하여 행정소송을 제기할 수 없다는 판결

<제13장 행정심판의 심리·재결.제02절 행정심판의 재결>

303. 재결의 효력 (5)

“헌법재판소 2014. 6. 26.자 2013헌바122 결정”

<주제>

- 행정심판 재결에 대한 처분청의 불복가능성

<쟁점>

- 행정심판청구를 인용하는 재결이 행정청을 기속하도록 규정한 "행정심판법 제49조 제1항"이 "헌법 제101조 제1항", "제107조 제2항" 및 "제3항"에 위배되는지 여부

<결정요지>

- [1] 공권력의 행사자인 국가, 지방자치단체나 그 기관 또는 국가조직의 일부나 공법인은 기본권의 주체가 아니라 단지 국민의 기본권을 보호 내지 실현해야 할 책임과 의무를 지는 지위에 있을뿐이므로, 지방자치단체의 장인 이 사건 청구인은 기본권의 주체가 될 수 없다.

- [2] "헌법 제101조 제1항"과 "제107조 제2항"은 입법권 및 행정권으로부터 독립된 사법권의 권한과 심사범위를 규정한 것일 뿐이다. "헌법 제107조 제3항"은 행정심판의 심리절차에서도 관계인의 충분한 의견진술 및 자료제출과 당사자의 자유로운 변론 보장 등과 같은 대심구조적 사법절차가 준용되어야 한다는 취지일 뿐, 사법절차의 심급제에 따른 불복할 권리까지 준용되어야 한다는 취지는 아니다. 그러므로 이 사건 법률조항은 "헌법 제101조 제1항", "제107조 제2항" 및 "제3항"에 위배되지 아니한다.

- [3] 이 사건 법률조항은 행정청의 자율적 통제와 국민 권리의 신속한 구제라는 행정심판의 취지에 맞게 행정청으로 하여금 행정심판을 통하여 스스로 내부적 판단을 종결시키고자 하는 것으로서 그 합리성이 인정되고, 반면 국민이 행정청의 행위를 법원에서 다룰 수 없도록 한다면 재판받을 권리를 제한하는 것이 되므로 국민은 행정심판의 재결에도 불구하고 행정소송을 제기할 수 있도록 한 것일 뿐이므로, 평등원칙에 위배되지 아니한다.

- [4] 행정심판제도가 행정통제기능을 수행하기 위해서는 중앙정부와 지방정부를 포함하여 행정청 내부에 어느 정도 그 판단기준의 통일성이 갖추어져야 하고, 행정청이 가진 전문성을 활용하고 신속하게 문제를 해결하여 분쟁해결의 효과성과 효율성을 높이기 위해 사안에 따라 국가단위로 행정심판이 이루어지는 것이 더욱 바람직할 수 있다. 이 사건 법률조항은 다층적·다면적으로 설계된 현행 행정심판제도 속에서 각 행정심판기관의 인용재결의 기속력을 인정한 것으로서, 이로 인하여 중앙행정기관이 지방행정기관을 통제하는 상황이 발생한다고 하여 그 자체로 지방자치제도의 본질적 부분을 훼손하는 정도에 이른다고 보기 어렵다. 그러므로 이 사건 법률조항은 지방자치제도의 본질적 부분을 침해하지 아니한다.

<선정이유>

- 행정심판청구를 인용하는 재결이 행정청을 기속하도록 규정한 "행정심판법 제49조 제1항"이 "헌법 제101조 제1항", "제107조 제2항" 및 "제3항"에 위배되지 않는다는 결정으로서 헌법상의 재판받을 권리가 행정심판에 대해서 갖는 의미를 밝히고 있다는 점에서 의미가 있는 결정